CONSIDERACIONES PRACTICAS EN TORNO AL PROCESO EJECUTIVO

(En especial el civil de hacienda)

PRIMERA PARTE

Oscar Eduardo González Camacho.

- 1995 -

INDICE

Capítulo I: El Cobro Judicial como parte de la materia Civil de Hacienda.....13

Capítulo II: El Proceso Ejecutivo como Proceso Sumario.....16

Capítulo III: Del Título Ejecutivo.....18

1- Presupuestos.....18

a-) Liquidez.....18

b-) Exigibilidad.....22

2- Naturaleza del Título.....26

3-Clasificación.....29

A- TITULOS JUDICIALES.....30

a- Judiciales en sentido estricto.....30

a-1:El proceso monitorio. Su procedencia contra un ente público.....34

a-2:Resoluciones Judiciales Firmes.....41

b.- Títulos Judiciales Mixtos.....42

B- TITULOS EXTRAJUDICIALES.....46

a- Los Extrajudiciales Negociales.....46

a-1: Negociales de Orden Público.....47

-Testimonios de Escritura Pública
y Asientos Registrales.....47

- Saldos Sobre Aportes de una Sociedad.....54

- Cédulas Hipotecarias.....54

- Certificaciones por Desalmacenaje Aduanero 55

a-2: Negociales de Orden Público con
participación de privados en ejercicio
de funciones públicas.....56

- Cuenta Corriente.....57

- Tarjetas de Crédito.....62

- Propiedad Horizontal.....73

- Almacenes de Depósito.....74

- Peritajes en Materia de Seguros.....74

a-3: Títulos expedidos por particulares.

Inconstitucionalidad.....74

- Institución Médico Privada (232 Cod.Trab.)..75

- Asociaciónes Cooperativas.....76

- Adelantos al Productor de Arroz.....76

- Agente Aduanero. Transporte Mercaderías.....77

a-4: Negociales Privados.....77

- Características de los títulos valores.....78

- Facturas.....80

- Certificados de Depósito.....81

b- Extrajudiciales Administrativos.....83

1-) Certificaciones de la Tributación Directa.....84

2-) Certificaciones del INS sobre riesgos
del trabajo..... 91

3-) Certificaciones Municipales.....92

4-) Certificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. (C.C.S.S.).....93

5-) Certificaciones del INA.....97

6-) Certificaciones del Banco Popular y Desarrollo Comunal.....97

7-) Certificaciones del IMAS.....98

8-) Certificaciones del INVU.....99

9-) Certificaciones del ICAA.....99

10-) Certificaciones de Asignaciones Familiares.....99

11-) Certificaciones del IDA.....100

12-) Documentos de CONAPE.....100

13-) Documentos de JAPDEVA.....100

14-) Certificaciones del ICE.....100

15-) Certificaciones del SNEE.....102

16-) Resoluciones de la Contraloría

General de la República.....102

17-) Copias Certificadas de Títulos Valores-
Ejecutivos extendidas por Bancos Estatales.....108

18-) Certificaciones de la Auditoría General
de Entidades Financieras.....110

19-) Certificaciones sobre "detalles" impagos
en materia de caminos públicos.....111

20-) Certificaciones por servicios de
Defensor Público.....112

21-) Certificaciones de la Ley General de la
Administración Pública.....114

i -: La ejecutividad, ejecutoriedad del acto
administrativo y la ejecución forzosa.....114

ii -: Casos de incertidumbre.....118

iii-: Excesos de salario.....119

iv-: Ambito e Cobertura del artículo 149
de la L.G.A.P.....123

v-: Algunos entes que han utilizado
esta normativa.....125

22-) Certificaciones de la Oficina del Arroz.....125

23-) Certificaciones del Instituto Costarricense
de Turismo (I.C.T.) 126

24-) Certificaciones del Fondo Nacional
de Contingencias Agrícolas.....127

vi-: Alcance del artículo 149 de la L.A.G.P.
Materia susceptible de ser incluida en la
certificación ejecutiva.....128

vii-: Nuestra Posición.....134

viii-:Necesario Cumplimiento de un
Procedimiento Administrativo Previo.
Debido Proceso.....161

ix-: Necesidad de las Intimaciones Previas.....164

x-: Funcionario Competente Para Certificar.....166

xi-:Certificaciones de la Administración por
adeudos de sus propios funcionarios.....168

xii-: Facultad de las Empresas Públicas para expedir certificaciones con carácter ejecutivo a la luz de la L.G.A.P.....179

xiii-:Títulos Administrativos con garantía real inmersa.....180

- Alcantarillado sanitario.....181

- Prenda Legal Aduanera.....181

- Hipoteca Legal Municipal.....182

25-) Certificaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica.....182

Capítulo IV: Prerequisitos de la Demanda.....186

1- El agotamiento de la vía administrativa como requisito de admisibilidad.....189

CAPITULO V: La Demanda Ejecutiva. Requisitos.....194

1- Nombres y Calidades del Actor y Demandado 194

a- PODERES.....199
a-1: Mandato y Poder.....199
a-2 : Tipos de Poder.....201
a-2-1: El Poder Generalísimo.....201
a-2-2 : El Poder General.....203
i- Comprobación de Poderes en el
Sistema Bancario Nacional.....205
ii- Los Fiscales Específicos en la
Tributación Directa.....206
a-2-3: El Poder Especial.....207
a-2-4 : El Poder Especialísimo.....207
a-2-5: Poder o Mandato Representantivo
Judicial.....208
a - 3: Timbres del Poder.....211
a - 4: Limitaciones al Poder.....214
a- 4 -1: Poderes Conjuntos.....215
a- 4 -2: Sustitución del Poder y
Poderes Sucesivos.....216
a - 5: La Extinción del Poder.....221
a-5-1: La extinción del plazo.....222
a-5-2: La renuncia del apoderado.....222
a-5-3: La extinción del plazo y la renuncia
en materia mercantil.....223
a-5-4 : La revocación.....229
a-5-5: La extinción del poder sustituido
y del subpoder.....230

2- Exposición sucinta de los hechos.....233

3- Fundamentos de Derecho.....234

4- Pretensión.....234

a- Innecesaria solicitud expresa para
el decreto de embargo.....236

b- Costas No Pedidas.....237

5- Pruebas.....238

6- La cuantía.....240

7- Lugar para oír notificaciones.....242

8- Firma de la parte o partes.....242

9- La Autenticación.....243

10-Timbres de la Demanda.....246

a- Timbres del documento base.....247
b- Entidades exentas de pagar timbres.....252
c- Entidades no exentas del pago de timbres.....259
d- La necesaria y debida cancelación

de los timbres.....261
e- Timbres de la Autenticación.....267
11- Copias.....270

Capítulo VI: Defectos de la Demanda.....274

Anexos.....279
1- Esquema sobre la clasificación de títulos.....280
2- Formularios base para demandas ejecutivas.....281
a- Ejecutivo Simple.....281
b- Ejecutivo Hipotecario.....284
c- Ejecutivo Prendario.....288

PRESENTACION

Capítulo I: El Cobro Judicial como parte de la materia Civil de Hacienda

Nuestra Jurisdicción se ha denominado tradicionalmente "Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", pero en realidad no todos conocen con claridad la diferencia fundamental entre los vocablos o expresiones referidas, por lo que es preciso aclarar que una cosa es la materia "contencioso administrativa" y otra la "civil de hacienda".

Digamos por ahora que la jurisdicción contencioso administrativa como tal, está destinada - o debería estar dirigida - al conocimiento y revisión de las conductas de la Administración en su esfera pública, lo que incluye entre otras cosas, todos aquellos actos y disposiciones del ente público en su esfera de autoridad. Dicho de otro modo, la jurisdicción contencioso administrativa en sentido estricto, es la encargada de conocer esencialmente de la impugnación de actos administrativos, como sería el caso de la impugnación de un acto que declara la caducidad de una concesión de servicio público; o el acuerdo o resolución en donde se ordene el cierre de una cantina; o de la destitución de un servidor público que reclama su reinstalación, etc. La materia civil de hacienda en cambio, está dispuesta básicamente, para la discusión de aspectos patrimoniales, a saber de los bienes muebles e inmuebles, así como lo relativo a la responsabilidad generada del incumplimiento de un contrato y todo el ámbito extracontractual. Bajo este prisma, la Administración Pública

actúa en su faceta privada, pasiva o activamente, y en algunas oportunidades incluso, como típico ente empresarial. Así encontramos que la esfera civil de hacienda rebasa en mucho, el proceso de conocimiento (que en nuestro caso se reduce al ordinario), pues en ella se incluye toda la materia relativa al procedimiento de cobro judicial (procesos ejecutivos sobre todo); desahucios; interdictos; ejecuciones de sentencia; diligencias de avalúo por expropiación; medidas cautelares, etc. Sin embargo, aquí es preciso señalar que de toda esta materia civil de hacienda, solamente el ordinario se tramita de conformidad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Aquí, es preciso agregar a modo de aclaración, que también algunos aspectos de la ejecución de sentencia de los que se encarga dicha Ley Reguladora (arts. 78 y siguientes), son aplicables tanto a las diligencias de avalúo por expropiación cuanto a los procesos ejecutivos una vez establecida (o ratificada) la obligación de pagar para el ente público demandado (acerca de la aplicación de la Ley Reguladora a las materia expropiatoria, puede verse la ley número 5052 de 17 de agosto de 1972 interpretada por ley número 5540 de 8 de julio de 1974, en tanto que sobre la aplicabilidad de la misma ley en la vía de apremio puede verse la resolución del TSCA. Secc. II No 4097 de las 9:50 hrs. del 6 de setiembre de 1988). En consecuencia, todos los procesos distintos del ordinario civil de hacienda y con la excepción apuntada, deben aplicar el procedimiento de su respectiva ley especial, que para el caso del proceso ejecutivo, lo es el Código Procesal Civil.

En otras palabras, el proceso ejecutivo en materia civil de hacienda, se tramita igual que en materia civil común, bajo el Código de Rito antes indicado, salvo en algunos pequeños aspectos en los que permea y prevalece la materia ius-publicista, según veremos en el transcurso de esta exposición. De esta forma lo señala con toda claridad el artículo 3 de la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que en su inciso primero dispone:

> *"1. Para los fines del inciso c) del artículo anterior, de los juicios atribuidos a la vía civil de hacienda, los ordinarios se tramitarán de conformidad con la presente ley, y los demás, de acuerdo con la tramitación señalada en el Código de Procedimientos Civiles o en leyes especiales."*

Por último, es conveniente señalar que la jurisdicción civil de hacienda conoce también de los procesos en donde sea parte (pasiva o activamente) un ente económico o empresa pública ente privado, que aunque no sea parte de la Administración Pública (conforme a los artículos 1 e inciso 2. del artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública) sí generan un interés directo para el Estado, ya se trate de empresas nacionales o mixtas, esto por disposición expresa del artículo 86 de la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial, hoy trasladada en forma más clara al artículo 110 de la nueva normativa correspondiente a este Poder, de acuerdo con la Ley número 7333 de 5 de mayo de 1993.

Capítulo II: El Proceso Ejecutivo como Proceso Sumario.

Dentro de la clasificación que establece nuestro Código Procesal Civil, encontramos que el proceso ejecutivo simple está ubicado como uno de los procesos sumarios, tal y como realmente debe ser, no solo por la celeridad en su trámite, sino además por la limitación en cuanto a las pretensiones y defensas que pueden formularse en él. En efecto, este tipo de procesos está dirigido a la recuperación - posible o no- de un crédito, cuya existencia consta en un documento - privado o público- y contra el cual solo caben determinado tipo de excepciones o defensas, pues de lo contrario estaríamos convirtiendo al ejecutivo en una especie de proceso declarativo, de conocimiento o abreviado, que desvirtuaría toda su razón de ser y finalidad, dirigida exclusivamente a la satisfacción del derecho del acreedor por medio de los bienes del deudor, o más concretamente, a la utilización de un conjunto de medidas compulsorias ejercidas sobre el patrimonio del demandado, tal y como lo preceptúa el artículo 693 del Código Civil.

Esta razón de ser del proceso ejecutivo - la que a su vez establece su naturaleza misma- debe tenerse muy en cuenta, pues no son pocas las críticas que se han dirigido a los Tribunales de Justicia en esta materia, cuando se afirma que "han convertido el proceso de cobro judicial en un pequeño juicio (sic) ordinario". Y es que, debemos insistir, el proceso ejecutivo está dirigido a tratar de satisfacer el adeudo no cubierto por el deudor, utilizando para ello los

diferentes medios compulsatorios que brinda el ordenamiento. Así, se entiende que se trata de un proceso ágil y rápido, inspirado en la economía procesal, y en el que hay limitación del conocimiento, tanto en los aspectos que el acreedor pretende discutir cuanto en relación a defensa que el demandado puede esgrimir. En ese sentido encontramos que el artículo 433 del Código de Rito sólo permite oponer las excepciones allí contempladas expresamente.

Capítulo III: Del Título Ejecutivo.

1- Presupuestos.

En primer término conviene puntualizar los requisitos del título ejecutivo como tal, o más bien determinar, cuáles son los presupuestos genéricos del mismo para poder establecer así en un caso concreto si estamos o no frente a un documento de esta naturaleza. Siguiendo la línea doctrinal ortodoxa, podemos afirmar que para la existencia del título ejecutivo se requieren tres elementos básicos, a saber: identificación de las partes, liquidez (actual o potencial) y exigibilidad. Es obvio que los sujetos del título han de estar plenamente identificados: el obligado u obligados y el acreedor, de quienes debe señalarse el nombre, apellidos, calidades, domicilio y cédula de identidad, pues de lo contrario carecerá de la ejecutividad requerida, salvo que se trate de un título al portador en cuyo caso el acreedor varía conforme a la circulación del documento. En este sentido resulta revelador el artículo 440 del CPC cuando manifiesta que: *"Si el actor acreditare su personalidad, y si el título presentado fuere ejecutivo, el juez despachará..."*. Si bien es cierto el artículo se refiere ante todo a los requisitos iniciales del proceso ejecutivo, antes que a los del título, sí resulta importante el énfasis que se hace en el elemento activo del acreedor, que deberá coincidir en el título y la demanda.

a-) Liquidez: En cuanto a la liquidez, ha de entenderse que se trata de un presupuesto relativo al objeto de la obligación, en la medida que ha de ser cierto y determinado, es decir,

claro y cierto en cantidad o valor, esencialmente en una suma de dinero, o en su caso, de fácil determinación para el Juez con vista del documento presentado. En este segundo caso la iliquez es solo aparente, pues con una simple operación aritmética puede el Juzgador concretar la suma adeudada, reduciendo la obligación a un aspecto dinerario. Así lo dispone nuestro Código Procesal Civil en el párrafo segundo del artículo 440 y en el numeral 442. Disponen las normas de cita lo siguiente:

> *"La ejecución no podrá despacharse sino por deuda cuya cantidad sea líquida, o que pueda liquidarse con vista del documento presentado, ..."*

> *"Si el título contuviere una obligación que sólo sea cierta y determinada en parte, por ésta se despachará la ejecución"*

Los Tribunales Civiles de Hacienda han sabido interpretar el recto sentido de este presupuesto cuando en algún caso, conjuntamente con la promesa incondicional de pago de una suma determinada en forma clara y precisa, se han establecido diversas claúsulas adicionales tendientes a garantizar el monto exacto que debe percibir el acreedor.

De esta manera, han indicado que las estipulaciones que atribuyen al ente deudor el pago de los impuestos, timbres y recargos correspondientes a la obligación contraída, así como

la compensación por cualquier disposición normativa sobreviniente que altere la contraprestación inicialmente pactada, **"no condicionan"** la obligación. En realidad, cuando el Tribunal señala que la obligación no está condicionada, parece referirse a la liquidez misma de la operación, adoptando con ello, la terminología amplia de algún sector doctrinal que incluye como parte de ésta, la exigibilidad, tesis que no compartimos, dado que definir la liquidez como "aquella suma determinada y exigible, no sujeta a condiciones términos ni discusión", no es mas que superponer los dos conceptos, con su consecuente confusión. Y llama la atención, pues el problema de la liquidez, al que realmente alude el órgano colegiado de referencia, fue precisamente el obstáculo que había interpuesto el Despacho de instancia cuando señaló que:

> *"...el monto original por el que la deuda se contrajo, puede eventualmente variar, sea que la certeza de la suma adeudada se desnaturaliza al estar sujeta a la eventual indemnización a que se somete a la deudora, por lo que la promesa de pago de una suma liquida y determinada resulta viciada..." (el subrayado no es del original)* (En este sentido puede verse la resolución del Tribunal Superior Sección Segunda, número 1975 de las 9:00 del 12 de agosto de 1985)

La susceptible liquidez que del título pueda hacer el Juzgador, no debe confundirse con aquellos supuestos en los que se plasma documentalmente la obligación de hacer, ni cuando se

refiera a obligaciones de dar directamente objetos diversos al dinero (como puede ser el caso de algunos bienes fungibles), pues en ambos **no se cumple con el presupuesto bajo análisis** de acuerdo con la afirmación anteriormente hecha. Tampoco puede hablarse de liquidez cuando una persona física o jurídica se compromete a "indemnizar" en forma genérica a quien se convierte en su acreedor, pues el monto de dicha indemnización es todavía impreciso, sujeto a una posterior determinación (fijación del "cuantum") que no puede darse en la vía ejecutiva. Aquí es preciso señalar que la liquidez y exigibilidad no solo son presupuestos necesarios del proceso ejecutivo sino también del monitorio (artículo 502 del CPC), en donde cabalmente se originó el anterior punto de vista, cuando la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso señaló lo siguiente:

> *"En ellos* (los documentos) *sin duda alguna, el Fondo se compromete a indemnizar a los agricultores aquí demandantes, no obstante, no concuerda al Tribunal con que tales montos sean exigibles (sic) ya que lo que tales documentos expresan es el término "indemnizará", respecto del cual indica el Diccionario de la Lengua Española, indemnizar es: "... resarcir de un daño o perjuicio ..." (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid, 1984, Pag. 766) , lo que en sentir de este Despacho, en modo alguno implica exigibilidad (sic) de los montos en cada documento certificado, razón de más para expresar que la vía*

utilizada por las aquí actoras no es la hábil para la creación de título ejecutivos." (Res. No 258-93 de las 10: 22 10 hrs. del 15 de junio de 1993)

Como puede verse, también en la resolución anterior el Tribunal parece confundir el concepto de "exigibilidad" con "liquidez" al que en principio y dentro del contexto realmente alude.

También deben incluirse dentro de la suma líquida de que se habla, todos aquellos rubros correspondientes a intereses, siempre que se hayan liquidado al momento de formular la demanda, independientemente de su procedencia posterior, pues no solo están determinados en ese momento , sino que al igual que el capital, se presumen válidos, ciertos y efectivamente adeudados.

b-) Exigibilidad: La exigibilidad por su parte, debe entenderse mas bien como la presunción de exigibilidad, puesto que el Juez no hace otra cosa que examinar el documento base de previo a despachar ejecución, sin que pueda en ese momento - por la etapa inicial y por la sumariedad del proceso- determinar a ciencia cierta si realmente es exigibile o no, guiándose en esta fase por el solo dicho del acreedor, dada la inversión de la carga de la prueba que en esta materia existe.

En este mismo sentido lo ha interpretado la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, la que en

resolución número 139 de las 7:30 hrs. del 27 de abril de 1982, señaló:

> *"... basta el dicho de la Editorial sobre el eventual incumplimiento de Textos Meoño S.A., para tener dicho incumplimiento por cierto para efectos judiciales".*

La exigibilidad como tal, cubre a su vez dos elementos esenciales: la promesa incondicional de pago y el vencimiento del plazo . La primera se refiere a que la obligación plasmada en el documento como tal, debe ser incondicional, o para el caso de que se haya dispuesto sujeta a condiciones, que las mismas ya se hayan cumplido. Para decirlo en otros y mas claros términos, se trata de una **promesa pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero**, lo que supone, según el dicho de la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso (en adelante TSCA. Sec II): *"que al momento en que se formuló sea, a la fecha del otorgamiento, exista desde ya la causa jurídica que sirve de fundamento a la obligación, y la cual por eso mismo siempre debe entenderse implícita en el título valor".* (Res. No 1378 de las 10:25 hrs. del 2 de mayo de 1984). De modo que si la obligación se sujeta a condiciones futuras y dependientes de terceros (es decir no ciertas), el requisito de exigibilidad cae, y por ende se pierde la ejecutividad del mismo. En esto el Tribunal de referencia ha sido muy celoso, pues ante algún viso claro de condicionalidad, niega la ejecutividad al título, como lo hizo por ejemplo en la resolución No 3592 de las 9:10 hrs del 2 de octubre de 1979, cuando indicó:

"Ahora bien, el pagaré es un documento por el cual la persona que lo suscribe promete incondicionalmente pagar a otra una cierta cantidad de dinero dentro de un determinado plazo, y deberá contener, entre otros requisitos y acorde con lo anterior, la promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero; por manera que si la promesa de pagar no es pura y simple, el documento se desnaturaliza y no es válido como pagaré (arts. 799, 800, inciso b), y 801 del Código de Comercio) ; por lo que, al no contener el documento base de este juicio una promesa incondicional de pago, sino una condicionada al hecho futuro e incierto de que un tercero, el Banco Nacional de Costa Rica, haga efectivo el aval rendido a su favor por el Consejo Nacional de Producción, lo desnaturaliza como pagaré, y por tal razón no es la vía ejecutiva la indicada para cobrar la obligación que se pretende..."

O como quedó evidenciado en la resolución No 1378 antes citada, en la que se dijo:

"De ello se desprende, que tal documento es contradictorio en cuanto a la certeza del adeudo original y de su exigibilidad, siendo evidente de su texto, que allí no se consigna un derecho autónomo, sino supeditado a que ocurra un hecho futuro e incierto en la ejecución de otro negocio jurídico

(...) en el presente caso, dado el contenido literal de los documentos analizados íntegramente, resulta que se está en presencia de una promesa condicionada de pagar una suma de dinero no determinada, pues s u liquidación y exigibilidad dependen de que con e l transcurso del tiempo se produzca la causa que genere l a 25 obligación de pago, causa que sería el eventual incumplimiento frente al tercero".

Por su parte, el segundo elemento se refiere a que el plazo otorgado en beneficio del deudor para la ejecución de la prestación comprometida, ya se encuentra vencido. Nótese que en última instancia, la exigibilidad va de la mano con el incumplimiento mismo de la obligación contraída y plasmada en el documento ejecutivo, pues si pagó por ejemplo, ya se extinguió, o si todavía no se ha cumplido el plazo para el pago respectivo (parcial o total) no existe adeudo ("el que tiene plazo nada debe", art. 773 Código Civil), y en consecuencia, en ambos casos, el crédito no es exigible. Igual sucede en la hipótesis de que convirtiéndose en exigible la obligación y habiéndose puesto al cobro judicial, se llegue con posterioridad a un arreglo de pago en el se prorrogue el plazo para cancelar la deuda, pues a partir de allí hay un decaimiento del presupuesto bajo análisis por una nueva circunstancia fáctica sobreviniente. En estos mismos términos lo ha dispuesto el Tribunal Superior Contencioso (Secc. II) cuando puntualizó como sigue:

"... las partes convinieron en un arreglo de pago, en

el que se canceló en el acto, la suma de sesenta mil colones y e l saldo de noventa y cuatro mil trescientos trece colones se acordó pagar en tres cuotas el día treinta de los meses de setiembre, octubre y noviembre, todos del año de cita. Esto permite concluir, que con posterioridad a la emisión de la certificación inicial, el monto debido no solo se modificó, sino además que perdió su naturaleza de exigible, a l haberse otorgado plazo para su cancelación, ..." (el subrayado no es del original) (Res. No 1024-92 de las 10:00 del 25 de noviembre de 1992)

Con esto también se explica el hecho de que el incumplimiento de un pago en una obligación dispuesta a tractos, para el caso de que así se haya pactado, haga exigible la totalidad de la misma, dando derecho a su cobro en la vía ejecutiva. En este supuesto se está incumpliendo con los términos establecidos para la obligación, por vencimiento del plazo parcial, lo que lleva a la exigibilidad plena del título.

2- Naturaleza del Título.

Ahora bien, al amparo de nuestra legislación (art. 438 del CPC en todos sus incisos, incluyendo el acápite 4, que debe interpretarse como el acta en la que consta la confesión judicial o declaración de rebeldía) podemos entender el título ejecutivo como un "acto - documento", en el sentido de que viene a ser la prueba documental que se presenta ante el Juez

para demostrar la existencia de una deuda establecida con anticipación, y que eventualmente como tal puede ser destruido; encontramos que en nuestro ordenamiento existe una enumeración en apariencia taxativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 438 supracitado. Y decimos que la enumeración es taxativa tan solo en apariencia, puesto que la misma disposición en su inciso 6 deja abierta la posibilidad a la existencia de más títulos conforme lo señalen las diferentes leyes especiales, apertura que según veremos, cubre la gran mayoría de títulos con fuerza ejecutiva que hoy se conocen y se utilizan. Sobre este último aspecto, es preciso enfatizar que la existencia de títulos diversos a los allí señalados, solamente puede darse por disposición de orden legal, pues en esta materia opera el principio de reserva de ley, que será la única capaz de conferir ejecutividad a un determinado documento de crédito, el que por el hecho de ser tal, no es necesariamente ejecutivo, dado que se requiere - tal y como se viene afirmando de manera reiterada-, disposición legal expresa que le otorgue dicho carácter. Sobre este particular conviene transcribir parte de la interesante sentencia adoptada por el TSCA.

Secc. II. No 570 de las 11:18 hrs. del 29 de octubre de 1982, redactada por el Juez Vindas Valdares, que en lo conducente señala:

> *"Que, como es la ley la que les otorga carácter de título ejecutivo a determinados documentos, el que se presente con la pretensión de estar revestido de*

fuerza ejecutiva debe tener un origen y formación de orden legal incuestionable. Tanto más rigurosamente clara debe ser la procedencia y calificación legal del documento, cuanto que, el título de tal naturaleza jurídica, por tener el derecho incorporado al mismo, abre una vía sumaria, y a veces sumarísima, que se torna en excepción dentro del ordenamiento procesal para hacer efectivo ese derecho.

siendo entonces el título ejecutivo un documento privilegiado, el que se presente como tal debe ser examinado en presencia de las disposiciones que le pueden ser aplicadas sin que sea dable interpretarlas de modo tal que expediten la vía ejecutiva, pues el precepto que la autorice debe ser claro y preciso al respecto. De modo que, si de acuerdo con ese examen resulta cuestionable la idoneidad del documento como título ejecutivo, a éste no puede reconocérsele ese carácter, siendo entonces otra la vía a que deba recurrir quien pretenda hacerlo valer. Esos son los alcances del principio de reserva legal que consagra el artículo 425 (hoy 438) del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto éste señala taxativamente cuáles son los documentos que constituyen título ejecutivo, y especialmente en cuanto en el inciso 7o establece que los son también, "los que por leyes especiales tengan fuerza ejecutiva".

3.- Clasificación.

De la lista de títulos que establece el artículo 438 del Código Procesal Civil, podemos intentar alguna clasificación con miras a una mayor claridad en cuanto a la diversa tipología de documentos a los que la ley confiere ejecutividad. Siguiendo la corriente tradicional, desde el punto de vista de su origen, podemos agrupar los títulos ejecutivos en dos grandes grupos: **judiciales y extrajudiciales** (con esto seguimos y luego ampliamos la clasificación básica que menciona don Walter Antillón M. en su artículo "Notas Sobre Nuestro Proceso Ejecutivo Común, publicado en las revistas de Ciencias Jurídicas No 2 de noviembre de 1963, pgs. 25 y ss, y No 3 de mayo de 1964). Dentro de los primeros encontramos la certificación de resoluciones a que alude el inciso 5) conjuntamente con los documentos privados y la confesión judicial a los que se refieren los incisos 3) y 4). Por su parte, como comprendidos en los extrajudiciales tenemos los referentes a escrituras públicas y demás documentos inscribibles que se incluyen en los incisos 1) y 2), y por supuesto la lista abierta a leyes especiales que permite el inciso 6) del mismo artículo. Cada uno de estos grupos puede subdividirse, y así encontramos que los "judiciales" pueden clasificarse a su vez en **propiamente judiciales o judiciales en sentido estricto, y los mixtos o híbridos**. A su vez, los extrajudiciales se ramifican en **negociales y administrativos**, siendo que los negociales pueden clasificarse como **públicos o privados.**

A- TITULOS JUDICIALES

a- Judiciales en sentido estricto.

Entendemos por títulos judiciales en sentido estricto aquellos que nacen del seno exclusivo del órgano jurisdiccional, es decir, aquellas resoluciones judiciales que al ser líquidas y exigibles, sirven de fundamento a un proceso ejecutivo, toda vez que por aspectos fácticos o jurídicos, no pueden hacerse efectivas en el mismo proceso o procedimiento donde nacieron.

De los catalogados como judiciales, solamente consideramos como propiamente tal ("judicial en estricto sentido") al contenido en el inciso 5) del numeral de comentario, pues se refiere a:

> *"Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan, a cargo de un tercero o de una parte, l a obligación de pagar una suma líquida, cuando ésta no hubiere podido cobrarse dentro del mismo proceso"*

Como puede verse se trata de una resolución condenatoria, y no solo eso, sino que además por suma líquida, con lo cual se cubren los presupuestos mencionados arriba. Nótese además, que se trata del caso en que no se haya podido cobrar dentro del mismo proceso en donde se dispuso la obligación, lo que obliga acudir a la vía sumaria ejecutiva. Tal sería el caso, por ejemplo, de una pensión alimenticia, para la cual el artículo 17 de la ley respectiva confiere ejecutividad.

Dispone el mencionado numeral lo siguiente:

*"**La obligación de alimentos constituye título ejecutivo.** Si hubiere renuencia al cumplimiento del obligado, podrá despacharse ejecución y embargo por las sumas adeudadas y acumuladas en tanto no mayor de un año.- También podrá despacharse ejecución en caso de renuencia tal y como se contempla en el artículo 12." (la negrita no es del original)*

En este supuesto se certifica la sentencia que impuso la obligación, el monto que se obligó a pagar por cada mes futuro, y los meses aún no cubiertos con el total adeudado, todo lo cual permite que se despache ejecución por una suma determinada. Por cierto, en esta materia la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto la posibilidad de que el monto adeudado de la pensión, puede cobrarse por la vía ejecutiva en la misma Alcaldía de Pensiones sin necesidad de acudir a la jurisdicción civil, esto en aras de la economía procesal.

En lo que interesa señaló la Sala lo siguiente:

"Las Alcaldías de Pensiones Alimenticias adquirieron ese rango en virtud de la Ley No 5711 de 27 de junio de 1975 y el respectivo acuerdo tomado por la Corte Plena en cumplimiento de esa normativa. A partir de la vigencia de aquella, asumieron el conocimiento de los asuntos de pensión alimenticia, en los términos que resultan de la misma (numerales 8 a 13). Si ello forma parte del ámbito de la competencia material (artículo 95 inciso 2o , de la Ley Orgánica del Poder

Judicial), la Alcaldía que tramita un negocio sobre alimentos, está facultada para conocer de él, de las distintas incidencias que se promuevan, con las excepciones que resultan de la ley por razón de la cuantía (ordinal 21 del Código Procesal Civil) y , consecuentemente, para ejecutar sus resoluciones en l a vía de apremio, para lo cual no hay ningún impedimento legal aún tratándose de cuestiones incidentales, y más bien dicha actividad judicial coactiva es inherente a la materia de que conocen los Alcaldes de Pensiones Alimenticias, según resulta del artículo 17 de la respectiva ley (resolución de la antigua Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No 117 de las 14:10 horas del 12 de abril de 1978)." (Sentencia No 61 de las 14:50 hrs. del 3 de abril de 1991)

Otro supuesto que cae en este tipo de títulos, es el contenido en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley de Inquilinato, que confiere ejecutividad a la certificación del auto firme expedido por una autoridad civil o penal en el que se fije el monto de los daños que el inquilino esté causando a la casa o local, luego de efectuado el reconocimiento legal correspondiente.

También puede darse como ejemplo de esta hipótesis, aquellas resoluciones firmes en las que se ha acogido una acción civil resarcitoria en sede penal, condenando en suma líquida y

determinada, y en la que figure el Estado (entendido el término en sentido amplio) como parte, o bien, que tenga interés directo en el asunto. Sin embargo, en este sentido tiene que aclararse que no se acude a la fase de conocimiento limitado del sumario (ejecutivo), sino directamente a la fase de ejecución por la vía del apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 630 del Código Procesal Civil.

Bajo este supuesto, suele incluirse en la práctica con evidente error, la resolución firme que declara con lugar en definitiva el incidente dirigido al pago de los alquileres no cubiertos luego de decretado el desahucio, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 454 del Código Procesal Civil. Y decimos que por error, por cuanto el inciso 5 del 438 es claro al establecer como título aquella certificación de resolución firme *"cuando esta no hubiere podido cobrarse dentro del mismo proceso"*, que cabalmente es lo que no ocurre en el caso concreto, dado que la condenatoria de los alquileres no cubiertos se ejecuta dentro de la misma incidencia y no por aparte; es decir, se convierte en una especie de ejecución de sentencia con el apremio de bienes, antes que un proceso ejecutivo.

Tampoco debe confundirse la figura en comentario - tal y como ocurre muy frecuentemente-, con el proceso de ejecución propiamente dicho de una resolución judicial en estricto sentido, como es el caso de una acción civil resarcitoria declarada con lugar en forma abstracta o la ejecución de una resolución de la Sala Constitucional, en donde se acoge el

recurso de amparo; pues es obvio que allí no solo habrá de determinarse el cuantum de la condena, sino que además tiene su procedimiento específico, a saber: la ejecución de sentencia. Esto fue cabalmente lo que llevó a los redactores del nuevo Código Procesal a eliminar de este artículo la ejecutoria de una sentencia, que de alguna forma podía catalogarse también como judicial en sentido estricto. Y la razón de ello - como hemos dicho- es que para ésta existe un trámite distinto, como es precisamente el de ejecución de sentencia, consagrado en forma expresa para dicho supuesto en los artículos 692 y siguientes del mismo Código.

a -1: El proceso monitorio. Su procedencia contra un ente público.

Pero aquí sí parece caber entre otras figuras, la hipótesis del proceso monitorio que culmina cabalmente no con una resolución que confiere ejecutividad al documento presentado y carente de tal requisito, sino que concluye con una resolución judicial que establece el deber de pagar la suma principal, y un monto dirigido a cubrir los intereses y ambas costas, disponiendo además en su caso, el embargo correspondiente. Aquí puede discutirse si la creación del título, al que va dirigido este breve proceso documental, se da con la orden inicial de pago que emite el Juez, luego de transcurrido el plazo otorgado sin oposición alguna o al menos eficaz (art. 502 C.P.C.), o,

si el título mismo se constituye con la sentencia dictada con posterioridad, de acuerdo con los artículos 503 y 504 del Código Procesal Civil. Nos inclinamos por el primer supuesto, pero independientemente de ello, lo importante aquí es dejar claro que no se trata entonces de un documento privado reconocido ante autoridad judicial y que luego servirá 35 de base al proceso ejecutivo, ni del caso de la confesión ficta a la que luego aludiremos, sino, insistimos, de una resolución firme que adquiere ejecutividad para todo efecto, como parte del supuesto que señala el inciso 5 de la norma de comentario.

Y aprovechando que mencionamos el tema del proceso monitorio, cabe comentar en forma breve alguna sentencia reciente del Tribunal Superior Contencioso, Sección Segunda, que debemos confesar, nos ha causado gran sorpresa. Efectivamente, la Sección mencionada, (no integrada por sus titulares), ha dispuesto de manera tajante que el proceso monitorio no tiene cabida contra la Administración Pública, es decir, un particular no puede hacer uso de este instituto procesal cuando se enfrente un ente público. Declaró en lo que interesa el Tribunal en la resolución número 116-94 de las 14:50 hrs. del 23 de febrero de 1994, lo siguiente:

> *"Se concluye entonces, que el proceso monitorio en nuestro medio, estaría reservado exclusivamente para las obligaciones entre particulares, excluyéndose por las razones aquí ofrecidas, los créditos en contra del Estado (creemos que el término debe entenderse en sentido lato por lo que adelante se agrega) los*

cuales requieren de una tramitación muy particular (...) En atención al cuadro fáctico señalado, se insiste que, un proceso monitorio no puede tener cabida en cuanto se refieran a obligaciones del Estado, pues las demandas que se presenten contra el Estado o sus instituciones, requieren del agotamiento previo de la vía administrativa (artículo 548 del Código Procesal Civil)".

En un primer momento la resolución parece referirse tan solo al Estado, pero luego queda claro que está dirigida a la Administración Pública y que tan solo se produce una confusión de conceptos, pues más adelante sí se habla del Estado y sus instituciones, lo que obviamente es muy distinto, amén de que el proceso declarado sin lugar, está dirigido contra una Municipalidad, que como todos sabemos no es parte del Estado en sentido técnico. Pero dejando de lado eso, hay una cosa clara en la sentencia: según dicho Tribunal, no cabe el monitorio contra el Estado y los entes públicos menores. Y para arribar a tal conclusión se sigue una serie de razonamientos que por equívocos, llevan también a una conclusión general e indiscriminada que no podemos compartir. Esto, claro está, con absoluta independencia de la solución que consideramos para el caso específico y concreto; es decir, no estamos diciendo con ello, que el asunto debía revocarse y declararse con lugar, pues al parecer existían otras causas que lo impedían.Veamos algunos de los fundamentos más importantes.

Se parte de tres razonamientos: a-) para el pago de cualquier

documento a cargo del Estado o de un ente público se requiere del refrendo de la Contraloría General de la República, pues *"... para que la obligación sea exigible..." (sic)* se requiere el refrendo de aquel órgano fiscalizador (se citan los artículos 20 y 66 de la Ley de la Administración Financiera de la República, 80 del Código Municipal y 4 inciso g. de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República); b-) que el Tesorero Municipal no puede hacer pago sin acuerdo municipal previo (artículo 135 del Cod. Municipal), y c-) que toda demanda contra el Estado y sus instituciones requiere del agotamiento de la vía administrativa (art. 548 del C.P.C.). En primer lugar, las citas de la Ley de la Administración Financiera se refieren al Estado Central no a las municipalidades. De allí que llama la atención que por un lado se menciona la Tesorería Nacional y por otro al Tesorero Municipal, si el pago debía hacerlo el segundo, no se entiende el por qué la cita de la Ley de la Administración Financiera. Pero uno de los argumentos más importantes es la ausencia del refrendo a aprobación de la Contraloría General de la República, sin tener presente que por circular éste órgano dispuso desde hace algún tiempo , el innecesario refrendo contralor de aquellos contratos suscritos por entes descentralizados, y que en todo caso, aquella aprobación es un requisito de eficacia, no de exigibilidad de la obligación, y a lo sumo, un requisito necesario para el pago en sede administrativa, no para accionar con el documento como elemento probatorio ante los Tribunales. Por otra parte, es claro que se

requería acuerdo municipal para el perfeccionamiento del mismo en sede administrativa, pero no para efectos de comprobación en sede judicial. Además, con independencia de todo ello, se deja de lado la obligación de pago para la Administración aún nacida de contrato formado de manera imperfecta, siempre que el ente público hubiere recibido la prestación efectiva pactada, estableciéndose claro está, una sanción patrimonial por la violación de los procedimientos (véase al respecto la letra clara del artículo 272 del Reglamento de Contratación Administrativa). Por último, es obvio que para accionar contra la Administración Pública se debe de agotar la vía administrativa, aún cuando sea en sede civil de hacienda (art. 548 del C.P.C.), pero ese es precisamente el presupuesto **procesal** para accionar, no la razón para denegar la posibilidad de accionar en general en un instituto específico.
Es decir, si se requiere agotar la vía administrativa para accionar, es precisamente que se puede accionar. Es más, si este fuere en verdad el obstáculo, sería simple subsanar el defecto, realizando un adecuado agotamiento de la vía administrativa.

De seguirse la tesis esbozada por el Tribunal, se estaría dando:

1-) Un privilegio odioso en favor de la Administración Pública en perjuicio del administrado. Interpretación que sería contraria a la Constitución Política, por violación abierta a principio de igualdad contenido en el artículo 33, aplicable en todo a la situación, por tratarse cabalmente de situaciones

iguales.

2-) Un privilegio más para la Administración por simple criterio jurisdiccional (que no jurisprudencial), cuando éstos solo pueden ser creados por ley expresa, por ser precisamente materia de reserva legal. Solo este aspecto genera la ilegalidad e inconstitucionalidad del privilegio creado.

3-) Se someterían al orbe jurisdiccional, las autorizaciones y aprobaciones de un ente u órgano público, en la medida en que los Tribunales sólo podrían condenar a un ente público si el encargado de la remoción del obstáculo legal para actuar, o bien para ejecutoriar la decisión, así lo hizo (como sería en este caso la Contraloría). Eso según 39 se vio, no es lo que señala nuestro ordenamiento.

4-) Si efectivamente fuese cierto que solo cabe entre particulares, como lo señala la sentencia, ¿ qué sucedería entonces cuando el Estado y sus entes actúan en su fuero privado como particulares ?. Naturalmente habría de responder que para ese caso sí es procedente el monitorio. ¿ Por qué entonces el distingo ?.

5-) Los requisitos procesales (presupuestos previos), no serían requisitos para establecer la demanda sino obstáculos absolutos y generales para accionar en una determinada sede sobre la generalidad de un instituto procesal.

Y esto último es lo que más preocupa, pues aún dejando de lado los fundamentos que se utilizan en las consideraciones para el caso concreto (que no compartimos pero que para nada deben mezclarse con lo resuelto en la parte dispositiva de la

sentencia, la que para nuestro efectos podía resolverse o no como se hizo, da igual), tenemos que si algo fallaba en el caso particular, y eso impedía acoger el caso específico, debió el Tribunal limitarse a hacerlo, puntualizando los aspectos concretos que obligaban al rechazo de esa gestión en particular, pero nunca utilizar razonamientos propios de un caso (en su gran mayoría también no muy felices como vimos), en cuanto no se cumplieron ciertos requisitos establecidos en el ordenamiento, para con ello afirmar que dado que todo documento en el que conste una obligación a cargo de fondos públicos requiere de refrendo (sic) no cabe el proceso monitorio, en ningún caso, contra un ente público. Es decir, la gravedad del hecho está en que, se impide al particular acceder a una vía y mecanismo jurisdiccional en general (para todos los casos), porque a través de ella todo documento requiere de un trámite administrativo previo. Se niega el acceso a la justicia en manos de los Tribunales porque esos documentos tienen un trámite especial de pago. Bajo ese argumento, tampoco cabe el proceso ejecutivo contra un ente público, pues todo documento que comprometa fondos públicos requeriría de un eventual refrendo.

Ahora bien, no obstante todo lo dicho parece ser que es ese el criterio que impera en la jurisdicción civil de hacienda, pues en una resolución aún más reciente, esta vez la Sección Primera integrada prácticamente por la totalidad de sus titulares (No 175-94 de las 9:10 hrs del veintidós de junio de 1994), reiteró el criterio en forma tajante adoptando en forma

sucinta los mismos argumentos esbozados por la ya comentada. Agrega tan solo un argumento adicional del que lamentablemente tampoco participamos, pues afirma que *"... el artículo 301 de la Ley General de la Administración Pública prohíbe a la Administración confesar en su perjuicio y tampoco existe la confesión cuando hay rebeldía"*. Lo dispuesto en el 301 es efectivamente cierto, lo que resulta concordante con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo; sin embargo, nuestra discrepancia se sustenta en el hecho de que se asimila la confesión a los efectos del proceso monitorio, cuando en verdad son dos institutos sustancialmente diferentes, según se desprende con claridad del mismo artículo 502 del Código Procesal. Además, bajo este argumento, el poseedor y propietario del documento no ejecutivo en el que consta la deuda, tampoco podría hacer valer su derecho en un proceso ordinario, pues tampoco allí podría confesar en su contra, ni funcionario alguno reconocer que el crédito existe, y que además es válido y exigible, no obstante que en el ordinario, sí podría declararse en rebeldía a la Administración si no contesta en su momento oportuno, tomando como ciertos lo hechos de la demanda. Y si los propulsores de aquella tesis oficialista rechazaran la anterior hipótesis, habrían de aceptar que si el servidor puede hacerlo (como informe o prueba testimonial) en el ordinario, nada impide para que lo haga en el monitorio; mas simple, si en un proceso ordinario civil de hacienda, aquel presunto acreedor puede encontrar protección a

su derecho (tal y como ha ocurrido en muchísimos casos), por qué no hacerlo en el monitorio.

a-2: Resoluciones Judiciales Firmes.

Por último, en cuanto a estos títulos judiciales en sentido estricto, hay que decir que en algún momento ha causado confusión lo que dispone sobre terceros el mismo inciso 5o del artículo 438 cuando señala: *"Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan, a cargo de un tercero o de un parte, la obligación de pagar una suma líquida..."* , pues se afirma que un extraño al proceso no puede ser condenado sin ser oído, pero lo cierto es que no se refiere la ley al caso de tercero ausente del proceso, sino a aquel que sin ser parte principal participa en el debate o en alguna fase de él, resultando eventualmente condenado en alguna suma de dinero. De manera que, puede tratarse por ejemplo, de una condenatoria en costas o lo referente a honorarios cobrados en vía incidental. Realmente debe reconocerse que esta especie de título se aproxima mucho a una vía de apremio directo ya en la fase de ejecución.

b.- Títulos Judiciales Mixtos.

En cuanto a los títulos judiciales que llamamos "mixtos", tenemos los señalados en los incisos 3) y 4) del numeral mencionado, a saber:

"3) El documento privado reconocido ante la autoridad

judicial competente, o declarado reconocido en rebeldía de la parte.

4) La confesión judicial hecha por la parte y la que se tenga por prestada en rebeldía de la misma parte"

En estas dos hipótesis si bien es cierto el órgano judicial interviene en la formación del título, no es por su mera participación o declaratoria que él se constituye, sino que en ambos supuestos, la intervención judicial está precedida de una actuación de parte, que se plasma ya sea en un documento privado aceptado luego por el deudor como v lido y cierto, o bien, con la aceptación expresa del crédito pendiente efectuado ante la autoridad judicial. En los dos casos, la autoridad judicial aparece de alguna forma como fiscalizadora u homologadora del acto realizado por la parte,con lo cual imprime certeza y ejecutividad a la acción efectuada, siempre y cuando, claro está, cumpla con los presupuestos de liquidez y exigibilidad. Nótese que la constitución del título mismo - insistimos- no viene dada por la autoridad judicial en forma unilateral, sino que se origina en el seno propio de los particulares interesados; en un caso, plasmado en un documento, en el otro, en la declaración (expresa o ficta) de la parte. De allí que no sea un título judicial propiamente dicho, tal y como quedó señalado líneas arriba.

Tanto la confesión judicial como el reconocimiento del documento privado se realizan bajo la misma forma, todo de conformidad con los artículos 245, 338, 379 y 388 del C.P.C. En

los dos casos, ha de entenderse que la resolución que declara el reconocimiento del título por incomparecencia de la parte (confesión ficta y reconocimiento en rebeldía) es un auto y no una sentencia como en algún momento se ha dicho. Lo particular aquí es que para ambos se limita la posibilidad de defensa, pues no se permite al ejecutado desvirtuar los motivos que fundamentaron la rebeldía, al menos en el proceso ejecutivo, pues podrá acudir luego si lo desea, al proceso ordinario a dilucidar ese punto específico (artículo 444 del CPC). Y lo que se da es una limitación en ese sentido, pero nunca una supresión de la defensa, pues resulta obvio que el demandado sí puede oponer cualquier otra excepción a la obligación.

En cuanto a la confesión judicial hecha por la parte, es necesario precisar un detalle importante, aplicable en aquellos procesos en los que interviene como demandado (deudor) un ente público o el Estado, propio de la materia civil de hacienda, pues ha de recordarse que la Administración Pública en general, a través de sus funcionarios, no puede confesar en su perjuicio, de tal forma que las declaraciones o informes que rindan sus representantes o servidores deberán ser tomados como testimonios para todo efecto legal, según lo disponen los artículo 301 de la Ley General de la Administración Pública y 54 de la Ley Reguladora Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así las cosas, esta disposición del artículo 438 inciso 4) no puede ser aplicable para aquellos casos en los que el Estado o un ente público menor figure como demandado en carácter de virtual deudor. Consideramos además que esta misma

limitación para que el funcionario confiese en perjuicio de la Administración Pública, alcanza por efecto extensivo y mayoría de razón al "Interrogatorio de las partes", instituto que obviamente es distinto del anterior, pero con similares o idénticos efectos, según lo señala el artículo 336 del mismo Código Procesal Civil. De allí que si un servidor público no puede ser llamado a confesión en perjuicio de la Administración Pública, tampoco pueda ser llamado a declarar (art. 333 idem) con iguales efectos contra el órgano u ente público.

B- TITULOS EXTRAJUDICIALES.

a- Los Extrajudiciales Negociales.

En cuanto a los títulos extrajudiciales, encontramos en primer término los de **formación "negocial"**, entendiendo por ellos los suscritos, perfectos y válidos sin la necesaria participación de la autoridad judicial, y cuyo origen (al menos en una fase primaria en la que opera la iniciativa), está dado siempre en el seno de la voluntad privada, es decir, nace entre los particulares, aunque posteriormente requieran de la participación de una autoridad pública o bien, de un sujeto privado en ejercicio de una función pública. Es por ello que dentro de estos (los extrajudiciales negociales) podemos distinguir dos grupos: aquellos realizados con participación de un sujeto público o privado, pero siempre en ejercicio de potestades públicas (distintas de la jurisdiccional por supuesto) que denominamos **negociales de orden público**, y los que sin requerir de esta participación, nacen, se perfeccionan y se hacen valer, con la sola afluencia de la voluntad privada, en donde uno de ellos se constituye deudor y se compromete a pagar suma líquida, voluntad a la que la ley otorga ejecutividad. En otros términos, son aquellos en cuya formación solo participan sujetos privados, los que esencialmente se reducen a las partes relacionadas con el nacimiento de la obligación (o únicamente del deudor cuando sólo es necesaria su presencia, tal y como ocurre en multiplicidad de casos), lo que precisamente nos lleva a su denominación: **negociales de orden privado.**

Es preciso insistir en que dentro de los negociales de orden público también incluimos aquel grupo de documentos a los que se aludió líneas arriba, en los que además de la necesaria participación de los sujetos principales particulares, requieren de la intervención de un sujeto privado en ejercicio de funciones públicas (como es el caso de nuestros Notarios). Nótese que en los títulos extrajudiciales -- negociales de orden público --, se da una relación bipolar; unas veces integrada por las partes y un ente público, otras, por las partes y un privado en ejercicio de funciones públicas. En ambos supuestos opera una formación del título en coparticipación y por ende, consideramos su origen de naturaleza compleja.

a-1: Negociales de Orden Público.

- Testimonios de Escritura Pública y Asientos Registrales

Entre los negociales de orden público con participación de una autoridad pública, podemos citar los contenidos en los incisos 1) y 2) del artículo 438, referidos al *"... testimonio de una escritura pública debidamente expedido o , en su caso , la certificación, de ese testimonio y de que se encuentra pendiente de inscripción, la cual no podrá negarse a dar el notario autorizante o el Registro Público correspondiente"* y a *"Las certificaciones de asientos del Registro Público,*

siempre que en ellas conste que las inscripciones certificadas no están canceladas o modificadas por otro asiento" . En los dos supuestos, se trata de documentos susceptibles de inscripción en el Registro Nacional (que no exclusivamente en el Público, el que tradicionalmente se ha entendido como sinónimo del Registro de la Propiedad), que si bien es cierto no se restringen a la escritura pública, puesto que podrían existir otros en posibilidad de producir iguales efectos, sí provienen generalmente, de dicha dependencia o en su caso, de un Notario Público, investido para este evento de fe pública, y por ende, capaz de imprimir publicidad al documento por él expedido.

En todo caso, es claro que en ambos supuestos resulta imprescindible la presencia de los dos presupuestos ya apuntados para todo título ejecutivo, además de los demás requisitos formales que la ley exige.

Los ejemplos más comunes de este tipo de títulos lo constituyen las certificaciones del Registro de Prendas (prenda debidamente inscrita, conforme al artículo 674 del Código Procesal Civil) y del Registro de Hipotecas (escritura de hipoteca debidamente inscrita o pendiente de inscripción de acuerdo con el numeral 422 del Código Civil en concordancia con el párrafo primero del artículo 660 del Código Procesal Civil, en el caso de que se haya hecho renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, o del artículo 663 del mismo Código Procesal Civil si no se hizo renuncia de trámites), donde dan fe del contenido y vigencia de la obligación contraída.

Dada la redacción del inciso primero de comentario, se han generado no pocas dudas en relación con el tipo de testimonios de escritura pública capaces de ocasionar ejecutividad de la obligación contraída ¿ Es ejecutivo cualquier testimonio de escritura pública, ya sea que provenga del Registro Público o tan solo de un Notario, o solo pueden serlo aquellos presentados o inscritos en dicha entidad ?. En efecto, el cuestionamiento surge a consecuencia del requisito que la disposición exige cuando señala la necesidad de que se indique que el mismo (el testimonio) se encuentra pendiente de inscripción, sin establecer en forma precisa, si la exigencia dicha cubre a todo testimonio de escritura pública, independientemente de quien lo expida (lo que abarcaría al extendido por un Notario), o si por el contrario, se refiere única y exclusivamente a las certificaciones expedidas por el Registro Nacional sobre aquellos testimonios presentados en sus oficinas, con la observación adicional de que se encuentran pendientes de inscripción, no así para los demás, con lo que se daría ejecutividad por otro lado, al testimonio expedido por un Notario aún si no se ha presentado al Registro o del todo no es inscribible. Y la discusión no resulta bizantina, pues ella nos lleva directamente a una doble alternativa, en donde hay que elegir si se acepta todo testimonio de escritura pública como título ejecutivo (siempre y cuando reúna los presupuestos ya comentados, tal y como hemos insistido) o, si en cambio, restringimos la ejecutividad únicamente para aquellos testimonios susceptibles de inscripción en el Registro. El

Tribunal Superior Primero Civil, siguiendo de alguna manera el criterio jurisprudencial de la Sala Segunda de entonces, se ha inclinado por considerar que solamente es ejecutivo el testimonio susceptible de inscripción. Así ha indicado por ejemplo en la resolución número 1172-E de las ocho horas treinta minutos del treinta de agosto de mil novecientos noventa y uno, lo siguiente:

> *"En tal normativa* (artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles derogado y 438 del Código Procesal Civil Vigente) *no aparece con tal rango ejecutivo e l documento aportado, pues se trata de un testimonio de escritura pública no inscribible en el Registro ... En este caso no se trata de un documento inscribible en el Registro que es lo que protege y sancionan las disposiciones dichas con el rango de título ejecutivo, pues el documento no reúne todos los requisitos propios para ser inscritos en e l Registro Nacional, pues las normas transcritas señalan que también puede admitirse en lugar del testimonio una certificación expedida por el Notario o el Registro, indicando de que se encuentra pendiente de inscripción. Como el documento aportado no puede enmarcarse dentro de la citada norma, el a-quo no resolvió en forma correcta, pues le confirió rango ejecutivo al documento que no reúne esas características; pues ya se ha dicho en forma reiterada en la jurisprudencia de este Tribunal que*

el rango ejecutivo al documento lo da la ley, y nunca el convenio de partes, como sucede en el caso bajo examen. Las partes no pueden crear por voluntad propia documentos con rango ejecutivo a su antojo, y no basta que el documento o contrato contenga un contrato u obligación personal de pagar una suma de dinero, y si no es título ejecutivo no puede cobrarse por la vía sumaria ejecutiva, ni hipotecaria ni simple, aunque haya un acreedor y un deudor ciertos, una obligación de pagar suma de dinero líquida o liquidable y que esta sea o pueda ser exigible".

En igual sentido pueden verse las resoluciones de la Sala Segunda Civil número 889-52; 944-63, y del mismo Tribunal Superior Civil, la número 1654- C de 1987; la 710-R de 1988; la 2092-89 y la 30-V de 1990.

Sin embargo, en la jurisdicción civil de hacienda se ha dado a través del tiempo una aceptación pasiva de los testimonios de escritura pública como títulos ejecutivos, aún y cuando no sean susceptibles de inscripción registral. En este sentido tenemos la resolución número 139 de las siete horas treinta minutos del veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y dos, que en lo pertinente expresa:

"... de acuerdo con el artículo 425 -inciso 2- del Código de Procedimientos Civiles (hoy trasladado al inciso primero del artículo 438 del Código Procesal Civil), el testimonio de una escritura pública debidamente expedida, como ocurrió en el presente

caso, es título ejecutivo; además, si la cantidad por la que se debía despachar la ejecución podía liquidarse con vista de los datos que resultan del documento base del juicio y la deuda era exigible según resulta de las propias claúsulas de la escritura pública que sirve de título ejecutivo, pues en la escritura se consignó la suma inicial mínima adeudada, ... y en la misma escritura 51 se estipuló que ella era título ejecutivo".

Por su parte, en la resolución No 3759 de las 10:10 hrs del 15 de marzo de 1988 acepta la ejecutividad de una escritura pública en la que un ente público se compromete a pagar una suma de dinero claramente determinada en favor de un Banco. Tanto el Juzgado como el Tribunal, pese al alegato de los demandados sobre la falta de ejecutividad del título, toman por buena la escritura como documento base del proceso, con fundamento en los artículos 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y 82 bis de la Ley Orgánica del Notariado.

No obstante lo anterior, y reconociendo de antemano la dificultad que existe para adoptar una u otra posición, dada la ambigua redacción del precepto señalado, parece más ajustado a derecho y más conveniente, la interpretación dada por la jurisdicción civil, pues de lo contrario, se estaría permitiendo la creación de una pluralidad enorme de títulos de variadísima índole, con la sola excusa de la protección notarial brindada a su vez por la escritura pública, lo cual iría obviamente contra el principio de reserva legal que impera

en esta materia. Admitir una tesis abierta en este campo sería precisamente derramar el contenido propio de la reserva legal para llenarlo con cualquier negocio o convenio plasmado en escritura pública a discreción de las partes. Ello no es posible siquiera con la preexistencia de uno de los denominados "contratos ley" en los que se establecen las condiciones del préstamo, pues ha de quedar claro, que tales negociaciones no pierden su naturaleza de contrato administrativo (artículo 124 de la Constitución Política), y por ende, son incapaces de crear un título de esta naturaleza. Con la posición señalada, también estaríamos excluyendo aquellos supuestos en los que se consigna en un testimonio de escritura pública, la obligación de pagar una suma de dinero (con los presupuestos básicos de la ejecutividad) pero como parte adicional del negocio jurídico, que es el único (el negocio) susceptible de inscripción, tal y como sería el caso de la compraventa de un inmueble, un arrendamiento de predio rústico o la venta de un vehículo, en el que además se establece la obligación de pagar parte del precio sin constituir con ello una garantía real. Aquí, podría pensarse, dado que se trata de un testimonio presentado o inscrito en el Registro y en el que se consigna una obligación pura y simple, líquida y exigible; que estamos frente a un título ejecutivo de conformidad con el numeral en comentario. Consideramos que con ello se incurriría en un equívoco, pues si bien es cierto el negocio principal sí está sujeto a inscripción, la obligación quirografaria como tal no es susceptible de ello, aunque conste en el testimonio que se

presentó al Registro, y al no ser inscribible, el testimonio en el que se plasma, no es título ejecutivo.
Dicho documento podrá servir de base para el respectivo proceso monitorio, pero no al ejecutivo tradicional.

- Saldos Sobre Aportes de una Sociedad.

Otro ejemplo interesante en este grupo de títulos (extrajudiciales- negociales - de orden público con participación de autoridad pública) viene dado por los testimonios o certificaciones, en los que conste su oportuna inscripción; entratándose de saldos no cubiertos en materia de 53 cuotas o aportes de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima, de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 112 del Código de Comercio.

- Cédulas Hipotecarias.

De igual forma, podemos incluir aquí, el supuesto de las cédulas hipotecarias, las que originadas en la voluntad de los particulares, requieren de la participación del Registro Nacional para su perfección, lo que les confiere su ejecutividad, según lo dispuesto por los artículos 426 frase final, 430, 431, 433 y 434 del Código Civil. Aparte del numeral 434 que les confiere el carácter de título ejecutivo al permitir el remate con base en las mismas, tenemos que el 431 les otorga el mismo rango y fuerza probatoria que al dispuesto para el testimonio de una escritura pública.

- Certificaciones por Desalmacenaje Aduanero.

Nuestro Código de Comercio agrega en su artículo 384, un caso más para este tipo de títulos, cuando otorga ejecutividad a la copia del pedimento de desalmacenaje debidamente certificada por el Administrador de Aduana o por el "Contador General de la República", en aquel supuesto en el que el agente o corredor de aduana hubiere efectuado el desalmacenaje de la mercadería propiedad de su comitente, quien ahora se niega a pagarle el importe de aquellos derechos. En este caso, la ley presume que hay convenio entre ambas partes, de modo que si el propietario de la mercadería se niega luego a pagar el importe correspondiente al agente aduanero, éste podrá cobrarle por la vía ejecutiva aportando como documento base la copia certificada a que se ha hecho mención. El numeral de cita tan sólo exige que la certificación sea expedida por el funcionario que allí se indica y especificación precisa de la suma cancelada por el agente aduanero. (al respecto puede verse la Sentencia del Tribunal Superior Primero Civil. No 1260 de las 9:05 hrs. del 31 de julio de 1984).

Esta copia certificada por funcionario público en favor de tercero (el agente), no debe confundirse sin embargo, con la certificación extendida por la Jefatura de Aduana de la cual resultan sumas dejadas de pagar al Fisco por virtud de recalificación del impuesto cancelado en su oportunidad, conforme reza el artículo 387 del mismo Código de Comercio, pues en este segundo caso, se trata de un título ejecutivo **de carácter administrativo** en favor del Estado, que él mismo expide en su favor de manera unilateral, según veremos páginas

adelante.

a-2: Negociales de Orden Público con participación de privados en ejercicio de funciones públicas.

Continuando con algunos ejemplos de los títulos extrajudiciales y negociales de orden público, podemos citar también otros en los que no participa el ente público sino el sujeto privado imbuido de potestades públicas, tal y como ocurre en algunos casos con el Notario y el Contador Público, que por sí y ante sí, de manera unilateral e imperativa, fijan los términos de la obligación para efectos del proceso ejecutivo posterior. De allí que en sentido estricto, estos no sean títulos verdaderamente negociales, pues la voluntad del deudor, en modo alguno interviene en la formación y perfeccionamiento del documento. La clasificación que de ellos hacemos obedece únicamente a aspectos didácticos o de organización de ideas, pues tampoco puede decirse que sean títulos "administrativos", ni propios de ningún otro grupo.

Aquí sin embargo, antes de continuar con cualquier otro aspecto, conviene cuestionarse sobre la muy dudosa constitucionalidad de este tipo de títulos en los que la ley transfiere de alguna forma potestades de imperio (exclusivas de la Administración Pública, por principio y de acuerdo con lo establecido en los artículos 12. 2), 59. 1) y 66 de la LGAP), a sujetos privados, que aunque investidos de funciones públicas (lo que cabalmente da fe de sus actos en el ejercicio de ellas)

no son parte de la Administración, como para permitírseles imponer obligaciones (monto, exigibilidad, intereses, condiciones y demás extremos del adeudo) en forma **unilateral**, sin el conocimiento y defensa previos por parte del deudor, que además violan el principio de igualdad constitucional consagrado en el artículo 33.

Pese a lo anterior, partiendo de la normativa aún vigente, podemos citar los siguientes ejemplos:

- Cuenta Corriente.

El artículo 611 del Código de Comercio le otorga ejecutividad a las certificaciones debidamente expedidas por Contador Público autorizado en lo referente a saldos pendientes luego de concluido el contrato de cuentacorriente. Es preciso señalar aquí el criterio reiterado del Tribunal en el sentido de que para expedir la certificación que luego servirá de base al proceso ejecutivo, es necesario el cierre previo de la cuenta corriente, pues solamente con ello es posible compensar todas las partidas hasta la cantidad concurrente, y establecer así el saldo adeudado. Como lo señala **Joaquín Garrigues** : *"Para que haya contrato de cuenta corriente en sentido técnico se precisa un pacto específico que excluya la disponibilidad aislada de los créditos, sea por vía de pago, sea por vía de compensación, y aplace su liquidación hasta el momento del cierre de la cuenta... En este caso, y sólo en este caso, existe un contrato de cuenta corriente. El efecto esencial del contrato de cuenta corriente es la fusión de todos los créditos*

en un crédito único resultante del saldo final" (Contratos Bancarios, Madrid, 1968, pag. 119. Entre muchas de las resoluciones judiciales que han reiterado este criterio, pueden verse las sentencias 3673 de las 9:40 hrs. del 14 de enero de 1988 y la 423-93 de las 9:55 horas del 19 de agosto de 1993).

También importa recordar la diferencia básica entre el contrato de cuenta corriente mercantil común y el contrato de cuenta corriente bancaria. El primero consiste en remesas recíprocas de los pactantes, en propiedad, constituidas por sumas de dinero, títulos valores o mercaderías sin aplicación a empleo determinado, con el deber de hacer los créditos y los débitos correspondientes, de modo que a la fecha prevista o de cancelación legal, se determine el saldo deudor a cargo de uno u otro de los negociantes. Como bien lo ha señalado el Tribunal Superior Primero Civil:

"CONSIDERANDO I. Se está en presencia de un contrato de cuenta corriente, cuando las partes se obligan de modo recíproco a no exigir aisladamente los créditos anotados en la cuenta y a pagar periódicamente, o al término del contrato el saldo o diferencia entre las partidas del Debe y del Haber que resulta a cargo de cualquiera de ellas... es un contrato sui géneris, consensual, no formal y bilateral, caracterizado por un acto que, a base de la recíproca concesión de créditos, aspira a mantener unidos los elementos integrantes de la cuenta, sin posibilidad de que sus partidas puedan ser hechas efectivas hasta el cierre y liquidación previstos y determinados del saldo final. Se impone a las partes una conducta futura, en

efecto, a regular y liquidar en una forma determinada las eventuales relaciones crediticias que entre ellas puedan constituirse, sin originar concretas obligaciones de dar hacer o no hacer inmediatamente exigibles. Es también el contrato de cuenta corriente un contrato de duración o tracto sucesivo establecido para exigir las relaciones de las partes durante un período de tiempo mas o menos largo." (ver resolución número 261 de las 8:40 hrs. del 23 de marzo de 1983. En igual sentido pueden verse también las resoluciones del mismo Tribunal número 2436- F de las 9:55 horas del 13 de noviembre de 1987; la número 1167 de las 8:10 horas del 2 de julio de 1985).

De manera que el contrato de cuenta corriente mercantil común se caracteriza por tres elementos esenciales: en primer término, por la circunstancia de que ambos contratantes asumen simultánea y recíprocamente la condición de deudores y acreedores; la segunda, por el hecho de que el saldo contra uno de ellos, si lo hubiese, se determina luego de compensar los créditos y las deudas de cada una de las partes (*"la esencia del contrato se encuentra en una recíproca concesión de crédito que se hacen los contratantes al consentir en que se aplace l a exigibilidad de los créditos aislados"* señala Garrirres, op. cit., pag. 120) ; de manera que la compensación de créditos y deudas, o del "débito" y el "crédito" equivale a la "liquidación de la cuenta corriente" (sobre estos dos aspectos puede verse la resolución del Tribunal Superior Primero Civil número 392 de las 8:20 hrs. del 19 de mayo de 1978); y en tercer lugar, porque en la cuenta corriente, el

cuentacorrentista sólo puede girar sobre los fondos efectiva y definitivamente acreditados a su cuenta o contra créditos concedidos por el Banco, tal y como lo dispone el artículo 619 del Código de Comercio. (sobre este tercer elemento puede verse la sentencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, número 3976 de las 8:30 hrs. del 14 de julio de 1988).

Por otro lado, el contrato de cuenta corriente bancaria, es un negocio por el cual un banco recibe de una persona física o jurídica dinero o valores acreditables de inmediato en calidad de depósito, o le otorga un crédito para girar contra dicho depósito (artículo 612 del Código de Comercio). Sobre la diferencia de ambos contratos puede verse la resolución No 3673 de las 9:40 hrs. del 14 de enero de 1988, de la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Y en especial sobre el concepto de cuenta corriente bancaria, pueden verse las resoluciones del mismo Tribunal número 128-92 de las 11:40 hrs. del 28 de enero de 1992 y la 423-93 de las 9:55 hrs. del 19 de agosto de 1993).

De manera que entre el contrato de cuenta corriente común y el contrato de cuenta corriente bancaria, pueden extraerse según lo dicho, las siguientes diferencias: en el contrato de cuenta corriente mercantil es esencial, el dato de la recíproca concesión de crédito entre los contratantes, que consienten en aplazar la exigibilidad de los créditos aislados, mientras que en la cuenta corriente bancaria la concesión de crédito cuando

existe, es unilateral, ya que si la cuenta corriente nace de un depósito es sólo el depositante quien concede crédito al Banco, y si nace de una apertura de crédito es sólo el Banco quien concede crédito al cliente. En segundo lugar, el contrato de cuenta corriente común produce la indisponibilidad de los créditos anotados hasta que llegue el momento del cierre, en el sentido de que ninguno de los contratantes puede reclamar separadamente el pago de un asiento hecho a su haber, en tanto que en la cuenta corriente bancaria, el cliente puede disponer en cualquier momento de las sumas resultantes de su crédito. Por último, en la cuenta corriente mercantil la compensación entre la masa de los créditos y la de las deudas sólo se produce en el momento del cierre de la cuenta, para dar lugar a un saldo exigible; en cambio, en la cuenta corriente bancaria los saldos activos se compensan con los saldos pasivos tan pronto como se producen los supuestos legales de la compensación de crédito y deuda. (Para una mayor ampliación sobre las diferencias entre ambos contratos, puede verse Garrigues (Joaquín): op. cit. , pag. 120 y siguientes)

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de nuestros Tribunales ha otorgado ejecutividad irrestricta a las certificaciones expedidas por Contador Público en cuanto a los sobregiros de cuenta corriente bancaria, asimilándola por analogía, a la cuenta corriente común, lo que pareciera violatorio del principio de reserva de ley tantas veces comentado. Sobre ello se ha creado ya algún grado de conciencia, que se refleja en el hecho de que recientemente se

presentara un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa tendiente a crear un inciso 7) al artículo 438 del C.P.C. en el que expresamente se da ejecutividad a las certificaciones sobre saldos en contratos de sobregiros bancarios (véase el proyecto número 11.753 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" del viernes 17 de setiembre de 1993). Por lo pronto se mantiene la asimilación entre ambos admitida por nuestros Tribunales.

- Tarjetas de Crédito.

La conceptualización de los contratos comentados y el detalle de sus diferencias, también nos permite fundamentar con mayor firmeza nuestro criterio en cuanto al moderno fenómeno de las tarjetas de crédito que han alcanzado desde algún tiempo las esferas judiciales. En efecto, la naturaleza jurídica del contrato de tarjeta de crédito, es un aspecto que ha provocado diversos puntos de vista, las que por el objeto de nuestro trabajo no podemos ahondar, razón por la cual nos limitaremos a establecer nuestro punto de vista, luego de examinar la posición adoptada por nuestra jurisprudencia. El criterio que se adopte es determinante, pues dependerá de ello el otorgamiento o no de la ejecutividad a tales documentos.

Nuestro Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, ha aceptado en forma tácita la caracterización de la tarjeta de crédito como cuenta corriente, lo que ha permitido imprimirle ejecutividad a las certificaciones de contador público autorizado sobre los saldos adeudados una vez

finiquitada la cuenta. En algún momento se ha dado incluso declaración expresa de parte del Tribunal en cuanto a su ejecutividad. Así, en la resolución número 518 de las 15:10 hrs. del 30 de setiembre de 1982, señaló la Sección Segunda:

> *"Redacta el Juez Rodríguez Vega; y CONSIDERANDO: II.- Que este Tribunal, mediante un cuidadoso estudio de l a realidad jurídica del tipo de contratos que se estila suscribir para la utilización de las llamadas "tarjetas de crédito"...ha mantenido la tesis de que estos últimos documentos constituyen verdaderos títulos ejecutivos, si se otorgan con las formalidades de ley,- útiles para servir de base en la vía judicial ejecutiva-. El fundamento legal se encuentra precisamente en el artículo 611 en relación con el 602, ambos del Código de Comercio; siendo que en base a ello y tratándose en la especie de un contrato de cuenta corriente, la certificación de un Contador Público Autorizado, sobre el saldo deudor, constituye título ejecutivo a fin de hacer exigible la obligación."*

El Tribunal Superior Civil por el contrario, (pese a que en algún momento también admitió la ejecutividad de las certificaciones de Contador Público expedidas en esta materia, al respecto véanse las resoluciones No 392 de las 8:20 hrs. del 19 de mayo de 1978 y No 4794 de las 16:05 horas del 16 de junio de 1981), ha ratificado su criterio jurisprudencial en el

sentido de que las certificaciones mencionadas no pueden tratarse como si fuesen consecuencia de una cuenta corriente, y por ende, los saldos que resulten de las tarjetas de comentario, no tienen por esa vía ninguna ejecutividad. Ha indicado el Tribunal Superior Primero Civil lo siguiente:

> *"Reiteradamente se ha resuelto que el contrato de tarjeta de crédito no es contrato de cuenta corriente, porque no se dan las condiciones que exige el artículo 602 del Código de Comercio; en el contrato de cuenta corriente, una de las partes remite a la otra y recibe de ella cantidades de dinero, mercaderías u otros efectos de tráfico mercantil, compensando lo remitido con lo recibido y si al final o en un determinado momento resulta saldo en contra de alguna de las partes, deben cancelarse de inmediato y ese saldo, certificado por un contador público, constituye título ejecutivo, conforme las disposiciones del Código Mercantil; diferente a la situación respecto de la tarjeta de crédito, que no se rige por el contrato de cuenta corriente, sino que es un contrato atípico y complejo en el que las partes no remiten y reciben para compensar y ante tales circunstancias el saldo que exista en determinado momento, certificado por un contador público, no es título ejecutivo." (en igual sentido pueden verse las resoluciones del mismo Tribunal No 378 de las 8:10 hrs. del 30 de abril de 1980 y*

2436- F de las 9:55 hrs. del 13 de noviembre de 1987)

Por su parte, el Tribunal Superior de Cartago, teniendo noticia de las distintas posiciones sostenidas sobre el tema y luego de transcribir algunos de esos fallos y criterios doctrinales, estimó que la tesis más acorde con nuestra normativa es la civil, por lo que también negó ejecutividad a la tarjeta de crédito. En lo que interesa señaló el Tribunal en la sentencia número 457-90 de las 10:10 hrs. del 16 de noviembre de 1990, bajo la redacción del Juez **Carlos Manuel García Cabezas**, quien al transcribir parte de la sentencia del Tribunal Superior Primero Civil de San José, No 377 de 1980, ya citada, indica:

> *"IV.- Vemos entonces que surgen varias relaciones contractuales independientes pero relacionadas. a) Entre entidad crediticia y tarjetahabiente. Dicen tratarse de un contrato de apertura de crédito. No es un pacto de cuenta corriente o cuenta bancaria. Sino un crédito abierto reutilizable, por una suma fija y fecha de cancelación preestablecida. Además el usuario no está intercambiando remesas, ni de los cortes mensuales puede resultar acreedor. - Al tarjetahabiente se le concibe como eventual deudor. si bien puede que no utilice el crédito, lo que señala que la tarjeta no presupone un tráfico económico necesario, sino posee un factor de disponibilidad del crédito el cual, agregamos,*

siempre está limitado a un tope. ese cuantum lo fija la entidad emisora; es posible volver a concederlo e incluso ampliarlo si el usuario se ha hecho acreedor a ello. Señala el margen de riesgo que se puede permitir la entidad. La apertura de crédito es un contrato típico bancario en otros países. Aquí lo debemos calificar como atípico... VI.- En síntesis, de lo expuesto se desprende que la tarjeta de crédito sólo puede operar a través de esa triple negociación, con lo cual nos alejamos cada vez más del concepto típico del contrato cuenta corriente... No basta que un contador público autorizado diga que certifica un contrato de cuenta corriente; es indispensable que el negocio jurídico responda a la figura concreta. Los saldos deudores resultado del incumplimiento al contrato de tarjeta de crédito no puede equipararse al pacto de cuenta corriente ya que su naturaleza jurídica es distinta y en consecuencia el título ejecutivo que hace del artículo 611 del Código de Comercio carece de vigencia en autos por lo que debe denegarse la vía sumaria de cobro..."

Al respecto consideramos que, pese a la aceptación tácita que ha venido haciendo el Tribunal sobre la ejecutividad de los saldos de tarjetas de crédito certificados por un contador público, no puede hablarse al momento de caracterizar este particular instituto, de un simple contrato de cuenta

corriente, ni mercantil común ni bancario, pues se trata realmente de una relación jurídica compleja y tripartita, en la que se dan relaciones jurídicas diversas y normalmente, tres tipos de contratos, los que a su vez forman una unidad: uno, entre la entidad emisora y el usuario; otro, entre el proveedor adherido y la entidad que emite la tarjeta y un último, entre el proveedor y el usuario de la tarjeta.

Para nuestros efectos, importa ante todo la relación entre usuario y entidad emisora, pues es de allí donde normalmente surge el conflicto que genera a su vez el proceso ejecutivo correspondiente. En ese sentido consideramos que se trata de una figura muy próxima al contrato de crédito, que en modo alguno puede asimilarse a una cuenta corriente, ni común ni bancaria, y que reúne los tres elementos siguientes: **a)** la ausencia de un pago inmediato al momento de realizarse el negocio jurídico que relaciona al titular usuario con el proveedor; **b)** la innecesaria provisión de fondos por parte del titular- usuario en poder de la entidad emisora delegataria de la deuda y garante de pago genérica, y **c)** el aplazamiento del pago efectivo por el usuario a la entidad emisora y de ésta al proveedor (sobre la naturaleza y características de la tarjeta de crédito, puede verse la interesante obra de **Muguillo (Roberto A.)**: Tarjeta de crédito. Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 1985, pag. 53 y siguientes). Este criterio sobre la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito, ha sido el adoptado incluso por nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha señalado que:

"... Así, habrá de observar, en primer término, que la tarjeta de crédito representa un negocio jurídico complejo. En la unidad configurada por él, convergen una serie de relaciones jurídicas diversas, donde los vínculos que unen a sus respectivos intervinientes están gobernados por una regulación propia, y presentan una naturaleza jurídica autónoma e independiente." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. No 81 de las 15:00 hrs. del 20 de mayo de 1992)

Y resulta aún más interesante el criterio vertido por la propia Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, la que según dijimos, ha venido admitido en forma generalizada, la ejecutividad de estos documentos. En su momento, señaló el referido Tribunal:

"Redacta la Juez Ferrero Aymerich; y,

CONSIDERANDO:

(...) ***VIII-)*** *Que en razón de lo manifestado es de fácil l comprensión, que el negocio de la tarjeta de crédito* ***no es más que la simple concesión de un crédito, para el usuario que califica dentro de sus regulaciones****. Su uso, como crédito inmediato que es, es equivalente al hecho de que el usuario se presente a las oficinas del Banco a solicitar dinero y se le entregue en el acto para la compra del bien o servicio que necesite y, consecuentemente, eso*

apareja el pago de algún accesorio, ya que el servicio no es prestado por la institución como una gratuidad sino a cambio de una ganancia en su giro comercial que se materializa además, con la captación de réditos". (Resolución No 685-92 de las 10:00 del 21 de julio de 1992 . El subrayado no es del original)

La redacción que en este aspecto específico se suscribió por unanimidad, es claro, y sobre él huelgan comentarios. Está clara la naturaleza jurídica dada por el Tribunal a la tarjeta de crédito, desvirtuando a su vez el presunto carácter de cuenta corriente, que por supuesto no es. Nótese que en ella, no se gira sobre un depósito previo, y lo que se da, tal y como se ha reiterado, es un crédito, en el que además no hay remesas recíprocas. Se ha querido ver este contrato, como un depósito que el banco efectúa a favor del usuario, y que a su vez coloca en la cuenta de su tarjeta, lo cual no es del todo acertado, pues de ser así, una vez consumido el monto específico por el que se dio el préstamo y depósito, se finiquitaría la relación negocial, lo que no sucede con la tarjeta en la realidad, pues esta mantiene un monto máximo reiterativo e indefinido, que puede ser utilizado en forma total o parcial.

Así las cosas, está claro a nuestro modo de entender, que si la tarjeta de crédito no es un contrato de cuenta corriente, los saldos que operen en favor de la entidad emisora una vez concluida la relación negocial, no pueden certificarse con

carácter de título ejecutivo. En este sentido es revelador el hecho de que los propios bancos estatales al momento en que suscriben una contrato de esta naturaleza, se hacen respaldar por una letra de cambio, ¿ por qué hacerlo si la misma tarjeta genera un título ejecutivo ?. Consideramos que el documento en que se haga constar el saldo en favor del ente, conjuntamente con el contrato suscrito y los respectivos comprobantes de compra ("baucher"), a lo sumo y con algún grado de dificultad, pueden servir todos en conjunto, como base de un proceso monitorio, de conformidad con el artículo 502 del Código Procesal Civil (dificultad, pues no se haría constar el crédito, su liquidez y exigibilidad por medio de un solo documento, lo que desvirtuaría ese especial proceso), o para ser reconocidos por la parte ante la autoridad judicial de acuerdo con el artículo 438 inciso 3) del mismo Código de Rito. Como lo señala Muguillo, con quien coincidimos en este punto:

> *"... por "título" entendamos no un único instrumento, sino e l conjunto de elementos aportados a la causa para probar el crédito que se reclama. Así el contrato de adhesión nos marcará l a exigibilidad de la deuda a través de sus claúsulas de pagos mensuales, mientras que la existencia, liquidez y también s u exigibilidad quedarán conformadas a través de sus "cupones" firmados y su sumatorio en la cuenta-liquidación que recoge resumidamente el total de la efectiva utilización del crédito por el usuario ejecutado "(Op. Cit. pag. 151 y ss.)*

Sobre este aspecto sin embargo debe reconocerse que para el monitorio existiría obstáculo jurídico, pues en el mismo se parte de que el documento en sí mismo se basta para establecer la deuda líquida y exigible, sin necesidad de proceder a análisis posteriores y a complementación documental; en tanto que para el reconocimiento judicial de tales documentos, tenemos que no se da en forma clara y simple la promesa pura de pagar suma líquida y exigible, pues tal conclusión debe extraerse de la documentación completa. De considerarse inaccesible estas dos vías no queda otra alternativa que remitir a las partes al proceso declarativo, lo que sin duda, resulta engorroso y sumamente lento para los interesados. En virtud de ello, y con el afán de ajustar la normativa patria a la evolución rápida y constante (sobre todo de nuestra economía) consideramos que en esta materia, si bien no es posible acudir a la vía ejecutiva directa, sí debe darse alguna amplitud en las interpretaciones de los demás institutos, con el objeto de no entrabar el tráfico mercantil manejado cada vez más por el "dinero plástico", sin que por ello se pueda, obviamente, violentar la legislación positiva. Por lo demás solo queda agregar que las Alcaldías Civiles de Hacienda han adoptado ya nuestra tesis en este aspecto, como se refleja por ejemplo en las resoluciones que han comenzado a rechazar este tipo de títulos como ejecutivos mediante rechazo ad portas (como es el caso entre muchas de la Resolución de la Alcaldía Primera de las ocho horas treinta minutos del 1 de julio de 1994); en sentencia sin oposición (como ocurrió en ese mismo

Despacho con la sentencia, entre otras tantas, de las 8:00 hrs. del 4 de julio de 1994), y en sentencia con oposición, tal y como aconteció, a manera de ejemplo, con la sentencia de la misma Alcaldía Primera No 1369 de las 10:13 hrs. del 23 de junio de 1994 (expediente número 7432-93 del BCR contra J.L.N.B. y otro), de la que conviene rescatar la caracterización jurídica que de ellas se hace, y en donde se ratifica una vez más la naturaleza que le hemos atribuido a ellas y nos proporciona con gran claridad nuevos elementos diferenciadores, para lo cual el señor Alcalde, licenciado Ronaldo Henández H., se apoya en las tesis de grado tituladas : "La Tarjeta de Crédito. Su Aspecto Jurídico" y "Proyecto de Ley Para la Regulación de la Tarjeta de Crédito", ambas de la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Al respecto señala el distinguido funcionario judicial:

> *"Viene a representar pues, un contrato innominado y sui géneris, viene a ser un negocio jurídico complejo, formado por dos institutos: 1.- un contrato de crédito de uso personal (en su modalidad de condiciones generales de la contratación o contrato de adhesión) y 2.- un acto de novación pasiva de una obligación (modo extintivo y a la vez traslaticio de una obligación). Es decir, es un contrato mediante el cual, una entidad crediticia, concede un crédito rotatorio (revolving credit), de cuantía y plazos determinados, prorrogables indefinidamente a una persona determinada, con el fin de que ésta lo*

utilice en establecimientos afiliados (proveedores). De esta manera, no existen remesas favorables al tarjetahabiente y en la apertura de crédito móvil no es la posibilidad de comprarse recíprocamente y cancelarse después, sino la disponibilidad puesta a favor del usuario, misma que es autónoma y tiene un valor que prescinde de la efectiva utilización de la suma, es decir, la disponibilidad es anterior a la utilización, que viene a representar un hecho autónomo respecto a la apertura del crédito, y crea una nueva y distinta relación entre el usuario de la tarjeta y la entidad crediticia"

-Propiedad Horizontal.

Por otro lado, continuando con los ejemplos de este tipo de títulos, tenemos que el artículo 32 de la Ley de Propiedad Horizontal otorga ejecutividad a las certificaciones extendidas por el administrador del edificio, debidamente refrendadas por contador y autenticadas por abogado, en lo concerniente a gastos comunes del condominio no cubiertos por los propietarios.

- Almacenes de Depósito.

A su vez, en materia de Almacenes de Depósito, el artículo el artículo 33 párrafo 2o de la Ley General de la Materia (No 5

del 15 de octubre de 1934 aún vigente) le da ejecutividad a las certificaciones extendidas por el Notario Público sobre el saldo en descubierto para la materia de depósitos, luego de efectuado el remate de la prenda correspondiente que él mismo dirigiera.

- Peritajes en Materia de Seguros.

También cabe dentro de esta tipología aquel documento sobre la valoración de daños efectuada por un perito para efectos de cobrar el seguro suscrito con el Instituto Nacional de Seguros, luego de acaecido el siniestro, siempre que la decisión del perito se haya hecho constar ante un notario, pues caso contrario, será preciso que el perito reconozca su firma y la verdad del documento (artículo 38 de la Ley No 11 de 2 de octubre de 1922). La disposición no aclara ante quien se debe realizar el reconocimiento de la firma y la verdad del documento, pero consideramos que debe efectuarse ante una autoridad judicial, en cuyo caso, el título emanado, no sería del grupo bajo análisis, sino de los catalogados como judiciales y mixtos.

a-3: Títulos expedidos por particulares. **Inconstitucionalidad.** Dentro de este grupo podemos incluir también aquellos títulos en los que la ley permite a un particular común certificar el adeudo correspondiente a efectos

de su cobro judicial. En estos supuestos, se trata de **un sujeto privado ordinario**, que sin poseer siquiera funciones de orden público, es capaz por sí mismo (sin necesidad de otro funcionario o sujeto privado en función pública) y de manera **unilateral** (sin el consentimiento del deudor), de expedir la certificación relativa al proceso ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, del artículo 232 del Código de Trabajo que permite a los directores de instituciones médicas privadas expedir certificaciones con carácter ejecutivo, en las que se consignan adeudos por servicios médicos otorgados con motivo de accidentes laborales en los que el patrono carezca del seguro de riesgos profesionales. Para estas hipótesis, nos atrevemos a afirmar la abierta inconstitucionalidad de la norma que así lo disponga, en cuanto confiere potestades de imperio a un particular, el que sin aviso previo y sin consentimiento del deudor, extiende un documento capaz de afectar seriamente los derechos subjetivos de un tercero, lo que obviamente viola entre otros, el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución, desde que un igual no puede imponer - ni siquiera con autorización legal - obligaciones o sanciones por su mera voluntad a un tercero. Aquí hay que recordar, que para la creación de un título entre particulares, se requiere, además de la ley base que le otorgue ese carácter, del consentimiento del deudor, por lo que no puede un sujeto privado, imponer por sí y ante sí, una obligación de esta naturaleza. La concreción y ejecución **unilateral** de obligaciones dinerarias, constituye un privilegio exclusivo de la Administración Pública, en

ejercicio de sus potestades públicas y de imperio, que escapan en todo, a la posibilidad de acción de un particular. (sobre la titularidad de potestades administrativas, véase **DE LA CUETARA** (JUAN MIGUEL): Las Potestades Administrativas. Madrid, España, Primera Edición, Tecnos S.A., pag. 56 y siguientes).

Esta grave violación de nuestra norma fundamental, ya fue declarada incluso para un caso muy similar al de comentario, cuando se anuló del ordenamiento jurídico vigente el artículo 13 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, que facultaba al gerente de ese tipo de agrupación a expedir certificaciones con carácter ejecutivo acerca de los adeudos que su representada tuviera a su favor (véase el voto de la **Sala Constitucional** No 998- 93 de las 15:54 hrs. del 23 de febrero de 1993).

Dentro de estos, tenemos también el caso del productor de arroz que habiendo entregado el producto al beneficiador, no recibe los adelantos del precio correspondientes dentro de los ocho días posteriores a la entrega. En ese caso, el recibo del grano constituye título ejecutivo, en cuyo proceso la ley sólo permite las excepciones de pago y prescripción (artículos 27 de la Le No 7014 de 28 de noviembre de 1985 y 57 del Reglamento de dicha ley, emitido por Decreto Ejecutivo número 17032- MAG- MEC de 2 de mayo de 1986). En cuanto a este último ejemplo interesa destacar que sola y únicamente se establece la ejecutividad para el incumplimiento en el pago de los adelantos respectivos, no para aspectos ajenos a dicha materia, tal y como acertadamente lo señaló el Tribunal Superior. Sección Segunda

en la resolución número 491-89 de las 14:55 hrs. del 2 de noviembre de 1989. Empero, hay que reconocer que este caso se aproxima mucho a un título negocial privado, en donde el recibo de arroz (debidamente firmado) hace las veces de factura a crédito.

Caso semejante a los indicados, es el que señala el art. 385 del Código de Comercio, cuando otorga ejecutividad a la factura extendida por el transportista en favor del agente de aduanas, para el caso de que éste hubiese transportado mercaderías propiedad de su cliente. Aquí se trata de un tercero privado que de alguna manera, extiende un documento con carácter ejecutivo en favor del agente y contra el propietario de la mercadería transportada.

a-4: Negociales Privados.

En lo referente a los títulos negociales privados (contemplados todos en la remisión abierta que hace el inciso 6o del artículo 438 del CPC), diremos que son todos aquellos que suscritos por la o las partes, sin ningún otro requisito u homologación posterior, adquieren ipso facto el carácter de título ejecutivo por así disponerlo en forma expresa la ley correspondiente. La ley reviste de ejecutividad al convenio suscrito por las partes, en el que uno (deudor) se compromete a pagar en favor del otro (acreedor) una suma determinada de dinero. Nótese entonces que en estos, juega un papel primordial la aquiescencia del deudor, quien participa del convenio y rubrica el documento. Este es el caso por ejemplo de la letra de cambio, el cheque, el pagaré , la factura, etc, a los que el

Código de Comercio otorga la ejecutividad en forma clara. La letra de cambio lo es por disposición del artículo 787 del Código de referencia; el cheque a tenor del artículo 815 del mismo Código; el pagaré según lo establecido en el artículo 802 en su inciso d); la factura a crédito por compraventa de acuerdo con el artículo 460 del mismo Código de Comercio y la prenda sin inscribir (y como tal, un documento meramente privado), según el artículo 676 del Código Procesal Civil. En el presente trabajo no pretendemos abordar los diferentes tópicos de estos títulos, que son materia de otro campo del derecho y que rebasan en mucho las expectativas de esta investigación. No obstante, resulta importante señalar algunos aspectos básicos pero sobresalientes sobre algunos de ellos, aunque sea de manera breve.

- Características de los títulos valores.

Nótese que la mayoría de estos títulos ejecutivos son a su vez de los llamados "títulos valores" (pues ha de recordarse que son concepciones diversas, dado que no todo título valor es ejecutivo), para los que se predican las características de autonomía, incorporación, legitimación y literalidad, aspectos que no deben ser extendidos indebidamente a otro tipo de títulos ejecutivos, los que por su origen y naturaleza deben ser tratados en forma distinta, según lo veremos más adelante al referirnos a los denominados "títulos ejecutivos administrativos". Sobre las mencionadas características, conviene transcribir la concepción adoptada por el Tribunal Superior Contencioso, Sección Segunda, en reiteradas

resoluciones en las que ha señalado lo siguiente:

"Redacta la Juez Ferrero Aymerich; y,

CONSIDERANDO:

... De conformidad con el capítulo correspondiente del Código de Comercio y la doctrina que lo informa, los títulos valores, dentro de los que se encuentra el pagaré, se rigen por los principios de autonomía, incorporación, legitimación y literalidad. El de incorporación significa, que el derecho está incorporado al título, es indispensable y bastante a l a vez, para hacer efectivo el derecho, la exhibición del documento. Como su inmediata consecuencia, surge l a legitimación, principio en razón del cual, solamente quien posea el título es quien puede ejercitar el derecho contenido en él y que atribuye a quien lo posee, la facultad de exigir del deudor, el cumplimiento de la obligación - legitimación activa -. La literalidad es la máxima de "sustantividad" o "independencia", y que consiste en que el título se basta a sí mismo, sin que pueda integrarse con otro documento. Es el principio que se contrae al contenido del título y significa que para determinar su naturaleza, vigencia y modalidad, es necesario y decisivo el elemento escritura, sin que pueda el obligado, modificar o variar su contenido invocando elementos fuera de él y que no pueden ser reconocidos

por su medio. Por último, la literalidad confiere al dueño del documento, la seguridad de que su derecho no podrá ser contradicho por excepciones o defensas basadas en hechos que no consten en el título mismo - artículo 667-." (Sentencia número 329-90 de las 9:40 hrs. del 31 de mayo de 1990. En igual sentido, pero referida a la letra de cambio puede verse la resolución número 396-89 de las 16:05 horas del 7 de setiembre de 1989)

- Facturas.

En cuanto a las facturas, es preciso reiterar que solamente son ejecutivas aquellas que versen sobre compraventa de bienes, no así las referidas a servicios (entre muchas, pueden verse las resoluciones del Tribunal Superior Primero Civil número 1409 de las 9:45 horas del 17 de agosto de 1984; la 2044 de las 8:10 horas del 9 de noviembre de 1984; la 2048 de las 9:10 hrs. del 29 de noviembre de 1985 y la número 2382 de las 9:35 hrs. del 26 de noviembre de 1985). Además han de estar debidamente firmadas por el personero respectivo conforme lo indica el Código de Comercio (sobre el punto pueden verse las resoluciones del mismo Tribunal Superior Primero Civil, número 1424 de las 8:00 horas del 21 de agosto de 1984 y la 802 de las 7:50 hrs. del 17 de mayo de 1985). Al momento en que se presenten como título base del proceso, deben contener los timbres fiscales correspondientes, pues de lo contrario deberán cancelar la multa de ley (diez veces lo dejado de pagar)

- Certificados de Depósito.

Dentro de estos documentos privados han surgido ocasionalmente fuertes dudas en relación a algunos títulos valores, que aunque tales, no tienen dispuesto en forma expresa el privilegio de la ejecutividad.

Este es el caso por ejemplo de los certificados de depósito expedidos por un Banco Estatal, los que en su momento provocaron fuertes discusiones a nivel jurisdiccional. El asunto fue resuelto sin embargo en forma contundente por el Tribunal Superior Contencioso Sección Segunda, que al respecto señaló en una excelente redacción del Juez de entonces **Vindas Valdares** la verdadera naturaleza del certificado de depósito como título valor administrativo pero no como título ejecutivo. Expresó el Tribunal lo siguiente: *"Fuera de los cuatro títulos a que se hace referencia* (Letra de Cambio,Pagaré, Cheque y Carta de Crédito), *todo otro documento que en orden a su contenido constituya título valor, para que el derecho pueda hacerse efectivo en vía sumaria es preciso que esté legalmente tipificado como título ejecutivo de acuerdo con su naturaleza específica; pues hay títulos valores innominados por falta de sustento legal, así como otros que, teniendo origen en la ley, carecen de fuerza ejecutiva, en cuyos casos, de toda forma, les son aplicables las normas generales que sobre títulos valores tiene previstas el Código de Comercio. (Artículo 685*

ibídem) . De manera que, ni todo documento de crédito es título valor pleno, ni todo título valor es ejecutivo. Pues en efecto, cuando aquí se dice que l a ejecutividad es el elemento esencial del título valor, según los conceptos contenidos en el artículo 667 del Código de Comercio, se está haciendo clara referencia al documento de crédito, en el entendido de que, de lo que trata l a materia analizada, es del cobro de una suma de dinero por cantidad cierta y determinada, líquida o que pueda liquidarse con base en el mismo título, pues ese es el objeto del título ejecutivo en orden a lo establecido por los artículo (sic) 426 y siguientes concordantes del Código de Procedimientos Civiles. Mas nada de lo dicho tiene que ver con otro tipo de títulos valores que, ejecutivos o no, consignan otro tipo de derechos y dan lugar a otra clase de acciones o de simple intervención fuera de juicio (...) En definitiva, la ley, que no lo prevé, no le confiere carácter de título ejecutivo al Certificado de Depósito a plazo, documento sui géneris de mera creación administrativa." (Sentencia número 570 de las 11:18 hrs. del 29 de octubre de 1982. En igual sentido puede verse la sentencia número 590 de las 8:15 hrs. del 19 de noviembre de 1982)

b- <u>Extrajudiciales Administrativos</u>.

Por último, corresponde referirse a los denominados títulos extrajudiciales administrativos, por los que entendemos

aquellos que se forman y perfeccionan en el seno de un ente u órgano de carácter público, el que ejerciendo típicas potestades de la misma naturaleza (públicas), certifica la existencia del adeudo, el monto del crédito, fecha de vencimiento, identificación del deudor, y demás elementos necesarios, a fin de acudir a la vía sumaria ejecutiva. Es decir, son aquellos documentos que emitidos por la Administración Pública en ejercicio de sus inherentes potestades de imperio (aplicadas por ende de manera unilateral y en una relación de sometimiento para el administrado), hacen constar la existencia de un crédito líquido y exigible en su favor, y que por virtud de dichas potestades, que mas bien privilegios, gozan de la fuerza ejecutiva a fin de compeler al deudor (privado o público) al pago de la suma indicada por el propio órgano o ente. Los mismos, como es obvio, requieren de creación legal, según lo dicho páginas arriba, y en algunos casos, ocupan requisitos adicionales previos a la emisión del documento, como ocurre esencialmente con la responsabilidad interna del funcionario, en la que el título debe ir precedido del correspondiente procedimiento administrativo, capaz de garantizar la defensa del afectado a través de un debido proceso. En muchos de los supuestos contemplados en este grupo de títulos, se restringe la posibilidad de defensa del deudor a la excepción de pago, y en algunas ocasiones se amplia a la de prescripción. Consideramos sin embargo, que esta limitación carece de fundamento, y que por el contrario es abiertamente inconstitucional, desde que la potestad de imperio se extiende

hasta la posibilidad de expedir el título como ejecutivo, pero nunca a cercenar el derecho de defensa del que goza todo administrado, en este caso deudor, el que como tal, puede hacer valer todas aquellas excepciones que contempla la legislación procesal civil precisamente en el artículo 433 del Código de Rito.

La enorme variedad de este tipo de títulos convierte en difícil y extensa la tarea que pretenda enumerarlos de manera exhaustiva, por lo que tan solo nos limitaremos a citar los ejemplos más relevantes, aludiendo en forma casual a algún aspecto importante y particular de alguno de ellos.

1-) Certificaciones de la Tributación Directa.

En primer término encontramos las certificaciones emitidas por la Dirección General de Tributación Directa, las que de acuerdo con el artículo 160 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios tienen carácter ejecutivo cuando hagan constar el adeudo de impuestos, tasas, contribuciones, derechos fiscales, rentas por arrendamiento de bienes del Poder Central no sujetos a leyes especiales, y de toda clase de créditos a favor de éste. Aquí, interesa llamar la atención sobre el contenido del párrafo segundo del numeral indicado, puesto que en la generalidad de los casos, el acto administrativo (como es cabalmente en este caso el establecimiento del adeudo mediante la respectiva certificación) goza de la presunción de legitimidad y además

resulta ejecutivo y ejecutorio, o para utilizar una terminología más adecuada, digamos que con el privilegio de la "ejecución forzosa", por lo que sus efectos y ejecución no se suspenden, aún y cuando se hubiere formulado algún recurso administrativo o acción jurisdiccional contencioso administrativa en su contra (artículos 148 de la LGAP y 91 de la LRJCA). Empero, en el mencionado párrafo se establece una excepción a la regla al disponer que no deben certificarse los créditos fiscales ya mencionados cuando hayan sido objeto de impugnación por el interesado en virtud de recurso administrativo, hasta que el Tribunal Fiscal Administrativo (que en esta materia figura como jerarca impropio) dicte la resolución correspondiente agotando la vía administrativa. Como puede verse entonces, para este caso, el recurso administrativo sí suspende los efectos de la disposición impugnada.

Esta imposibilidad de ejecutoriar el acto que establece los tributos específicos sino hasta que sea definitivo, no debe confundirse sin embargo, con otra situación totalmente distinta, que se presenta cuando habiéndose resuelto el recurso por parte del Tribunal Fiscal Administrativo, y habiéndose agotado por ende la vía administrativa, se presenta ante el Juez el proceso ejecutivo correspondiente, en tanto que el particular afectado acciona por la vía jurisdiccional ordinaria, mediante un proceso declarativo especial tributario (de los consagrados en el artículo 82 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). En ese caso, el acto que se ejecuta posee plena ejecutividad y ejecutoriedad,

sin que la interposición del proceso ordinaria tenga la virtud de suspender el trámite del sumario, siguiendo con ello el conocido principio general de que "el ordinario no suspende el trámite del sumario" recogido en la doctrina y en la jurisprudencia reiterada por muchos años, máxime que en este proceso especial tributario, según lo preceptuado por el inciso 9) del artículo 83 del de Ley Reguladora citada, no cabe el incidente se suspensión de los efectos del acto administrativo. En este mismo sentido se ha pronunciado expresamente nuestra Sección Segunda del Tribunal Superior, cuando refiriéndose al caso espícífico señaló:

"Redacta la Juez Ferrero Aymerich; y,

... la Administración Tributaria, tiene la potestad de emitir títulos ejecutivos cuando los tributos por ella establecidos estén definitivamente aprobados en vía administrativa y es precisamente lo que sucede en el sub judice, en donde, al mediar apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, por inconformidad de lo resuelto por la Dirección General de Tributación Directa, ese órgano colegiado confirmó lo actuado, de manera que el tributo está aprobado en vía administrativa, lo que concede al actor, se reitera, el derecho de cobrar la suma que le es adeudada por el trámite del juicio ejecutivo y en razón de ello no puede accederse a la suspensión de los procedimientos aún y cuando exista incoado por parte de la aquí demandada, un juicio contencioso

administrativo - especial tributario - , por la inconformidad de la determinación de que fue objeto. Si llegare a prosperar esta demanda en favor de la accionante, podrá solicitar la devolución de las sumas pagadas en forma indebida. " (Sentencia N o 4200 de las 9:00 hrs. del 8 de noviembre de 1988. En igual sentido puede verse la resolución 3936 de las 9:00 hrs. del 21 de junio de 1988).

Sobre todos estos aspectos de la certificación Tributaria (central), sin embargo, es importante esperar el pronunciamiento de constitucionalidad, pues recientemente se interpuso una acción ante la Sala Constitucional contra los párrafos penúltimo y último del artículo 160 del Código de Procedimientos Tributarios y contra los incisos 2 y 9 del artículo 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa, citados líneas arriba (Ver Expediente No 4765-94, presentado el 21 de setiembre de 1994).

En esta materia, el Código Tributario exige dos tipos de audiencias como acto previo a la ejecución misma. En primer término, el artículo 160 señala en su párrafo tercero que como acto previo al envío de la certificación a la Oficina de Cobros, la Administración Tributaria deberá notificar al deudor por cualquiera de los medios señalados por el artículo 132 del mismo Código, que le concede un plazo de quince días, **contados a partir de su notificación**, para que se proceda a la cancelación del crédito fiscal impago. Podrá observarse la fecha inicial que se establece para el cómputo del plazo

diferente de la regla general ("a partir del día siguiente al de la notificación").

Este plazo de quince días, no debe confundirse con un segundo requerimiento que establece el artículo 162 del mismo Código de Rito, también de previo a el cobro judicial respectivo. En este caso, debe concederse un plazo de ocho días al deudor para que proceda a la cancelación del crédito fiscal impago, ya certificado.

En la primera regla, se establece la obligación de otorgar al deudor un plazo de quince días, **como acto previo a remitir el asunto a la Oficina de Cobro**, es decir, se trata de una última audiencia al administrado (sujeto pasivo), como parte del debido proceso impuesto como regla especial en el ámbito tributario. De allí que su incumplimiento genera la inejecutividad de la certificación expedida, en cuanto se emitió sin haber otorgado tal plazo, circunstancia por la que debe velar el Juzgador aún de oficio. Pero otra cosa es, el período de ocho días establecido por el 162, cuyo otorgamiento corresponde mas bien a los abogados de cobro o fiscales específicos, **luego de que se expidió la certificación ejecutiva.** De manera que aquí, esos ocho días juegan no como parte del debido proceso, a cumplimentarse de previo a la emisión del acto, sino como **intimación** necesaria antes de la ejecución judicial. En este sentido, la consideramos excesiva, pues el deudor tributario en este caso, ha tenido toda la posibilidad de defenderse y hacer valer sus derechos en el procedimiento administrativo, el que una vez finalizado obliga

incluso a un requerimiento como acto previo a certificar el adeudo, según acabamos de ver, además de que ante el Juez tendrá también toda la oportunidad de defensa en el proceso sumario ejecutivo. Siendo así no vemos la necesidad de esta segunda intimación, y no porque nos parezca mal que la Administración trate a toda costa de recuperar sus créditos en sede administrativa, o que se de al moroso la mayor oportunidad de pago. Esto parece bueno. Sin embargo resulta impropio que se imponga como un requisito necesario e ineludible, que de omitirse (por ese solo hecho) produce (muchas veces ya para sentencia) la inadmisibilidad del proceso, con todo el costo que ello implica.

Sin embargo, hemos dejado de lado un aspecto de suma importancia en estas audiencias, a saber: su comunicación. El artículo 160 manda que la primera de ellas (la de 15 días) se comunique por cualquiera de los medios del artículo 132 del mismo Código, al domicilio que conste en sus registros. No obstante, cuando acudimos a dicha norma, encontramos enumerados varios mecanismos de notificación, los que no debemos entender establecidos en forma estrictamente prioritaria, pues ello implicaría acudir a los mismos necesariamente en el orden señalado por el precepto. Estimamos por el contrario, que el artículo 132 simplemente señala las formas en que puede notificarse (en este caso) la audiencia, e incluso no las agota, por lo que resulta una lista meramente ejemplificativa y no taxativa. Consideramos que estos medios de notificación, deben ser interpretados y aplicarse con miras a que se cumpla

su fin último y esencial: la adecuada y real comunicación al administrado, que no protege otra cosa que su derecho de defensa. De allí que respetando el criterio jurisprudencial sentado tanto por los Tribunales Contenciosos como Civiles, y el de la propia Sala Constitucional, creemos que deben aplicarse en forma supletoria, en el siguiente orden:

a-) Notificación personal cuando concurra el deudor a la Tributación Directa, según lo manda el inciso a. del artículo 132.

b-) Notificación personal o en su casa de habitación por medio de funcionario común o de policía, según los términos del inciso c) del mismo artículo.

c-) De no ser posible lo anterior, por medio de correo certificado con razón de recibido, cuando se conozca su residencia (persona física) o su domicilio legal con certeza de que allí habita. En este supuesto ha de presumirse que el certificado de correo fue debidamente recibido en su destino, salvo que el deudor alegue lo contrario, en cuyo caso recaerá la carga de la prueba en la Tributación Directa.

d-) Y en el evento que no hubiere podido notificarse al deudor por ninguno de los medios anteriores, <u>luego de haberse agotado los mismos o comprobado que ya no habita allí y que se desconoce su paradero</u>, podrá notificarse por edictos, tal y como lo autoriza el inciso d) del numeral de comentario. Es realmente lamentable la costumbre acuñada por el órgano tributario, cuando reiteradamente ha acudido a la notificación por edictos como medio primario e inicial de comunicación, con

detrimento evidente para el administrado, y por ende, inadmisible desde un punto de vista jurídico.

Por último resta agregar que en los procesos que se presenten con este tipo de certificaciones, no es preciso que se aporten los requerimientos o avisos de cobro (boletas) que exige el 162 citado, pues ha de presumirse que los mismos se efectuaron realmente, y sólo en aquellos casos en los que el demandado niegue haberlos recibido, deberán ser requeridos por el Juzgador. Asimismo, sobre algunos aspectos de la prescripción de estas obligaciones y los actos capaces de interrumpirla (donde entran en juego cabalmente los mencionados avisos), volveremos luego en un capítulo posterior.

2-) Certificaciones del INS sobre riesgos del trabajo.

El artículo 232 del Código de Trabajo otorga ejecutividad a las certificaciones expedidas contra el patrono, por el Jefe del Departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros referidas al cobro de cualquier suma que se le adeude, derivada de la aplicación del régimen de riesgos del trabajo que establece el mismo Código y específicamente para los casos en que un trabajador no asegurado, que habiendo sufrido uno de estos riesgos, acuda al Instituto en demanda de prestaciones médico sanitarias y de rehabilitación. De igual potestad goza la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando haya sido dicha entidad la que cubrió el

servicio.

3-) Certificaciones Municipales.

El artículo 84 del Código Municipal establece la ejecutividad para aquellas certificaciones de los Contadores Municipales (no de la Secretaría Municipal) relativas a deudas por impuestos, contribuciones o tasas municipales, con la observación que ya comentáramos líneas arriba (en el sentido de que es inconstitucional), de que en el proceso establecido con fundamento en ellas, sólo proceden las excepciones de pago y prescripción. Para estos cobros judiciales ha sido competente la jurisdicción civil, de acuerdo a la localidad respectiva (por disposición del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior). Sin embargo, según veremos luego al referirnos a la competencia como excepción, con la nueva Ley Orgánica, al parecer el conocimiento de estos asuntos queda atribuido a la Jurisdicción Civil de Hacienda, como siempre debió ser (artículos 115 y 119, ambos en su inciso primero).

Dentro de los tributos a los que alude la norma como sujetos a cobro judicial, pueden tan solo a manera de ejemplo, lo relativo a las patentes y licencias municipales (arts. 96, 97 y 98 del Código Municipal); lo concerniente a servicios urbanos como alumbrado público, limpieza de las vías públicas, recolección de basura, mantenimiento de parques y zonas verdes (art. 87 del mismo Código); o lo relativo a la construcción de cercas y limpieza de lotes sin construir, remoción de objetos,

materiales o similares abandonados (artículo 88 del Código de referencia. Sobre este artículo es preciso señalar que en vista de la inconstitucionalidad declarada sobre el párrafo segundo introducido por Ley No 7108 de 8 de noviembre de 1988, queda vigente tan solo la primera parte de la norma, la que por cierto no corresponde a la supuesta transcripción de la norma originaria que se hace con equívoco en la resolución de la Sala Constitucional de referencia). Asimismo, son susceptibles de cobro por esta misma vía, los denominados "detalles" de caminos públicos, sobre los cuales haremos comentario individualizado mas adelante.

4-) Certificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. (C.C.S.S.)

En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, la ley confiere ejecutividad a las certificaciones expedidas por el Jefe de Contabilidad de dicha institución, cuando dispone en el artículo 53 lo siguiente:

> *"La certificación del Jefe de Contabilidad de la Caja, sobre sumas debidas a ésta, constituirá título ejecutivo. En el juicio correspondiente se admitirán las excepciones contempladas en el artículo 433 del Código Procesal Civil" .*

El artículo en cuestión hasta hace poco, autorizaba a los Jefes de las Sucursales de dicha institución autónoma a certificar los adeudos que existieran en favor de la Caja dentro de su correspondiente ámbito territorial. Sin embargo, la Sala Constitucional, mediante voto número 2852- 92 de las

14:00 hrs. del 8 de setiembre de 1992, declaró la inconstitucionalidad del párrafo segundo de dicha norma por ser atípica, dejando vigente en su lugar la reforma realizada a dicho artículo mediante ley número 2765 de 22 de junio de 1961, con lo que se suprimió dicha potestad a los Jefes de Sucursales, además de que rompió la restricción de la defensa para el deudor, al admitir para dichos procesos todas las excepciones contempladas en el artículo 433 del Código Procesal Civil y ya no solo la de pago como anteriormente se disponía.

Con estos títulos de la Caja se ha presentado sin embargo algún problema ocasional, pues el mismo artículo 53 citado faculta a esa entidad para denunciar las faltas que se contemplan en los artículos 44 y siguientes, y cuando la falta cometida implique perjuicio económico para la institución, deberá imponerse, además de la multa respectiva (cuya ilegalidad e inconstitucionalidad es patente, desde que no está- fijada por ley sino por vía reglamentaria, cabalmente en el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte y en el Reglamento de Enfermedad y Maternidad, lo cual viola incluso el contenido expreso del artículo 124 de la Ley General de la Administración Pública), el pago de los daños y perjuicios los que consistirán en el monto de las sumas que como consecuencia de la infracción no hayan ingresado a la Caja y en los intereses legales sobre esas sumas. El cuestionamiento surge en aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo del Ministerio de la materia, denuncia al patrono por esa infracción a las leyes de trabajo, pues en ese caso, como se dijo, el Juez Laboral, de comprobar

la infracción, condena con una multa al patrono y a los daños y perjuicios.

Por cierto, sobre estos últimos en muchas oportunidades se omite pronunciamiento, lo que en nuestro criterio no debiera ser, vista la disposición expresa de la ley y porque con dicha actuación además se impide establecer la reincidencia de un patrono en caso de que vuelva a incumplir con dicha obligación. Pero volviendo al aspecto de nuestro interés, tenemos que por otra parte, la Caja procede a cobrar por la vía ejecutiva las mismas sumas adeudadas en la sede civil de hacienda. Entonces, ¿ lo resuelto en un asunto, produce cosa juzgada en cuanto al otro ? La respuesta debe ser negativa, pues solo las sentencias firmes venidas de proceso ordinario tienen tal efecto jurídico, y así lo ha dispuesto entre otras, la resolución del Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Segunda, número 1234 de las 8:30 horas del 12 de enero de 1984, quizá en grado extremo, pues declara la independencia absoluta entre ambos procesos. Sin embargo, estimamos que en aquellos supuestos en los que se determina la inexistencia de la infracción laboral (porque no existe por ejemplo la relación de empleo alegada), sí se producen efectos directos en el proceso ejecutivo, en el que necesariamente debe ponderarse esa circunstancia a efecto de acoger o no la demanda ejecutiva. Nótese que en el fondo nos estamos refiriendo a la posibilidad de examinar la causa del título (en cuanto a la existencia o no de los supuestos fácticos que la anteceden), aspecto de suyo complejo, y sobre el que volveremos al momento de analizar el artículo 149 de la

Ley General de la Administración Pública. Por lo pronto basta indicar que para estos títulos específicos, compartimos en todo la posibilidad de examinar la situación fáctica que dio origen a la certificación, máxime si ya existe un pronunciamiento jurisdiccional, por parte en este caso del Juez de Trabajo, que establece certeza sobre el presupuesto de hecho controvertido ahora en el proceso ejecutivo. De esta forma también lo ha señalado la misma Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso en la resolución número 4971 de las 9:15 hrs. del 7 de agosto de 1981, en donde manifestó:

> *"Armonizando lo dicho debemos entender que si existe ya una sentencia en que se declara al patrono exento del pago, no puede la Caja constituir otro título para cobrar por la misma causa, máxime que el artículo 56 de la citada Ley Constitutiva dice que el derecho a reclamar los daños y perjuicios," sea que se ejercite la vía de ejecución de sentencia penal o directamente la vía civil... ", lo que nos da la idea de que ambas acciones son excluyentes" .*

En estos títulos de la Caja se ha venido cuestionando también la necesidad o no de un procedimiento administrativo de previo a expedir la certificación, pero este es un tema que abordaremos páginas adelante.

5-) Certificaciones del INA.

También gozan de ejecutividad por disposición expresa de la ley (artículos 16 de la Ley 6868 del 6 de mayo de 1983 y 20 de la Ley 3506 del 21 de mayo de 1965), las certificaciones expedidas por el Jefe del Departamento Financiero del Instituto Nacional de Aprendizaje, en lo relativo a las contribuciones establecidas por la misma ley.

6-) Certificaciones del Banco Popular y Desarrollo Comunal.

Para el caso del Banco Popular y de Desarrrolo Comunal, las certificaciones que expida el Jefe del Departamento de Inspección en materia de cuotas patronales y de ahorro son título ejecutivo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley número 4351 y sus reformas.

Sobre el especial cálculo de las multas sobre cuotas del Banco nos referiremos en capítulo posterior. Sin embargo, debe tenerse presente que en la actualidad este tipo de procesos se encuentran suspendidos por estar cuestionados ante la Sala Constitucional los artículos 5, 8 y 10 de dicha Ley Orgánica (Expediente 1901-90. Avisos publicados en los Boletines Judiciales número 17, 18 y 19 de los días 24, 25 y 26 de enero de 1991).

7-) Certificaciones del IMAS.

Asimismo tienen ejecutividad las certificaciones expedidas por la Dirección Administrativa y Financiera del Instituto

Mixto de Ayuda Social en lo relativo a las contribuciones del medio por ciento que corresponde a los patronos privados e instituciones autónomas que no dependan del presupuesto ordinario de la república, de acuerdo con los artículos 14,16 y 31 de las leyes 4760 de 4 de mayo de 1971 y 5586 de 21 octubre de 1974. En esta materia han surgido dos interrogantes de interés. En primer término, si la norma cubre también a las instituciones semiautónomas, a lo que se ha respondido en forma negativa, dado que en materia tributaria (y debe recordarse que esta es materia parafiscal) la interpretación normativa debe darse en forma restrictiva. Por otro lado, ha surgido la duda en relación a las instituciones que siendo autónomas reciben aportes del Presupuesto Nacional de la República. En ese sentido se ha dicho que aún y cuando reciban dichos aportes, si los mismos no están dirigidos a los gastos esenciales del ente, y sobre todo a los salarios, deben incluirse como sujetos pasivos de tal imposición.

Por otra parte, esta entidad también certifica con carácter ejecutivo, el impuesto de un treinta por ciento, establecido para los moteles, hoteles sin registro, casas de alojamiento ocasional y similares, que se calcula sobre el valor de la tarifa fijada para cada uso de una habitación, según lo dispone la Ley No 5554 de veinte de agosto de 1974, concretamente en el artículo 5.

8-) Certificaciones del INVU.

En cuanto al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

tenemos que el artículo 44 de la Ley 1788 del 24 de agosto de 1954, confiere ejecutividad a las certificaciones expedidas por el Jefe del Departamento de Contabilidad sobre los adeudos que existan para con la institución.

9-) Certificaciones del ICAA.

A tenor del artículo 5 de la Ley No 6622 de 19 de agosto de 1981 las certificaciones expedidas por el Jerarca del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados acerca de las deudas provenientes de los servicios prestados por dicha institución tienen carácter de título ejecutivo.

10-) Certificaciones de Asignaciones Familiares.

En materia del impuesto que existe sobre los sueldos y salarios en favor de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (5 % mensual), el Director de dicha entidad tiene la potestad de certificar los adeudos que con ella existan, a lo cual se imprime carácter ejecutivo, según lo disponen los artículos 9, 11 y 15 de la Ley No 5662 de 23 de diciembre de 1974. Aquí es preciso aclarar que por artículo 12 de la Ley No 7088 de 25 de agosto de 1987, se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social para el Cobro del monto que corresponde a éste órgano.

11-) Certificaciones del IDA.

Por otro lado el inciso ch) del artículo 7 de la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario (No 6735 de 29 de marzo de 1982) confiere ejecutividad a las certificaciones expedidas por el Auditor General del Instituto en lo relativo a deudas en general.

12-) Documentos de CONAPE.

La ley también otorga ejecutividad a los documentos privados en los que se constituyan créditos en favor de CONAPE relacionados con los contratos para estudio que suscribe dicha entidad, según lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 6041 de 18 de enero de 1977.

13-) Documentos de JAPDEVA.

Para las facturas y cuentas certificadas por el Auditor de Japdeva por créditos en favor de la Institución, también se confiere ejecutividad, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 44 de la Ley No 5337 de 27 de agosto de 1973

14-) Certificaciones del ICE.

En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, tienen carácter ejecutivo todas aquellas certificaciones sobre adeudos en favor del Instituto que se expidan de conformidad con el artículo 21 de la Ley No 3226 de 28 de octubre de 1963. El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección

Segunda ha reconocido esta potestad del ICE, pero sujetándola, a nuestro modo de ver, a un requisito antijurídico, por no estar previsto en el ordenamiento, cuando ha señalado que el título debe ser consecuencia directa de un acto firme (por ello, definitivo), ya sea por falta de impugnación - consentimiento del prestatario-, o bien, por haber emitido el pronunciamiento del caso cuando aquella hubiere mediado (Sentencia No 331-90 de las 10:00 horas del 31 de mayo de 1990). Con ello, se está desconociendo el principio de ejecutividad y ejecutoriedad de aquellos actos administrativos que no sean absolutamente nulos, pues ha de recordarse que de conformidad con el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública - aplicable al caso -, los recursos administrativos no suspenden la ejecución del acto, como ocurre precisamente en el caso de que exista un recurso pendiente contra la resolución que impone una suma a pagar a cargo de un administrado. Mas simple, de conformidad con la norma citada.

artículo 148, no parece necesario que exista resolución (acto) definitivo o firme, para proceder al cobro judicial, pues en virtud de los principios dichos, la resolución final que se emita en el procedimiento puede ser ejecutada. Para este principio, según sabemos, y de acuerdo con lo dicho líneas arriba, sólo existe una excepción, contemplada en la materia tributaria (art. 160 Cod. Trib.).

15-) Certificaciones del SNEE.

Para las multas e impuestos que los concesionarios adeuden al Servicio Nacional de Electricidad nuestro ordenamiento otorga ejecutividad al documento expedido por el Jefe de Contabilidad con visto bueno del Director o Subdirector de dicha institución, según lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley No 276 de 26 de agosto de 1942.

16-) Resoluciones de la Contraloría General de la República

Dentro de este conjunto de instituciones u órganos, también se incluye a la Contraloría General de la República, para cuyas resoluciones definitivas en materia de su incumbencia, que fijen créditos en favor del Estado o en general de los *"sujetos pasivos"*, se confiere ejecutividad, según lo disponía el artículo 9 de su vieja Ley Orgánica, que se retoma ahora en los artículos 7 y 76 de la Ley número 7428 de 7 de setiembre de 1994, publicada en la Gaceta del 4 de noviembre de ese mismo año (que constituye el nuevo marco legal orgánico de aquel centro contralor). Aquí, como en muchos otros casos, según lo señalamos anteriormente, sólo se admitían en la vieja ley (de manera inconstitucional) las excepciones de pago y prescripción. Sí, interesa destacar que siempre entendimos la expresión consignada en el artículo 9 hoy derogado: *"resoluciones definitivas en materia de su incumbencia"*, a todas aquellas que siendo culminación de un procedimiento administrativo, en las que se define por el fondo el objeto del mismo, carecen de ulterior recuso administrativo, es decir,

causan estado en la vía gubernativa, siempre y cuando, claro está, se encuentren directamente relacionadas con la hacienda pública. Creemos que de esta manera debe entenderse también el nuevo artículo 76 cuando en forma más clara otorga la mencionada ejecutividad a la *"resolución razonada que declare la responsabilidad y su monto pecuniario"*, previo cumplimiento del debido proceso.

Obviamente, debe entenderse que se trata de resoluciones emitidas dentro del ámbito mismo de sus competencias de control y fiscalización de la Hacienda Pública, y es precisamente la certificación de l¡o dispuesto y consignado en ella, la que se convierte en el título ejecutivo base del proceso. Con esto, estamos excluyendo de dicha potestad, la práctica viciada que venia dándose en el pasado, en cuanto algunas instituciones descentralizadas (que en principio parecían carecer de la potestad para crear títulos ejecutivos) enviaban las certificaciones de sus acreencias a dicho órgano contralor, para que éste, por medio de un sello certificara la validez de la misma. Con ello iniciaban posteriormente el proceso ejecutivo, con una certificación que en modo alguno podía considerarse como resolución definitiva de las que menciona la ley de referencia. De esta manera, diferimos del criterio que en su momento expresara la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, únicamente en lo relativo al considerando cuarto de la resolución número 3854 de las 9:40 hrs. del 10 de mayo de 1988, en cuanto señaló:

"IV.- La sentencia niega carácter de título ejecutivo

a la certificación que sirve de fundamento a esta demanda, pero ciertamente que la resolución número 34- L- 85 dictada por la Contraloría General de la República en el dorso de la certificación expedida por el señor Auditor Interno del Instituto Costarricense de Turismo, con fundamento en el artículo 9 de su Ley Orgánica, sí le imprime el carácter pretendido por el actor de título ejecutivo..."

Es de hacer notar sin embargo, una restricción clara y razonable que introduce el nuevo artículo 76, cuando limita la causa de la lesión patrimonial del sujeto pasivo (público o privado) a una ilegalidad, la que no puede ser cualquiera, sino **flagrante y manifiesta**. Es decir, la Contraloría General de la República podrá certificar sus resoluciones definitivas con carácter de título ejecutivo --en cuanto establezcan por supuesto una suma líquida y exigible en contra del servidor o servidores del sujeto pasivo (público o privado)--, siempre que haya podido determinar como causa o origen del daño patrimonial, una ilegalidad del servidor flagrante y manifiesta, según la determinación que de ella haga el órgano contralor, que aunque no sujeta a control y revisión del Juez en el propio "juicio" ejecutivo a que dio origen (por virtud de la presunción de legitimidad de que goza dicho acto y de la sumatoriedad del proceso ejecutivo, que no permite en su seno discusiones de esa índole), sí puede ser objeto del control jurisdiccional mediante el proceso ordinario correspondiente,

sin excluir naturalmente, el eventual control de constitucionalidad ante la Sala respectiva.

Dentro de esta potestad general, también son título ejecutivo las resoluciones que emita la misma Contraloría (luego de cumplido el debido proceso) en las que determine la responsabilidad civil de un funcionario o empleado municipal, cuando hubiere actuado en perjuicio de la corporación y con motivo de la custodia o administración de los fondos y bienes municipales, siempre que se determine que actuó con evidente culpa o con manifiesta violación de ley (**artículo 74 del Código Municipal**). Aquí resultan interesantes dos aspectos. En primer término, que el párrafo tercero del mencionado artículo otorgara con anterioridad a la nueva Ley Orgánica, la legitimación o mas exactamente, capacidad procesal a la Contraloría General de la República para accionar a nombre del gobierno municipal, cuando éste no hubiere iniciado el cobro dentro del plazo de un mes. Y llama la atención por el hecho de que la Contraloría (como órgano que es) carece de personalidad jurídica y por ende tampoco tenía capacidad para accionar por sí misma. De allí que sus decisiones como contralor o fiscalizador <u>eran defendidos</u> (al igual que todo órgano miembro del Estado Central) por la Procuraduría General de la República, con la salvedad de que podía y puede actuar como coadyuvante (diríamos que activo y pasivo), en aquellos procesos en los se discutan conductas administrativas en la que ella hubiere efectuado algún grado de fiscalización. Hoy la situación es diversa, pues de conformidad con los artículos 3

párrafo tercero, 35 y 36 de su nueva Ley Orgánica, está- autorizada no solo para intervenir como coadyuvante sino incluso como parte principal cuando se trate de la defensa y resguardo de la Hacienda Pública o de fondos privados sujetos a control. Con esto, deben entenderse complementados y en algún aspecto, derogados en forma tácita, los artículos 9 y 11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cabe entonces cuestionarse, si estas nuevas disposiciones de la Ley Orgánica, permiten a la Contraloría General de la República establecer de manera generalizada los procesos ejecutivos incoados con fundamento en sus propias certificaciones, figurando en consecuencia como parte demandante. Consideramos que la respuesta debe ser negativa, pues es esta una facultad que sigue reservada la Procuraduría General de la República, cuando del Estado Central se trate, o al propio ente público menor en caso contrario. Nótese que la legitimación otorgada parece restringida a aquellos procesos (de cualquier índole) en los que se cuestione o discuta *"sobre actos o dictámenes de la Contraloría o sobre actos de la administración activa ordenados o recomendados por ella"* , tal y como lo dispone el propio artículo 36, circunstancia que no se da cuando se establece por la vía ejecutiva el cobro de un monto adeudado. Pero la hipótesis específica de comentario (la del 74 municipal), es bastante diversa, pues se trataría de un proceso ejecutivo instaurado por la Contraloría como actora, aún cuando sea en nombre de la Municipalidad. Es obviamente una excepción a la regla en la que el órgano Contralor actúa en una especie

de gestoría procesal.

El otro aspecto a comentar en cuanto a este punto, se refiere a lo dispuesto en el párrafo cuarto del mismo artículo 74 del Código Municipal en donde se dispone que:

> *"Los efectos de la resolución de la Contraloría quedarán sin lugar sólo si fuere anulada en la jurisdicción contencioso administrativa, o por sentencia penal firme que la contradiga"* +

Es obvio, aunque el artículo no lo disponga, que los efectos de la resolución de Contraloría, también quedarán sin efecto cuando así lo disponga la Sala Constitucional por resolución firme. Pero el aspecto más discutible, radica en la susceptible suspensión de los efectos de la disposición de comentario. Al respecto consideramos que los efectos de dicha resolución se suspenderán bien por disposición de la Sala Constitucional, ante el establecimiento de un recurso de amparo e incluso, por disposición en firme de un Tribunal (en sentido lato) Contencioso Administrativo ante la formulación de una gestión ("incidente", como se le ha denominado) de suspensión de los efectos del acto administrativo, conforme lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Nótese que el artículo se refiere a la supresión total de los efectos, no así a la susceptible suspensión de los mismos. Pero en todo caso, negar al administrado la eventual suspensión de los efectos de este acto discutido en el amparo o en la vía plenaria, parece evidentemente inconstitucional, entre otras razones, por

palmaria transgresión al principio de igualdad.

Por último, dentro de esta potestad de emitir títulos ejecutivos, la Contraloría General de la República también puede certificar con dicho carácter, los daños y perjuicios causados al Gobierno Municipal por uno de sus servidores a consecuencia del incumplimiento de la obligación de servicio que éste adquiere con la corporación, luego de haber disfrutado de una beca o licencia con goce de salario, según lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 149 del mismo Código Municipal. Aquí parece que la legitimación para el cobro está dada, no a la Contraloría, sino al mismo municipio, con fundamento en la certificación expedida por la Contraloría.

17-) Copias Certificadas de Títulos Valores - Ejecutivos extendidas por Bancos Estatales.

El artículo 70 párrafo 5o de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional confiere a los Bancos comerciales **la facilidad** de presentar como título ejecutivo base de sus procesos, fotocopias debidamente certificadas por el Gerente de la institución. Señalamos que se trata de una facilidad, pues realmente no es una potestad de crear el título en sí mismo como ejecutivo, tal y como se ha dicho, sino de presentar fotocopia certificada de título que ya existe y que está en custodia del Banco, lo que realmente es un privilegio, pero no por la creación de un nuevo título . Y no podría ser de otra manera, pues en la esfera crediticia a los particulares, el Banco estatal normalmente actúa en su capacidad de derecho privado (empresa pública- ente público), por lo que mal

haríamos al permitirle creación de aquellos.

Para esta regla de presentación de fotocopias certificadas, en la jurisdicción civil de hacienda se dan dos excepciones: los cheques y las cédulas hipotecarias. Los primeros en virtud de su normal y rápida circulación, amén de la debida comprobación de firmas. Las segundas para efecto de verificar quien es realmente el poseedor del título y para efectos de su posterior cancelación registral, que incluye su incineración, tal y como lo señalan los artículos 439 in fine del Código Civil y 24 y 86 del Reglamento del Registro Público.

En virtud del enorme cúmulo de funciones que posee el Gerente de un Banco y de lo engorroso que le resulta certificar cada una de las fotocopias que se presentarán como título ejecutivo, algunas entidades bancarias han ideado la posibilidad de delegar dichas función en los Jefes de cobro Judicial o de los Departamentos Jurídicos, como es el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y del Banco Anglo. En el Popular se delegó la posibilidad (competencia) de firmar las certificaciones a la Jefatura del Departamento de Control de Crédito y Gestión de Cobros, según acuerdo publicado en el Diario Oficial la Gaceta No 46 del 7 de marzo de 1988. En el Banco Anglo Costarricense la Gerencia se había delegado dicha función al jefe y subjefe de la Sección de Cobros de esa entidad, conforme acuerdo publicado en el mismo Diario Oficial La Gaceta No 83 del 3 de mayo de 1990. El Tribunal Superior Contencioso. Sección Segunda, ha dado por buenas dichas delegaciones, realizadas al amparo de lo dispuesto en artículo

89 de la Ley General de la Administración Pública, al considerar que no se trata de funciones personalísimas otorgadas al Gerente, pues no estamos frente a competencias otorgadas a dicho Gerente en razón de su específica idoneidad para el cargo y que por ende, pueden ser plenamente delegadas, siempre que se cumpla con la publicación que exige el mismo artículo citado, ya que se trata de la delegación para un tipo de acto y no para un acto determinado (entre otras, puede verse la resolución No 3851 de las 9:10 hrs. del 10 de mayo de 1988 y la No 4161 de las 9:00 hrs. del 11 de octubre de ese mismo año).

18-) Certificaciones de la Auditoría General de Entidades Financieras.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, según reforma introducida a la ley No 1644 mediante ley No 7197 del 26 de octubre de 1988 (publicada en la Gaceta No 222 de 22 de noviembre de 1988), la Auditoría General de Entidades Financieras (no precisa quien, por lo que debe entenderse como único competente para ello al jerarca), puede certificar con carácter de título ejecutivo las multas que se impongan a una empresa por la utilización del término "BANCO" o "ESTABLECIMIENTO BANCARIO" , sin ser tal, es decir, sin estar inscrito como tal, ni estar autorizado para funcionar como entidad bancaria. En ese caso, la multa que debe imponerse es de cien mil colones (100.000) y dos mil colones (2.000,oo) por cada día que mantenga o utilice dicha denominación.

19-) Certificaciones sobre "detalles" impagos en materia de caminos públicos

La Ley General de Caminos Públicos (No 5060) establece en sus artículos 8- 9- 10- 13 y 16 los denominados "Detalles" que debe cancelar el sujeto pasivo como contribución anual para el mantenimiento de los caminos públicos. Para el caso de no pag la misma ley en el artículo 16 establece la ejecutividad de la certificaciones extendidas por el Ministerio de Obras Pública y Transportes (si la vía es nacional) o del Municipio correspondiente (si el camino es vecinal). Más aún, el artículo 13 establece gravamen real sobre los bienes de las personas obligadas al pago. En este sentido consideramos que los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 16 no están derogados, ni tácita ni expresamente, como en algún momento se ha señalado, pues la derogatoria que se dio únicamente del artículo 8, lo fue mediante el artículo 71 de la Ley No 6963 que corresponde a la Ley de Presupuesto del período fiscal 1984, lo que es claramente inconstitucional, de acuerdo con el reiteradísimo criterio sentado por la Sala Constitucional sobre normas atípicas.

Como puede verse, esta carga tributaria está dirigida al mantenimiento de caminos vecinales o calles urbanas, según lo preceptuado también por el artículo 94 del Código Municipal que de igual manera alude a este aspecto y que en este sentido debe

concordarse con el artículo 7 de la Ley Sobre la Contribución para Obras de Interés Público Especial (No 74 de 18 de diciembre de 1916), con el Decreto Ley No 578 de 6 de julio de 1949, en cuanto señala una contribución para construir y pavimentar las nuevas vías del Cantón Central de San José; que fue ampliado en forma generalizada para todo el país, por el artículo 71 de la Ley de Planificación Urbana, con el cual también debe concordarse; así como con el artículo 12 de la Ley de Plan Vial, que establece un impuesto proporcional a cada quintal de azúcar que se elabore en cada ingenio, para que las municipalidades construyan y conserven los caminos de acceso a las zonas cañeras.

20-) Certificaciones por servicios de Defensor Público.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley No 7333 de 5 de mayo de 1993, publicada en el Alcance No 24 a la Gaceta No 124 de 1 de julio de 1993) crea un nuevo título ejecutivo de características muy particulares, cuando señala en los artículos 152 y 153 que para aquellos supuestos en los que el imputado solvente solicite los servicios de un defensor público y se niegue luego a pagar al Poder Judicial los honorarios, de acuerdo con la fijación hecha el Juez, constituirá título ejecutivo la certificación que se expida sobre ellos. Surgen aquí varios aspectos de interés. En primer lugar, ¿ a quien corresponde expedir la certificación ? Consideramos que corresponde hacerla al Secretario del Despacho en donde se hayan fijado los honorarios, pues es al Juez a quien

corresponde establecer el monto de los mismos. Nótese que el párrafo primero del artículo 152 establece que el imputado solvente deberá pagar al Poder Judicial los servicios del defensor público, **según la fijación que hará el Juez**, lo que implica que no puede ser el Director Ejecutivo quien certifique y establezca el monto de la obligación. De allí que antes que un título ejecutivo administrativo, constituye éste una resolución judicial ejecutable por la vía del apremio, y más exactamente un título ejecutivo judicial en sentido estricto.

Pero el asunto no termina allí, pues el art. 153 continúa señalando que la autoridad encargada de conocer del proceso (debemos entender por "proceso" el ejecutivo, y no el proceso penal base antecedente del cobro), que necesariamente ha de ser un Despacho Civil de Hacienda (en concreto la Alcaldía), o eventualmente el Juzgado Agrario cuando en un "juicio" suyo se hubiere designado defensor en las condiciones dichas (esto por economía procesal, aunque directamente no tenga una relación agraria), ordenará el embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente. Pero la más interesante es que concede legitimación expresa al defensor correspondiente para realizar las diligencias judiciales y extrajudiciales necesarias para hacer efectivo el pago. Y esto es sorprendente, pues si los defensores públicos son funcionarios dependientes del Poder Judicial (art. 155 de la misma Ley), y este a su vez forma parte del Estado Central (Estado Persona como lo señala la doctrina), hubiese sido lógica consecuencia que del cobro respectivo se encargara la Procuraduría General de la

República, como encargada de representar al Estado ante los Tribunales de Justicia, tal y como siempre se ha hecho. Sin duda alguna, esta especial legitimación al defensor público viene a ser una excepción dispuesta por la ley al principio general de representatividad jurisdiccional del Estado Central.

21-) Certificaciones de la Ley General de la Administración Pública

i-: La ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo y la ejecución forzosa: Nuestra Ley General de la Administración Pública también contempla algunos supuestos de títulos ejecutivos administrativos, fundamentados en las típicas potestades de imperio o mas bien privilegios de que goza la Administración, siempre que actúe en su esfera pública. En efecto, por principio y doctrina la Administración Pública requiere de ciertas atribuciones adicionales con el objeto de cumplir sus fines públicos tanto en la esfera de servicios, como de policía y de orden social. Sin ellos, se afirma, estaría en un plano de absoluta igualdad al particular, lo cual le impediría aplicar las medidas necesarias para la consecución de dichos fines. Ahora bien, para la doctrina clásica esta posibilidad de expedir títulos ejecutivos es derivación directa de la ejecutoriedad del acto administrativo (que no de la ejecutividad, cosa bien distinta),en cuanto se faculta a ésta la ejecución efectiva de sus actos administrativos, haciendo

uso de la fuerza o medios coercitivos si es preciso y sin necesidad de acudir al Juez, es decir, en su propia sede administrativa. Esto es necesario, se afirma, por razones de orden político (el interés general no puede ser obstaculizado o retardado por los particulares, pues aquel priva sobre el de éstos); en el carácter público de la actividad administrativa (que deriva del poder o potestad de mando); en la presunción de validez (no de legitimidad, como tradicionalmente se dice, pues ni siquiera la tienen las leyes en sentido formal) del acto administrativo (en principio, no se puede hablar de riesgo al ejecutar actos que se reconoce válidos, sería contradictorio no hacerlo) (al respecto cfr. **FERNADEZ VASQUEZ (Emilio)**: Diccionario de Derecho Público. Primera Edición, 1981, Editorial Astrea, pag. 265 y ss.).

Sin embargo, no debe identificarse plenamente la ejecución forzosa con la ejecutoriedad, puesto que esta última se refiere a un régimen complejo compuesto por las diversas situaciones objetivas y subjetivas de privilegio en favor de la Administración, generadas precisamente con el acto administrativo adoptado; en tanto que la ejecución forzosa conlleva una potestad de decisión y actuación material indispensable para vencer la resistencia del particular, que de hecho muchas veces no requiere de un acto previo (coacción directa, por ejemplo). Al respecto puede verse **Ortiz Ortiz** (Eduardo): Los Privilegios de la Administración Pública, en Revista de Ciencias Jurídicas No 23, febrero de 1974, p.110). De allí que sea una manifestación directa de aquél privilegio,

entendiendo por tal aquella situación en la que se agrega una ventaja a la esfera de poder económico o jurídico de un sujeto sin hacer lo propio con los otros que se encuentran en igual situación, legal o de hecho. Podríamos decir sobre la idea base de Rafael Mendizabal Allende (citado por don Eduardo, op. cit. , p. 37) que consiste en una regla de derecho excepcional, en cuanto otorga una o varias concesiones especiales a un sujeto sobre los demás que ocupan una igual posición, en el polo opuesto a la discriminación.

De todo esto se extrae que la clásica "ejecutoriedad" se deriva del principio más amplio de **autotutela ejecutiva administrativa** (que exime de la necesidad de acudir al auxilio judicial para que la coacción legítima pueda ponerse en servicio de la ejecución práctica de los derechos de un sujeto desconocido, resistidos o atropellados por los demás. Cfr. **García de Enterría (Eduardo) y Fernández Ramón- Tomás** : Curso de Derecho Administrativo, Tercera Edición, 1979, Madrid, España, Editorial Civitas S.A., pag. 655), y que a su vez permite el de coacción administrativa (con la que tampoco debe confundirse, por ser aquella una simple manifestación de ésta), y que antes que *"ejecutoriedad del acto"* como tradicionalmente se le ha llamado, debe entenderse como la **obligatoriedad coactiva o ejecución forzosa**, que es a lo que verdaderamente aludimos en estas páginas, y que por supuesto no debe equipararse con aquel, tal y como aboga un sector doctrinal moderno, entre los que cabe destacar - por su claridad, aunque quizá incurre en algún exceso -, al autor argentino **Néstor**

Luis Montezanti, para quien (siguiendo a Mairal), es absolutamente falso que la ejecutoriedad sea una virtud *in rerum natura* de todo acto administrativo, pues hay algunos que no la tienen y otros que no la necesitan (como ocurre por ejemplo en el otorgamiento de una condecoración o la autorización del ejercicio de una actividad privada, la imposición de una obligación personalísima o cuando se atribuye a un centro de imputación inmune a dicha ejecución), al grado de que llega a sostener que en todo caso, es una consecuencia directa estructural de su presunción de validez y, por tanto, no merece subsistir. (Suspensión del Acto Administrativo, Primera Edición, Buenos Aires Argentina, Editorial Astrea, 1993). Nuestra idea en todo caso, no es negar esa *"ejecución forzosa"*, que como tal existe, y con carácter independiente; sino desligarla, como actualmente lo hacen varios estudiosos del tema, del acto administrativo como antecedente necesario y ineludible, ya que rebasa en mucho este conocido instituto, pues como se ha reiterado, en algunas conductas administrativas, tal acto no existe, o en algunos otros, aunque exista, no goza del privilegio, todo lo cual nos indica que verdaderamente debe ubicarse como "una cualidad subjetiva predicable de un sujeto, una toma de posición jurídica subjetiva", que algunos también llaman en forma genérica *"obligación de cumplimiento inmediato"* . Bajo esta perspectiva entonces, tenemos que los artículos 149, 204 y 210 establecen la posibilidad de expedir certificaciones a efecto de interponer, con base en ellas, el respectivo proceso ejecutivo.

ii-: Casos de incertidumbre: en el artículo 149 se establece como un medio de ejecución administrativa el apremio forzoso sobre el patrimonio del administrado, cuando se trate de créditos líquidos de la Administración, aplicando para ello las normas del Código Procesal Civil sobre embargo y remate. Para ese efecto sirve de título ejecutivo la certificación del acto constitutivo del crédito expedida por el órgano competente. Ahora bien, la determinación de los alcances del mencionado artículo es una tarea que aún no se ha logrado alcanzar con claridad, puesto que nuestra jurisdicción civil de hacienda ha venido aplicando la disposición para cada caso concreto, sin establecer lineamientos o principios generales acerca de lo que puede o no puede certificar la Administración con fundamento en dicho precepto. Es así como surgen serias dudas sobre la posibilidad de cobrar por esta vía ejecutiva lo relativo a daños y perjuicios producidos por un incumplimiento contractual, o si puede la Administración por esta vía certificar el monto correspondiente a los daños que le ha ocasionado un tercero administrado particular luego de que éste colisionara con un vehículo de aquella, sin que haya mediado aún resolución judicial en ese sentido. También surge incertidumbre acerca de la posibilidad de expedir certificación con base en este artículo, de los faltantes de mercadería que se presenten en un expendio del Consejo Nacional de Producción que se ha dado en administración a un ex-empleado de dicha entidad. Mas recientemente, se ha pretendido cobrar

por la vía ejecutiva con fundamento en este tipo de certificaciones, los viáticos y gastos de representación a un regidor, que se consideraron mal invertidos o destinados, y tampoco fueron liquidados en tiempo, según lo certificó el Contador Municipal, lo cual ha vuelto a provocar dudas sobre este aspecto; como también las ha generado, aquella certificación expedida por el Subgerente de un Banco estatal contra uno de sus ex-funcionarios, mediante la que se pretende el cobro de una suma determinada por el propio Banco como faltante por concepto de "cuenta contable denominada cuentas por liquidar", o una certificación sobre el adeudo generado en una tarjeta de crédito. Asimismo puede citarse el caso del Instituto Nacional de Seguros que subrogándose en los derechos de su asegurado (conforme se lo permite el artículo 20 de la Ley de Seguros), pretende el cobro ejecutivo, también por vía de este tipo de certificaciones, contra aquél que estima como responsable del accidente de tránsito (sin que exista por supuesto resolución judicial al respecto, pues de ser así, estaríamos no ante un proceso ejecutivo sino ante una ejecución de sentencia).

iii-: Excesos de salario: Y dentro de este conjunto de casos particulares, merece especial comentario el pago de salarios en exceso, cuya recuperación se ha intentado por esta misma vía del artículo 149, acción que ha generado innumerables cuestionamientos. Al respecto es bueno aclarar, que el artículo 173 del Código de Trabajo, en su párrafo segundo, permite al

patrono reducir del salario del trabajador, aquellas sumas que hubieren sido entregadas como anticipo o como excesos en el pago de su remuneración, para lo cual, el empleador (público o privado) podrá efectuar las amortizaciones durante la vigencia del contrato **en un mínimo de cuatro períodos de pago**, sin que pueda cobrar interés alguno. Si terminase antes la relación laboral, el patrono podrá efectuar las compensaciones correspondientes por estos rubros al momento de realizar la liquidación final. Este párrafo segundo del 173 (que ha de concordarse con los artículos 36, 171, 576 y 607 del mismo Código), debe entenderse restringido a estos dos supuestos y nunca mas allá, pues no puede prestarse para deducciones salariales directas a causa de otro tipo de adeudos contraídos por el empleado con su patrono, como sucedería en la hipótesis de un préstamo o arrendamiento de dinero (al respecto puede consultarse la sentencia de la **Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia**. No 244 de las 9:30 hrs. del 20 de noviembre de 1985). En el caso del sector público, de previo a efectuar el rebajo, será necesario comunicar formalmente al servidor sobre el monto que se considera pagado de m s, con explicación precisa de por qué, en qué períodos se dio el exceso y por cuanto, así como la forma en que se ha definido su recuperación o el plazo que se le otorga para el reintegro, a fin de que éste pueda realizar las observaciones u oposición que estime pertinentes antes de la ejecución de la medida, en cuyo caso, deber abrirse un procedimiento administrativo a efecto de establecer la verdad real de los hechos y de permitir la

defensa del funcionario. En este sentido, es realmente preocupante la práctica adoptada por algún sector de la Administración, en donde simplemente se ordena y ejecuta la reducción salarial, muchas veces sin comunicación alguna al empleado, que se entera al recibir su pago. Esta es una medida viciada, que constituye un típica vía de hecho, reprochable desde todo punto de vista jurídico (véase el art. 357 de la L.G.A.P.). Obsérvese además que las deducciones deberán efectuarse en un mínimo de cuatro pagos, no en menos, regla aplicable en todo, tanto al sector privado como público. En este aspecto, discrepamos con lo resuelto en su momento por nuestra Jurisdicción de Trabajo, cuando se indicó que la deducción hecha al salario de un servidor público por la suma total, en un sólo pago, no violenta la disposición de comentario (véase la sentencia del **Tribunal Superior de Trabajo** y posteriormente la de la **Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia**, por su orden No.
6090 de las 10:25 hrs. del 22 de diciembre de 1980 y 74 de las 10:00 hrs. del 1 de julio de 1981). Es claro que los fines y naturaleza pública de aquellos dineros, no hacen menos asalariado al funcionario (también público), que ve menguado su salario con igual efecto que el trabajador privado. La resolución viola evidentemente el principio de igualdad, pues con la debida aplicación del artículo en comentario, tampoco se violentaría el de legalidad como principio rector de este régimen de empleo. Ahora bien, es preciso enfatizar que si por estas deducciones surgiere conflicto judicial entre patrono y

trabajador, que haga necesaria la declaración del derecho en favor de cualquiera de las partes, el asunto deberá ventilarse por la vía ordinaria **en sede laboral**, al no estar de por medio prestaciones civiles comunes, o civiles de hacienda (si del sector público se trata), sino contraprestaciones y diferencias surgidas de la relación de empleo, tal y como lo ha dispuesto la **Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia** en las resoluciones número 26 y 27, respectivamente de las 10: 10 hrs. y 10: 20 hrs., ambas del 23 de marzo de 1983. Con lo dicho sin embargo, no se despeja aún la incógnita sobre la posibilidad o no de certificar con carácter ejecutivo este tipo de adeudos, para acudir luego a su ejecución en la vía civil de hacienda, máxime si ya no es empleado público, aspecto que abordaremos en las siguientes páginas.

Estas y algunas otras hipótesis causan incertidumbre sobre los alcances de la norma en comentario, y esto se debe, como ya lo dijimos, en primer lugar, a la generalidad e imprecisión de la norma, y en segundo término, a que tanto los Despachos de primera instancia como los de segunda, han resuelto los diferentes conflictos en forma meramente casuística, sin que por otro lado, exista un apoyo doctrinal nacional en este aspecto tan específico, aunque sí es un tema frecuentemente abordado en forma genérica por los autores extranjeros. (al respecto puede verse en nuestro medio, además del artículo ya citado de don Eduardo Ortiz Ortiz, otra de sus múltiples obras denominada: Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública (Costa Rica) en Revista

del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de Abogados, San José, 1981, pp. 389 y ss, así como las Actas de Comisión de la Ley General de la administración Pública, palabras preliminares, página número 10 y Acta número 102 del 1 de abril de 1970).

iv- Ambito de Cobertura del artículo 149 de la L.G.A.P.

En un principio, alrededor del año 1984, el Tribunal adoptó una tesis sobre este artículo que podríamos denominar conservadora, y como tal, no menos equívoca, cuando señaló que solamente tendrían ejecutividad las certificaciones de un ente público cuando así lo dispusiera expresamente la ley orgánica o constitutiva del respectivo ente. Dispuso el Tribunal en lo que interesa:

> *"Pero es lo cierto que en materia de pagos de sumas de dinero que adeudan los particulares a la Administración, incluyendo los créditos tributarios no existe en Costa Rica un procedimiento económico coactivo en vía administrativa, que permita a la Administración con sus propios mecanismo (sic) y el auxilio de la fuerza, si fuera del caso, proceder a cobrar coactivamente, embargando bienes, rematándolos y finalmente, cobrar el débito respectivo, ya que dichos procedimientos están reservados a los Tribunales de Justicia y, a lo sumo, se establecen medidas cautelares en protección de los créditos fiscales, cuando estén en peligro de perderse, según*

> *lo dispone excepcionalmente, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Consecuentemente el título ejecutivo, que da lugar a un proceso especialmente regulado en el Código de Procedimientos Civiles, Título VI, requiere que expresamente sea reconocido como tal por el artículo 425 ibidem, cuyo inciso 7, que interesa, dispone que l o constituirá "Toda clase de documentos que por leyes especiales tengan fuerza ejecutiva", y es lo cierto, como e l propio personero del ICE (sic) lo manifiesta, su Ley Orgánica no reconoce el carácter de título ejecutivo a l a certificación que expidan sus funcionarios.-"* (en sentido similar puede verse la resolución del mismo Tribunal número 1576 de las 8:20 hrs. del 4 de octubre de 1984)

En primer término, en Costa Rica sí existe un procedimiento económico coactivo, como lo denomina el redactor de la resolución, contemplado expresamente en el artículo 149, cuando permite incluso a la propia Administración recuperar los créditos que existan en su favor sin necesidad de acudir al Juez, acudiendo a las normas del Código Procesal Civil. La potestad allí conferida, ciertamente parece peligrosa, pero allí está, y afortunadamente en la enorme mayoría de los casos, por no decir en todos, el ente público ha acudido al Juez por la vía ejecutiva y no ha hecho uso de tal prerrogativa. Por otro lado, es cierto que el artículo 425 inciso 7) del Código

de Procedimientos Civiles (hoy inciso 6. del artículo 438 del Código Procesal Civil) solamente reconoce como títulos ejecutivos a aquellos documentos que por ley especial tengan el carácter de tales, pero ese requerimiento está cabalmente cubierto con lo dispuesto en el reiterado artículo 149, el que a la letra da clara y expresa ejecutividad a las certificaciones expedidas por la Administración Pública. Y por último, discrepamos de lo resuelto, por cuanto afirmar que tan solo son ejecutivas las certificaciones de aquellas entidades cuya normativa les otorgue ese carácter en forma expresa, es desconocer la letra misma del 149 a), que literalmente establece lo contrario. Es decir, se consagra allí una potestad general para todo ente público por el hecho de serlo, y en consecuencia, resulta de aplicación indiscriminada a toda la Administración Pública independientemente de la ley específica de cada órgano u ente.

v-: Algunos entes que han utilizado esta normativa.

Así lo han hecho incluso diversas entidades descentralizadas, con la aceptación posterior y expresa del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, tal y como ocurre en los siguientes casos:

22-) Certificaciones de la Oficina del Arroz.

La Oficina del Arroz ha hecho uso de este mecanismo, pero únicamente en lo relativo al impuesto que señala el artículo 24 de la ley citada. En él se dispone un impuesto del 0,5 sobre el precio del arroz entregado, limpio y seco, que pagan por partes

iguales el agricultor y el beneficiador. El del agricultor lo recauda el beneficiador al momento en que paga los adelantos. La parte del beneficiador conforme a las ventas. Lo interesante aquí, es que la ley no da ejecutividad en forma expresa a las certificaciones que expida dicha semiautónoma sobre esos aspectos, no obstante lo cual, aquí sí parece posible que el ente público utilice la potestad consagrada en el artículo 149, por cuanto la obligación, aunque sea en forma general, está preestablecida, según explicaremos luego.

23-) Certificaciones del Instituto Costarricense de Turismo (I.C.T.)

Al igual que la Oficina del Arroz también ha venido haciendo uso de esta potestad el Instituto Costarricense de Turismo para recuperar el impuesto del 3% sobre Hospedaje establecido en la Ley 4812, artículo 13 y en el Reglamento para la Recaudación de dicho impuesto (Decreto No 13000- MEIC de 15 de octubre de 1981 y sus reformas), puesto que en esa normativa específica no se confiere la ejecutividad a sus certificaciones.Cabalmente en la resolución número 3854 de las 9:40 hrs. del 10 de mayo de 1988, el Tribunal Superior dio por buena la certificación extendida como título ejecutivo con fundamento en este artículo 149. Señaló la sentencia lo siguiente:

> *"V- Aún y cuando se dejara de lado el ordinal recién citado ... es lo cierto que el numeral 13 de este Decreto (el mencionado líneas arriba agregamos nosotros) obliga al Instituto a proceder por los*

medios pertinentes para establecer y recuperar el impuesto no enterado a tiempo por el recaudador, y al amparo del principio iura novit curia, debe aplicarse el artículo 149 de la Ley General de la Administración Pública que establece como medios de ejecución administrativa, entre otros,... y como el órgano competente en estos casos es el auditor, el título contiene un crédito líquido de la Administración y es exigible, el título es ejecutivo y su fuerza no ha sido desvirtuada."

24-) Certificaciones del Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas

También ha hecho uso de este privilegio el Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas, que como ente descentralizado que es, certifica aquellos adeudos que en su favor existan, como producto del tributo establecido para los agricultores sobre el valor del producto final que venden o entregan, con el objeto de financiar programas de asistencia en favor de los productores agrícolas, conforme se estipula en la ley número 6916 de 16 de noviembre de 1983, en el Decreto Ejecutivo No 22259-MAG de 19 de mayo de 1993 y en el Reglamento de Cobro Para las Deudas de Agentes Recaudadores con el Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas, todos los cuales por cierto, han sido cuestionados recientemente ante la Sala Constitucional por violación a la Carta Magna, (Expediente No 3509-94, presentado el 03 de agosto de 1994). La recaudación del impuesto está a

cargo de toda persona física o jurídica, pública o privada que compre directamente al agricultor su producto para luego entregarlo a dicho ente, pues en caso contrario, el Fondo puede recuperar los dineros adeudados por los mecanismos legales correspondientes. Como puede verse, la ley del Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas no otorga ejecutividad expresa a las certificaciones que éste expida, pero consideramos que en este caso, también puede hacerse buen uso de lo dispuesto en el 149. Y así lo ha entendido el Tribunal, Sección Segunda, cuando señaló:

> *"IV.- Que visto así el panorama, procede en consecuencia, tomarse en consideración lo preceptuado en la Ley General de la Administración Pública, la que, en su artículo 3 establece que el derecho público regula la organización y actividad de los entes públicos y como en la ley de la actora no existe disposición expresa al respecto, para la recuperación de las sumas a que por ley tiene derecho, debe ser el derecho público quien lo haga, por lo que, a l amparo del artículo 149, es título ejecutivo la certificación del acto constitutivo del órgano competente para ordenar la ejecución y el cobro..." (ver resolución número 279-89 de las 8:30 hrs. del 18 de julio de 1989)*

vi-) Alcance del artículo 149 de la L.A.G.P. Materia susceptible de ser incluida en la certificación

ejecutiva.

¿ Implica lo anterior que la Administración Pública puede certificar cualquier adeudo que considere en su favor ?

La respuesta debe ser negativa, pues lo dicho hasta el momento se limita a que el 149 es aplicable a toda la Administración sin necesidad de norma específica para el órgano u ente, y que no participamos del criterio restrictivo que en algún momento expusiera el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, hoy por hoy superado. Pero precisamente no participamos tampoco de la posición abierta que señala la posibilidad para la Administración de certificar cualquier adeudo, que viene a ser la tesis antagónica a lo dispuesto por el Tribunal en 1984, señalada entre otras, en el voto transcrito. Lo curioso, es que el mismo Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda - con diferente integración interina-, parece haber adoptado también en alguna oportunidad reciente esta otra posición abierta, que reiteramos, no compartimos. En ese caso, el Tribunal mediante resolución número 561-93 de las 11:10 hrs. del 28 de setiembre de 1993, reconoce al Estado la posibilidad de hacer valer por la vía ejecutiva una certificación expedida por el Consejo Nacional de Inversiones como órgano desconcentrado del Banco Central (y aquí está el primer cuestionamiento serio a la resolución, pues no parece legitimado el Estado para un cobro es esas circunstancias) luego de que en procedimiento ordinario administrativo se resolviera el contrato de exportación y se "obligara" a la empresa a la devolución de varios Certificados

de Abono Tributario, lo que cabalmente se hizo valer por el mecanismo dinerario mediante la certificación dicha. En el considerando VI de la resolución el Tribunal se aferra a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad del acto para dar cabida a la ejecución pretendida, dejando de lado las circunstancias particulares del caso y la procedencia misma del acto, bajo la excusa de que la relación subyacente origen del título no es discutible en el proceso sumario. Y esa posición - que nos parece equivocada - es la que preocupa, pues bajo esa tesitura todo acto administrativo que establezca la existencia de un adeudo en favor de la Administración, goza del privilegio de la ejecutividad, sin importar su procedencia y carácter de lo certificado, pues basta, según lo indica la sentencia, que se de un procedimiento administrativo previo para *"... que desde el punto de vista estrictamente procedimental- formal"* se cumpla *"... con l o establecido por la ley para abrir la vía ejecutiva."* . Todo esto obliga a una breve consideración.

Consideramos que si bien es cierto, los actos administrativos poseen las características de ejecutividad, ejecutoriedad y presunción de validez (y no de legitimidad como se indica en el fallo, salvo caso de nulidad absoluta), el enfoque que se hace de ellos para el caso de comentario, obedece a una mal formación en los conceptos básicos de ese y este instituto, además de que el Juez no puede limitarse a una revisión de la esfera *"estrictamente procedimental- formal"* (al menos cuando el proceso ya está en sentencia), por más

sumaria que sea la vía, pues quien así lo haga se despoja de su esencia misma de Juzgador.

¿ Cúal es entonces nuestra posición en cuanto al alcance del artículo 149 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública ?

Al respecto, consideramos en primer término que el artículo 149 consagra la posibilidad **para el Estado y todo ente público** de certificar los adeudos que **un tercero** (administrado o ente público deudor) posea en favor de éste. Lo que excluye desde ya, la posibilidad, al menos generalizada, de que por vía de este artículo se pretenda el cobro contra servidores de la misma entidad, pues, conforme veremos, para ello deberá acudirse normalmente a los artículos 204 o 210 de la misma ley según sea el caso. En este sentido, compartimos lo dispuesto por el Tribunal Superior Contencioso, Sección Segunda cuando manifestó en la resolución número 315-92 de las 11:20 hrs. del 3 de abril de 1992 lo siguiente:

> ***"Redacta la Juez Ferrero Aymerich:*** *(...) VI.- Que de este modo, se regulan dos situaciones diversas: 1. cuando sea en contra de funcionarios públicos - artículos 203 y siguientes-, y 2. Cuando ataña a l os administrados, ajenos a la relación de servicio..." (en igual sentido puede verse la resolución del mismo Tribunal No 2541 de las 10:20 hrs. del 9 de setiembre de 1986 bajo la redacción del Juez Ramírez Camacho.)*

O como lo expresó de manera más tajante la misma licenciada

Ferrero Aymerich al salvar su voto en la resolución del mismo Tribunal número 4062 de las 9:30 hrs. del 18 de agosto de 1988, al manifestar:

> *"El otro motivo que me mueve a no darle entrada a la acción lo es por cuanto se fundamenta en el artículo 149 de la Ley General citada ut supra, cuando tal título, debió haberse expedido de conformidad con el artículo 210 Ibidem, que se da para el caso de servidores como lo es el señor Murillo Murillo en relación con la institución accionante, aplicándose erróneamente el 149 ya que no se trata de un tercero sino de un servidor" (como criterio equivocado sobre la aplicación del 149 y el tipo de procedimiento previo, puede verse el Dictamen de la Procuraduría General de la República número C- 133-80 de 13 de junio de 1980)*

Ahora bien, dejando por sentado que el artículo 149 faculta a la expedición de títulos contra terceros, nos resta aún por determinar el alcance de la disposición citada, con el fin de esclarecer cúales situaciones o supuestos pueden o no ser cobrados en la vía ejecutiva.

Aquí según quedó visto, se nos presentan dos tesis o caminos antagónicos. Uno que señala la posibilidad de que el ente público certifique el adeudo con carácter ejecutivo sólo cuando su ley especial y propia (orgánica o constitutiva) así se lo señale, lo cual es desconocer el contenido mismo del 149, según se dijo, y por ende de una sola vez, inaceptable.

Pero podría adoptarse una segunda tesis amplia en sentido de que la Administración Pública puede certificar por esta vía cualquier adeudo y de cualquier tipo, siempre y cuando exista una suma líquida y exigible, con lo cual habríamos de aceptar como títulos ejecutivos todas aquellas certificaciones expedidas en los diferentes casos expuestos al inicio de este apartado. Este es precisamente el criterio de un sector doctrinal importante y mayoritario, del cual participa don Eduardo Ortiz, quien señala al respecto:

> "... Cuando la coacción es sobe cosas la legalidad será también estricta si son determinadas e infungibles, y a la inversa, si son dinero o fungibles, en cuyo caso se trata más bien de créditos comunes. (...) La coacción por sustitución (de obligaciones de dar o hacer, de objeto fungible) es lo mismo que la ejecución civil forzosa de alcance patrimonial y recae sobre el patrimonio y, después del embargo, sobre la cosa secuestrada. Parte de la doctrina reputa posible este tipo de ejecución coactiva administrativa sin autorización expresa de ley, y lo creemos correcto, a condición de que se respeten en el trámite los principios fundamentales de la defensa, básicamente las garantías de audiencia y prueba suficiente. La razón es una y bien clara: lo que se cobra por la ejecución forzosa administrativa es lo mismo que el deudor debía; pero dado el incremento de la deuda por las costas, la audiencia

y, sobre todo, el requerimiento de pago con un plazo razonable para el mismo son absolutamente indispensables" Op. Cit. Los Privilegios..., p.117 y ss)

De lo anterior podríamos afirmar, siguiendo esta tesis, que todo ente u órgano público puede certificar con carácter ejecutivo, todos aquellos adeudos que en su favor hayan surgido como consecuencia directa de la ejecución o funcionamiento de sus competencias inherentes, lo cual puede encontrar algún apoyo adicional en las Actas de Comisión Legislativa de la Ley General ya citadas, si se leen con sumo detenimiento, y con ello estaría acorde la sentencia del Tribunal Superior supra citada sobre el reintegro por concepto de Cats, . Sin embargo, hay que reconocer que el anterior razonamiento (que nos atrevemos a afirmar con gran osadía, puede extraerse de lo dicho por Don Eduardo) es sumamente sólido desde un punto de vista lógico jurídico.

vii- Nuestra Posición.

No debe perderse de vista que el artículo 149 de la Ley General de la Administración Pública, como manifestación directa de la potestad coercitiva que es, resulta también consecuencia y reflejo de la autotutela administrativa (que también se desdobla en esta faceta), y como uno de los medios característicos y usuales de la coacción administrativa.

Esta última, que se entiende como todo el régimen jurídico de ejecución de sus efectos en cuanto trasciende a la realidad social, externa a la Administración (**Ortiz Ortiz**, op. cit., p. 99), puede clasificarse como ejecución directa y ejecución indirecta, así como en ejecución derivada de obligaciones creadas por ley y de obligaciones nacidas de acto administrativo. Se entiende por la primera ("ejecutoriedad" - sic - directa), aquella que se aplica directamente por la Administración Pública, sin necesidad de acudir al Juez para su aplicación efectiva, la que está expresamente permitida en el 149 de comentario, según se observa de su lectura rápida y que por fortuna no se ha aplicado en Costa Rica, al menos en forma generalizada en lo que se refiere a obligaciones dinerarias. Es esto lo que en estricto sentido se conoce como "ejecutoriedad", pues la doctrina generalizada coincide en excluir la indirecta como tal. Así tenemos, **Emilio Fernández Vásquez** nos define la ejecutoriedad como :

> "... la posibilidad que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración para ejecutar, por sí misma, el acto administrativo, a cuyo efecto puede valerse de diversas medidas de coerción. Significa que la misma Administración pone en práctica el acto y lo hace efectivo por medios propios y en virtud de facultades que le han sido otorgadas en forma expresa o razonablemente implícita. La ejecutoriedad presupone la ejecutividad o eficacia del acto"

(Vocablo: Ejecutoriedad. op. cit, pag. 266)

Y de manera más drástica **Montezanti** sostiene la necesidad de abandonar dicha clasificación, que él denomina "obligatoriedad impropia" (Op. Cit., pp. 30 y 120). Consideramos sin embargo, que la clasificación es válida, pues en aquellos casos en los que acertadamente (es decir de manera **lícita**) la Administración hace uso de este privilegio, aún acudiendo al Juez, pone de manifiesto su potestad de concretar la obligación, sin que pueda el Juzgador negarse a poner en marcha los mecanismos de coerción, si es que el título cumple con los requisitos formales. Es decir, ante el uso legítimo de este privilegio, el Juez está obligado a actuar, y de hecho lo hace de manera casi automática y directa, vinculado, atado (al menos en la vía sumaria) por la aparente validez de aquel título, que ha cumplido ya, de manera preceptiva, las formalidades que el mismo ordenamiento ha impuesto.

La segunda ("ejecutoriedad" -sic- indirecta o impropia) se refiere a la aplicación efectiva del acto pero con la ayuda y auxilio del Juez, es decir, es la autoridad judicial, la que en última instancia, con fundamento en el acto administrativo o conducta administrativa en general, adopta las sanciones correspondientes. En otras palabras, en este segundo caso, la administración no tiene en sus manos los medios de coerción, por lo que debe pedirlos a los órganos encargados de administrar justicia, razón por la que como hemos dicho, no se considera realmente ejecutoriedad, al menos como privilegio de la Administración, por parte de la doctrina mayoritaria. (Sobre

la ejecutoriedad directa e indirecta, puede verse **Gordillo (Agustín A.)** : Tratado de Derecho Administrativo . Tomo III, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Macchi, 1979, pag. V-30).

Por otra parte, se da la ejecutoriedad de obligaciones nacidas directamente de la ley, como lo es por ejemplo el desalojo de un sujeto de un bien afecto al dominio público, como puede ser una vía pública; o el cierre de un establecimiento porque no cuenta con ningún permiso sanitario ni patente requeridas por ley. A su vez, la ejecutoriedad de obligaciones provenientes de acto administrativo viene dada, como también se ha dicho, cuando se permite a la Administración Pública aplicar un acto del que se derivan obligaciones (por lo pronto patrimoniales) en el plano real, en contra del administrado, no como producto de una ley específica para el caso concreto en la que se establece la obligación, sino como creación básica del ente u órgano público encargado de establecer la responsabilidad y por ende la obligación de uno o varios individuos señalados también en el acto.

Está claro que el artículo 149 de nuestra Ley General de la Administración Pública permite una ejecutoriedad (o mas bien ejecución forzosa) directa; en tanto que una interpretación amplia del mismo permitiría afirmar que también permite la ejecución de obligaciones nacidas de simple acto administrativo, **cuando éste se dicte dentro de la competencia esencial del órgano o ente público**, pues así parece estimarlo don Eduardo Ortíz en las obras citadas y en las Actas Legislativas sobre el Proyecto de la Ley, interpretación a la

que parece haberse plegado (aunque de manera inconciente) la sentencia ut supra sobre los Cats y el criterio de algunos de nuestros jueces. Más aún, esta tesis podría verse reforzada por el hecho de que de acuerdo con la misma letra de la ley (art. 147), para la ejecutoriedad de las obligaciones nacidas de la capacidad de derecho público de la Administración también se aplican lo medios de ejecución de los actos administrativos del artículo de comentario. En este artículo 147 hay dos cosas de interés para nuestros efectos, una que como derechos de la Administración provenientes de su capacidad de derecho público, pueden y casi que deben entenderse, los derechos surgidos directamente de la ley, lo cual nos lleva de seguido a la segunda, a ellas también se aplican los medios de ejecución del acto administrativo, que no son otros que los del 149. Es decir, los medios de ejecución del 149 están referidos esencialmente a la ejecución forzosa de actos administrativos, aplicables por vía de extensión (por disponerlo así el 147) a las obligaciones nacidas de la esfera pública del ente u órgano.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, cabe entonces cuestionarse: ¿ es que por medio de un acto administrativo común pueden **crearse directamente** (como nacidas eminentemente del fuero administrativo) obligaciones dinerarias en contra del administrado particular, para ser ejecutados posteriormente por la vía sumaria del proceso ejecutivo ?

Con todo y los elementos expuestos líneas arriba, creemos que la respuesta debe ser negativa. La doctrina mayoritaria

sostiene la improcedente ejecutoriedad del acto administrativo por vía de principio, y para tal privilegio, con todo acierto, exigen una ley que la autorice (pues los privilegios o potestades de imperio para la Administración sólo pueden nacer de la ley, nunca de norma inferior - arts. 59.1) y 12. 2) de la Ley General de la Administración Pública). Pero aún partiendo de que la ley la otorga, se sostiene también con acierto, que tal cumplimiento forzoso no puede ser dado en forma general e irrestricto para todo acto administrativo, sino que se requiere de precisión legal para cada caso concreto. Y aquí cabe citar las palabras del francés **Georges Vedel** cuando señala:

> "Sería un error creer que, por definición, una decisión ejecutoria puede ser ejecutada por la fuerza. Es cierto que tiene fuerza ejecutoria por sí misma, pero esto no equivale en absoluto a afirmar que puede, en cualquier caso, ser objeto de ejecución forzosa. Por consiguiente, debe quedar bien claro que el primer efecto y, desde el punto de vista jurídico, efecto esencial de una decisión ejecutoria es el modificar unilateralmente el ordenamiento jurídico. Pero este efecto, que es uno de los aspectos de la ejecución de la decisión, no supone por sí mismo el empleo de la fuerza... la ejecución forzosa supone a menudo un atentado contra los derechos fundamentales (libertad individual, propiedad, inviolabilidad del domicilio, etc); ahora bien, es un principio de toda sociedad civilizada que tales atentados no puedan

producirse más que con el control y con la autorización de un juez" (Derecho Administrativo, Traducción a la Sexta Edición Francesa, Madrid España, Editorial Aguilar, 1980, p.p. 165 y ss.)

Esta posición prácticamente generalizada en la doctrina francesa en la vieja pero aún vigente sentencia del Tribunal de Conflictos del 2 de diciembre de 1902, *Societé inmobiliére de Saint Just* , en donde el comisario del Gobierno, Romieu, sistematizó en sus conclusiones las condiciones precisas para la ejecución por la coerción, a saber:

"1-) La decisión a ejecutar debe tener su base en un texto de alcance general.

2-) La Administración debe estar enfrentada a una resistencia activa o pasiva; si no, el recurso a la coerción sería una vejación inútil.

3-) La resistencia no puede ser vencida por otros medios, sea que los textos no prevén sanciones penales ... ni sanciones administrativas... sea que las sanciones ya aplicadas permanezcan ineficaces" (Al respecto puede verse además de la obra citada, al autor **CHAPUS (René):** Droit Administratif Général, 2o Edition, Paris, Editions Montchrestein, 1990, pags. 811 y ss., así como **RIVERO (Jean):** Derecho Administrativo, Traducción a la Novena Edición, Caracas, Venezuela, Instituto de Derecho Público, 1984, p.p. 115-116)

Ya también en España, los maestros **Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández**, critican la "indebida generalidad" con el que se redactó el numeral 102 de su Ley de

Procedimiento administrativo (similar al nuestro) y de seguido citan el principio inverso que rige en el sistema francés (y también en el italiano), según el cual:

> "la ejecución coactiva de sus actos por la propia Administración sólo procede en caso de autorización legislativa específica y en defecto de cualquier otro procedimiento coercitivo establecido (incluido el de sanción penal o administrativa a la desobediencia ó, según precisó el arrét del Consejo de Estado *Societé inmobiliére* de Saint- Just de 1902, cuya doctrina se mantiene hasta hoy..." (Op. Cit.,pp. 658-659).

Creemos que entre la confrontación entre autoridad y libertad, debe protegerse a esta última, sometiendo los poderes de la Administración a la ley, tal y como lo señala el propio don Eduardo Ortiz y el principio básico de legalidad. La coacción administrativa está sometida a la ley y debe estarlo, pues nada hace pensar lo contrario, antes bien, por tratarse de afectación del particular, todo apunta a su regulación (que la permita y autorice) por vía legal, por respeto básico al principio de legalidad. En este sentido, señala el mismo maestro y jurista nacional de cita, las siguientes palabras a todas luces reveladoras:

> "No hay principio general que autorice a la Administración para usar la violencia en el ejercicio de sus derechos o ante el incumplimiento por el ciudadano de sus deberes para con ella. La única intervención coactiva permitida es la que lo está

caso por caso, inequívocamente autorizada por norma escrita. De este modo la regla general es que la Administración no puede emplear la fuerza para ejecutar sus actos o ejercer sus derechos y exigir al ciudadano el cumplimiento de sus deberes administrativos, salvo que una norma le permita hacerlo expresamente o que se den especiales condiciones..." (Op. Cit. Los Privil..., pag. 112.)

Con esto, el Lic. Ortiz Ortiz viene a hacerse eco de lo señalado por la jurisprudencia francesa al respecto, en donde según se indicó, se ha permitido la ejecución del acto de oficio, sujeta a dos grandes principios: a) cuando la ley le da a la Administración el poder de actuar de oficio, la Administración no lo posee sino en la medida estricta en que la ley se lo reconoce, y b) cuando no hay ley reglamentando el punto, la Administración no puede asegurar ella misma la ejecución de su orden o de su prohibición sino cuando no hay sanción penal, ni sanción civil, e incluso ni sanción administrativa. (Lefébure, citado por **González Pérez**. op. cit, pag. 368). Así don Emilio Fernández (op cit., pag.108-109), nos señala como requisitos para el ejercicio de la coacción los siguientes:

"1) Existencia de un acto administrativo notificado al particular interesado. 2) Incumplimiento de la obligación por parte del destinatario del acto administrativo. 3) Apercibimiento por la Administración que de no cumplirse la obligación se

procederá a su ejecución forzosa. 4) **Existencia de ley que autorice a utilizar la coacción administrativa, para lo cual deber tenerse en cuenta que se trata de medidas sumamente graves - ya que inciden sobre la propiedad y la libertad de los administrados- y que requiere que la autorización sea específica para el caso de que se trate.** 5) Los medios de coacción sólo podrán ser los previstos por la ley para el fin de que se trate; es decir que han de ser medios lícitos... 6) Los medios de coacción utilizables deben ajustarse a los principios generales del derecho... 7) La coacción debe cesar en el momento en que se logra el cumplimiento del acto." (la negrita no es del original)

Claro está, contra todo lo dicho anteriormente, podría esgrimirse simple y llanamente la existencia misma del artículo 149 a) de la Ley General, con lo que podría afirmarse, se cumple con el principio de legalidad y se obtiene la disposición legal requerida para esa ansiada ejecución forzosa (y en especial de toda obligación dineraria). Pero con todo ello, seguimos considerando, tal y como ha quedado plasmado, que tal autorización irrestricta y generalizada no es posible, pues este importante plus en favor de la Administración requiere de regulación precisa y expresa para cada caso concreto. Aquí conviene citar, por lo tajante y claro de sus manifestaciones, las palabras de don **Agustín Gordillo**, quien con su característica elocuencia nos señala:

"La ejecutoriedad "propia", con el alcance de otorgar a la administración el uso de la coerción para ejecutar por sí sus actos, aún cuando se encuentre en contraposición a derechos de los particulares, sólo puede razonable y constitucionalmente otorgarse en casos determinados, a texto expreso; nunca podría admitirse, sin incurrir en arbitrariedad, que una norma legal general diera a la administración una suerte de potestad omnímoda e indiscriminada para usar de la coerción de la manera que discresionalmente le pareciera más oportuna, en cualquier caso." (Op. cit., pag. V-32)

Pero es que aún con independencia de lo dicho anteriormente, tenemos que bajo la doctrina, y ante todo por nuestro ordenamiento jurídico positivo, existen materias que solamente pueden ser reguladas por ley, es este el conocido principio de reserva legal, que puede ser absoluto o relativo, según sea la materia específica y la regulación delegada que de ella pueda darse. Y de acuerdo con nuestro sistema jurídico, tanto la propiedad, como las penas y sanciones, son materia cuya regulación se encuentra restringida a la ley de manera absoluta (al respecto véase el contenido de los artículos 39 y 45 de nuestra Constitución Política; 19 y 124 de la Ley General de la Administración Pública y 6 del Código

Tributario). Ahora bien, está claro que el embargo, las multas e intereses (los legales al menos), son sanciones (civiles, claro está, y aún cuando se pretenda encubrirlas con el argumento de que no lo son, porque únicamente buscan compeler al deudor a cumplir; es esta precisamente una de las finalidades esenciales de la sanción: evitar la acción o en su caso, la omisión), y que los bienes muebles, inmuebles, salarios, cuentas corrientes, de ahorros, derechos telefónicos, etc., constituyen entre otras cosas, el patrimonio o propiedad de una persona. Y si esto es así, como efectivamente lo es, tenemos entonces que no pueden aplicarse multas, intereses legales, embargos y demás sin previa ley que lo autorice, como tampoco podría afectarse la esfera patrimonial de un persona sin ley que así lo disponga expresamente; ergo, no puede la Administración por sí y ante sí, o bien acudiendo al Juez en la vía ejecutiva, afectar el patrimonio (propiedad) particular e imponer además sanciones, cuando no están específicamente previstas por la ley para el caso también tipificado en aquella norma. Es esto, incurrir en semejante antijuricidad prevista y prohibida, lo que cabalmente haría el ente u órgano público con una interpretación amplia del artículo 149 como la señalada, pues sería la propia Administración la que, creando ella la obligación

plena en sí misma, procedería a efectuar o solicitar al Juez el embargo y remate de bienes, lo cual implicaría suprimir o afectar la propiedad privada con motivo del dicho y acto de la sola Administración, lo que sería a todas luces inconstitucional. La Administración, acudiendo o no al Juez en la vía ejecutiva, carece de la facultad de afectar bienes de terceros administrados e imponer sanciones cuando le plazca y en las circunstancias que ella elija, so pretexto de la ejecutoriedad de sus actos o de la coacción administrativa, pues debe insistirse, para esto se requiere ley específica que establezca los supuestos concretos. Nuestra tesis podría catalogarse de ortodoxa e inclusive de anacrónica u obsoleta, por atentar contra las necesidades de la Administración, los tiempos modernos y la abrumadora mayoría doctrinaria, pues no falta quien señale el carácter "espiritualista" de las potestades administrativas, las que bajo esta óptica, pueden estar autorizadas por el ordenamiento jurídico general y no solo por la ley, como afirma la teoría denominada "formalista" (que de alguna forma es la que seguimos en este texto). Pero es interesante observar, que aún los más férreos postulantes de esta posición amplia o abierta, reconocen la necesidad de ley para el caso de que se pretenda aplicar sanciones. Así tenemos que el autor

español **Juan Miguel de la Cuétara**, como uno de sus máximos exponentes, también reconoce que: "En fin, se da por supuesto que en muchos campos, cuando la intervención administrativa alcance derechos y libertades garantizados a los particulares (como ocurre con el patrimonio o propiedad de aquellos, agregamos nosotros), será necesaria la habilitación por ley formal, lo que se ha reiterado una y otra vez para la potestad sancionadora ..." (Las Potestades Administrativas. Primera Edición. Madrid, España, Editorial Tecnos, pp. 228-229).

Y aquí es donde precisamente podría replicarse a nuestra tesis nuevamente, que esa autorización legal es ni mas ni menos que la contenida en el artículo 149 de comentario, porque allí autoriza el embargo y remate directo , o si lo desea, por mayoría de razón, acudir al Juez. Sin embargo, rechazamos de manera enfática tal razonamiento, pues en el 149 no se están dando medidas sancionatorias, ni la afectación de la propiedad para un caso o casos específicos, sino para una situación general la que deberá determinar la Administración, ella por sí y ante sí, para cada caso concreto, estableciendo incluso, la causa misma de la obligación, es decir, cuando aquella estime que determinado administrado es su deudor por la causa que unilateralmente indique. De modo que la ley estaría fijando el mecanismo y la vía para la recuperación de lo adeudado (y hasta allí todo bien), pero no sería la misma ley la que establece cúando y en qué supuestos opera, dado que por ser

estos generales e imprecisos (acorde con cada situación de hecho que se presente), se transfieren a la Administración Pública, con lo cual se deja en nada la reserva legal exigida para la materia. En otras palabras, de seguirse una interpretación tan amplia como la pretendida, estaríamos vaciando de contenido el 149 para que sea la autoridad pública la que lo llene en su totalidad, y esto no es ni mas ni menos que inconstitucional. Y en este aspecto cabe recordar las valiosas palabras del autor francés ya citado **Jean Rivero**, el que al respecto nos señala:

> "Por el contrario, no parece que la administración haya adquirido el poder de autorizarse ella misma por vía reglamentaria (ni mucho menos por acto administrativo, agregamos nosotros), para recurrir a la ejecución forzada: este recurso, en efecto, conlleva necesariamente una limitación a las libertades públicas o a la propiedad, que el artículo 34 mantiene en el dominio legislativo." (Op. cit., pag. 114).

Nótese que hemos insistido en que sería igualmente inconstitucional que permita crear la obligación el ente público para ejecutoriarlo en su seno, como si opta por ejecutarlo ante el Juez. Esto último porque realmente da igual, en vista de que en la vía ejecutiva el Juez se encuentra sujeto, atado, frente a un título que por ser ejecutivo, tiene incorporado el derecho, y ante el cual (si reúne todos los

requisitos formales), no puede negarse a despachar ejecución y decretar los embargos para su posterior remate. En este segundo supuesto, la Administración se estaría valiendo de un "Juez", funcionario judicial, para ejecutar la obligación, no para declararla, ni mucho menos constituirla, por lo que sería igualmente contraria a nuestra norma fundamental.

Sobre este aspecto concreto, es nuestro criterio que el artículo no permite una creación irrestricta de títulos para cualquier supuesto de hecho en el que la Administración considerándose acreedora de alguno sus administrados, emita un acto administrativo estableciendo el crédito, tal y como lo han querido interpretar y aplicar algunos entes, amparados a los principios (o características como las considera algún sector doctrinal) de ejecutividad, ejecutoriedad y presunción de legitimidad del acto. Es cierto que el acto administrativo goza de tales privilegios, pero es necesario destacar también, que no todo acto puede valerse de ellos, puesto que los absolutamente nulos carecen totalmente de dicho fuero. Es decir, la presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad sólo se aplica a los actos válidos o anulables, no a aquellos que transgredan en forma grosera el ordenamiento jurídico. Y es necesario recalcar esto, porque en nuestro criterio el artículo 149 inciso a) solamente permite la certificación de créditos en favor de la Administración Pública para aquellos supuestos en los que la obligación como tal, esté claramente preestablecida en la ley (en sentido estricto) o por resolución judicial previa. Pero no puede el Estado o un ente

público, valiéndose de este mecanismo de ejecución forzosa, crear obligaciones totalmente nuevas para el tercero administrado sin norma legal previa o disposición judicial de respaldo que imponga la obligación misma. En otras palabras, **la Administración Pública, por vía del 149 de la LGAP sólo puede certificar aquellos créditos que además de líquidos y exigibles, estén predeterminados (al menos en forma genérica) en una ley o en una resolución judicial previa, salvo que los mismos posean un procedimiento (administrativo o jurisdiccional) específico para su exigibilidad y recuperación.** Recuérdese que este artículo se refiere a los medios de ejecución de obligaciones en favor de la Administración **ya existentes**, los que pueden ser patrimoniales, o de dar, hacer, tolerar o no hacer, que en algunas oportunidades pueden ser cumplidas por un tercero, mientras que en otras sólo en forma personalísima por el obligado. Y el artículo debe verse además en concordancia con el artículo 147 de la misma ley en cuanto se refiere también a los derechos (ya adquiridos) de la Administración. Lo que queremos decir es que la disposición bajo análisis pretende ejecutar tan solo los derechos de la Administración, los que para ser tales, tienen **que estar preconstituidos o declarados aunque sea en forma general**, pues no pueden ser producto de la mera voluntad administrativa, por más pública que sea. De modo tal que un ente público, no puede valerse de esta disposición para burlar el necesario fallo jurisdiccional que se requiere en muchos casos para el establecimiento previo de la responsabilidad del administrado,

pues con ello estaría afectando los derechos subjetivos patrimoniales de un tercero en forma unilateral e imperativa, con clara violación del bloque de legalidad, dada la inexistencia de norma legal expresa que se lo autorice (recuérdese el contenido de los numerales 11.2), 131 y 132 de la Ley General de la Administración Pública). Mas sencillo, en esta materia específica, y solo en esta, se trata de la ejecución de obligaciones dinerarias establecidas directamente en la ley (aunque sea de manera general) o en resolución judicial previa. Recuérdese que la ejecutividad de un documento solo puede ser dado por ley (reserva legal), y ésta no puede facultar, ni siquiera a un ente público, para la creación irrestricta de títulos bajo presupuestos fácticos plenamente abiertos a determinación del acreedor.

Lo que sí podría darse, es que, establecida claramente la obligación para el administrado en la ley, dada la generalidad de la misma, se requiera su concreción (para efectos de liquidez) a través de un acto administrativo, el que gozará, allí sí, de los principios antes mencionados, puesto que si no existe la previa obligación legal o judicial, el acto que certifique el aparente crédito es nulo de pleno derecho, por lo que consecuentemente no es ejecutivo, ni ejecutorio ni presuntamente legítimo. Es en ese sentido que debe entenderse la expresión *"acto constitutivo del crédito"* que utiliza el mismo numeral 149. El acto puede constituir el crédito en cuanto lo perfecciona, convirtiéndolo en líquido y determinado para uno o varios sujetos pasivos específicos, pero nunca en

cuanto a su creación misma. Es decir, cuando la ley utiliza dicha expresión, se refiere a la posible concreción del crédito y muchas veces, a la individualización del sujeto pasivo deudor para efectos judiciales. Es decir, se refiere a la facultad de hacer cierta la obligación ya nacida, distinguiéndola de cualquier otra originada en la misma causa. (**Constitutivo**, según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición, 1984, pag. 365, significa "... lo que constituye una cosa en el ser de tal y la distingue de otras.). De hecho, a estos supuestos están referidos los ejemplos que se dan en las Actas de la Comisión Legislativa que se encargó de estudiar y aprobar la actual Ley General de la Administración, ya citadas páginas arriba, en donde se alude esencialmente a ejemplos en materia tributaria, en la que como es obvio está predeterminada la obligación por vía legal de manera genérica en cuanto sujeto pasivo y monto específico, lo que de algún modo viene a ratificar nuestra posición, la que según se ha visto no choca el modo alguno con la mayoría doctrinal francesa, española, ni latinoamericana (a través de los autores citados), como tampoco lo hace con la doctrina italiana, en la que no por casualidad se analiza la ejecución forzosa de la Administración en materia de obligaciones dinerarias, como un instituto paralelo al ámbito tributario (al que por supuesto no lo restringimos nosotros). Así el autor **RENATO ALESSI** acepta y comenta la posibilidad de una ejecución de oficio directamente por medio de los órganos administrativos sobre bienes muebles **del deudor de impuestos**, con la única garantía de la vigilancia

de la autoridad judicial, excluido el juicio declarativo. Y así menciona como ejemplos algunas leyes relativas a impuestos directos e indirectos. Nótese además, que en aquel país la ejecución forzosa directa sobre se admite sobre bienes muebles, ya que en materia de inmuebles la Administración siempre está obligada a acudir al Juez (ejecución indirecta). (Véase la obra del autor citado: Instituciones de Derecho Administrativo, Barcelona, España, Traducción a la tercera edición italiana, Editorial Bosch, 1970, Tomo I, pag. 207 y siguientes, Tomo II, p.p. 541-542.)

Se habrá observado que consideramos viable la creación de la obligación directamente de la ley (al menos en cuanto deber genérico de cubrir una suma de dinero, eventualmente indeterminada en la norma), o, por parte de un Juez, pues en este segundo caso, es éste el que investido de su autoridad, está llamado a declarar o constituir el derecho y por ende la obligación, a favor y en contra de los sujetos públicos y privados, según se entiende por mero principio, pero además se extrae de los artículos 9, 10, 35, 39, 41, 42, 49, 152 y especialmente el 153, todos de la Constitución Política, artículos 1, 5, 7, 105, 109, 110, 113, 115 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en general de un sinnúmero de disposiciones legales dispersas en nuestro ordenamiento.

Esta tesis nuestra, parece haber sido el criterio que ha imperado incluso en algunos casos aislados de los muchos que ha resuelto el Tribunal Superior, y en la mayoría de votos salvados de la Licenciada Sonia Ferrero Aymerich. Si bien es

cierto en ellos no se establece de manera clara y expresa este mismo razonamiento, sí parece extraerse del rechazo mismo del título como tal, en el que se intuyen los límites propios de la norma en mención. Así tenemos el voto salvado de la licenciada Ferrero Aymerich en la resolución del Tribunal Superior número 3929 de las 8:30 hrs. del 19 de junio de 1989 en el que rechaza como título ejecutivo la certificación expedida por el Poder Judicial para el cobro a un tercero de los daños y perjuicios ocasionados a un vehículo de ese Poder, luego de emitida la resolución penal correspondiente en la que se omitió pronunciamiento acerca de la condenatoria en daños y perjuicios, pues ni siquiera se le imputó responsabilidad a ese tercero. En este caso, aún y cuando se utilizan como argumentos para rechazar el título como ejecutivo, la ausencia de un debido proceso previo a la certificación y la inexistencia de una suma líquida y exigible, es lo cierto que la Juzgadora parece intuir la imposibilidad jurídica de certificar con carácter ejecutivo en dicho supuesto. De hecho su posición se convierte posteriormente en mayoría y queda plasmada de manera aún más clara en el Voto número 180-89 de las diez horas treinta minutos del dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, en donde se indicó lo siguiente:

"Redacta la Juez León Feoli; y,

CONSIDERANDO:

(...) Si bien es cierto que la Administración Pública, tiene facultades para emitir títulos ejecutivos como medios de ejecución para resarcirse

> de los daños y perjuicios sufridos, es igualmente cierto, que esta potestad que le confiere l a ley no es irrestricta, pues para ello, deben seguirse y respetarse las pautas que al efecto se disponen ... A ello debe agregarse, como bien se expone en el voto salvado de la resolución 3929 de las ocho horas treinta minutos del dieciséis de junio del año anterior, que el demandado, en la sentencia de tránsito, - en ninguna de las dos instancias- se le condenó a pagar los daños ocasionados al vehículo del Poder Judicial sin que sobre ello se pidiera adición o aclaración alguna, y desde luego, tampoco en esa sede se estableció una suma líquida que en todo caso no eximiría que posteriormente y sin el debido proceso, pudiera ser certificada por la autoridad administrativa, contraviniendo así el numeral 149. 1 ibidem... arribando por mayoría a la conclusión de que no se está en presencia de un título ejecutivo, al no cumplir con los requisitos mínimos que la ley establece para su emisión" (en igual sentido puede verse la resolución del mismo Tribunal No 70-90 de las 15 horas del 22 de marzo de 1990.)

De lo transcrito pueden rescatarse varios aspectos de interés. En primer término, el Tribunal señala en forma expresa y tajante, en coincidencia con nuestro criterio expuesto líneas arriba, que la potestad de certificación de la Administración Pública no es irrestricta, con lo cual establece la existencia

de límites, los que si bien es cierto no se definen en forma precisa, sí confirman la imposibilidad de la Administración de certificar como título ejecutivo cualquier suma en la que se considere acreedora. Por otro lado, en la resolución de comentario parece quedar patente, la necesidad de que en aquellos supuestos en los que la obligación no está preestablecida en la ley, se requiere el pronunciamiento judicial previo que imponga las responsabilidades. En el caso, si bien es cierto se indica la insubsistencia del procedimiento administrativo previo, no se da la posibilidad de su posterior cumplimiento, pues al final de la resolución se remite a las partes a la vía ordinaria *"... sin perjuicio de que se dilucide la controversia en la vía declarativa"*, reza la sentencia en mención. ¿ Por qué a la vía declarativa si bien podía cumplirse con el debido proceso y valiéndose de la potestad señalada (en la versión irrestricta) iniciarse un nuevo ejecutivo, aunque no hubiera sentencia penal ? Todo ello, nos hace pensar que de manera implícita el Tribunal considera en el caso concreto que no es posible certificar y cobrar por vía ejecutiva, pues el 149 no es aplicable a dichas hipótesis. Es decir, antes que la omisión de condenatoria a los demandados en el proceso penal o la omisión del debido proceso, parece imperar en la mayoría del Tribunal, una fuerte duda sobre la posible certificación del supuesto adeudo en la situación particular.

Pero si alguna duda existe en la cita anterior, queda despejada con mayor claridad en la resolución del mismo Tribunal número 4062 de las 9:30 hrs. del 18 de agosto de 1988,

en la que además de examinarse la relación subyacente de la certificación misma (lo cual es revelador, pues se trata también de una demanda contra tercero por responsabilidad luego del choque de un vehículo propiedad de la CCSS) se indica lo siguiente:

"Redacta la Juez Miriam Anchía; y,

CONSIDERANDO:

(...) Pero no obstante lo anterior, el título no puede emitirse por sumas creadas o fijadas en forma unilateral y discrecional por la entidad acreedora, tiene que existir algún elemento probatorio idóneo que la respalde y le dé fundamento."

Por último, interesa mencionar en este aspecto, por su claridad e importancia, lo dispuesto en la resolución No 491-89 de las 14:55 hrs. del 2 de noviembre de 1989, en la que a nuestro modo de ver, se puntualiza de una vez por todas, la imposibilidad de la Administración para certificar por vía del 149 cualquier adeudo cuya existencia estime en su favor, y de alguna forma - aunque sin decirlo de manera expresa- deja entrever el verdadero alcance del artículo cuando lo restringe, para el caso concreto, a los recibos de arroz extendidos al productor por el beneficiador, por así disponerlo expresamente la ley (artículo 27 de la Ley No 7014 de 28 de noviembre de 1985, ya citada páginas arriba); es decir, a aquellos casos en los que preexista la obligación como tal. De no ser así, no cabría ningún fundamento para rechazar la ejecutividad de la certificación que se aportó, salvo por la ausencia del debido

proceso, que tan solo se utiliza como argumento adicional y accesorio de la conclusión ya vertida. Señala la resolución de comentario lo siguiente:

"Redacta la Juez Ferrero Aymerich;y,

CONSIDERANDO:

(...) Que luego del análisis de lo transcrito, es que se arriba al convencimiento de que, la Oficina del Arroz, sí está facultada para emitir títulos ejecutivos, empero únicamente, en el caso contemplado en los artículos 27 de la Ley y 57 del Reglamento, no así por el no pago del incremento introducido por Decreto 17811 de reiterada cita. El admitir el título base de esta acción, implicaría violentar abiertamente la ley y crear para los llamados a cumplir con las obligaciones en ellos consignados, l a inseguridad. Al compartirse plenamente lo resuelto por el Tribunal Superior Primero Civil en su resolución número 2252 de 3 de abril de 1981, este órgano se permite transcribir en lo que interesa, el pronunciamiento emitido en esa oportunidad: "Legalmente no es posible crear títulos ejecutivos a base de analogía, a fortiori a través de cualquier medio de los que existen para interpretar o integrar el derecho, porque ese camino pondría en entredicho la seguridad jurídica, en ese caso del deudor, porque atenido a que no firmó ningún documento con ese carácter, de pronto se vería en la condición de

ejecutado; con ello no se trata de impedir al acreedor ejercitar su derecho, sino simplemente de que no es la vía en donde puede discutirlo. "Si bien la Ley General de la Administración Pública, permite la emisión de título ejecutivo, lo será siempre y cuando así lo disponga la respectiva ley que regula a un determinado ente, mas no a la ligera y sin respaldo jurídico alguno. Aún partiendo del supuesto de que la Oficina acreedora podría hacer uso sin más, de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 149 de la Ley General citada, se echa de menos también, el requisito contemplado en el 150 Ibidem, motivo ese solo que le restaría la fuerza y carácter que pudiera contener el documento en estudio."

La resolución reviste más importancia de la que parece, pues además de lo dicho, abre un portillo claro para todo ente público que pretenda recuperar lo que le adeude un administrado particular, siempre y cuando, el crédito esté predeterminado en la ley o en resolución judicial firme.

De allí que nuestro máximo órgano jurisdiccional en la actualidad, la Sala Constitucional, haya insinuado también los verdaderos contornos del instituto de comentario, cuando al momento de resolver un recurso de amparo contra un acto administrativo en el que se pretendía la devolución de sumas de dinero aparentemente pagadas en forma incorrecta a diferentes abogados señaló lo siguiente:

"... dichas sumas pasaron a formar parte de la propiedad del accionante, cuya inviolabilidad se encuentra garantizada en virtud del principio que establece el artículo 45 de nuestra Constitución Política. Por ello, resulta claro que la Administración no puede incautar los bienes del recurrente sin una orden o sentencia judicial anterior que sirva de fundamento a dicha acción. La procedencia o improcedencia de que el INCOP reclame el referido pago tendrá necesariamente que ser establecida ante las autoridades jurisdiccionales competentes, ... Esta Sala considera que únicamente en virtud de una sentencia firme que declare la existencia de un crédito líquido a cargo del accionante y a favor del INCOP, podrá la Administración hacer uso de los medios de ejecución forzada que le otorga nuestro ordenamiento jurídico ya que se estaría ante las circunstancias previstas en el artículo 149. 1 de la Ley General de la Administración Pública. Si el INCOP procediera a hacer uso de sus facultades ejecutivas antes de que se haya determinado en la vía judicial la procedencia del cobro, se estaría lesionando el derecho de propiedad que ya adquirió el accionante con respecto a los montos que le fueron pagados y, tratándose de un embargo, se violaría su derecho de propiedad respecto a los bienes embargados" (el subrayado no es

del original. Véase el Voto No 498- 91 de las 15 hrs. del 1o de marzo de 1991).

De hecho, esta tesis nuestra, ya ha sido adoptada por algunas de la resoluciones de las Alcaldías Civiles de Hacienda a nivel de "machote", entre las que pueden citarse la de las 9:00 hrs. del 12 de julio de 1994 (Exp. 7406-94. El Estado c/ M.S.V.) y la de las 9:00 hrs. del 14 de julio de 1994, en la que se indicó:

> *"... partiendo del principio de que los hombre son reputados responsables de sus actos, la Ley General de la Administración Pública contiene disposiciones que establecen la responsabilidad del administrado ante la propia administración (art. 149 LGAP) y la responsabilidad del servidor público por los daños causados a la administración (art. 210 LGAP), para ambos supuestos se prevé como medio para recuperar los daños causados a la administración la ejecución forzosa mediante la instauración de un proceso ejecutivo que tiene como base la certificación expedida por el órgano competente para ordenar la ejecución. Sin embargo la certificación tiene que reunir ciertas características para ser considerada título ejecutivo en primer lugar debe originarse en un crédito de la administración que a la fecha de su emisión sea una suma líquida y exigible, además lo que se certifica se debe* ***circunscribir a la esfera de***

las competencias específicas del ente emisor, pero sobre todo se debe tratar de una obligación que se encuentre preconstituída en la ley o fundada en una resolución judicial, toda vez la consecuente sanción es materia de reserva legal. *En la especie se pretende que la accionada que dejó de ser funcionaria del MINISTERIO DE EDUCACION, cancele una obligación que no está- preconstituida por ley y que no puede ser constituida por acto administrativo por razones de legalidad, ya que esto transgrede la esfera de competencia de la administración..."*

viii-Necesario Cumplimiento de un Procedimiento Administrativo Previo. Debido Proceso.

Para la emisión de títulos conforme a este artículo 149, el Tribunal Superior ha exigido en algunos casos - no en todos - el necesario cumplimiento del procedimiento administrativo ordinario establecido en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, a fin de dar cumplimiento al principio básico y superior del debido proceso. La exigencia parece válida, pues si bien es cierto la obligación está preconstituida, la mayoría de las veces requiere de concreción mediante un acto administrativo específico, por lo que con ello se afecta la esfera patrimonial del administrado (para este caso público o privado), convirtiéndose en necesaria la oportunidad de defensa para él. Así lo ha dispuesto el Tribunal, entre otras, en la resolución

número 315-92 de las 11: 20 hrs. del 3 de abril de 1992 en la que señaló:

> *"**IX.**- Que si bien el estudio realizado por el órgano contralor fue exhaustivo, la mayoría de este Tribunal concluye, que se incumplió con el procedimiento ordinario que establece la Ley General de la Administración Pública, ya que no consta en autos que se haya realizado el "debido proceso", como lo ordena la ley para poder hacer uso luego, de lo establecido por los artículos 146 y siguientes de ese cuerpo normativo. No se está negando por esto, en modo alguno, la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, mas es del caso que para cobros como el que se hace en esta vía, es menester la culminación del procedimiento en la forma dicha en acápites precedentes." (en igual sentido pueden verse las resoluciones del mismo Tribunal 491-89; 289-92 y 561-93)*

Aquí es preciso enfatizar que el debido proceso sí se ha exigido en forma generalizada para las certificaciones expedidas contra funcionarios públicos a los que se les impone la obligación de restituir los daños y perjuicios irrogados a la Administración como patrono, lo cual es verdaderamente plausible. Pero como se ha dicho, no ha sido esa la misma tónica entrándose de las certificaciones del 149. Incluso, recién se ha cuestionado con vehemencia la necesidad de requerir el debido proceso para estos diferentes títulos

amparados a una ley especial, como ocurre con el caso concreto de la Caja Costarricense de Seguro Social, según dijimos páginas atrás. Consideramos al respecto que la respuesta debe ser afirmativa, pues al igual que con el 149 de comentario, con las certificaciones ejecutivas dispuestas por ley especial se afectan de igual manera los derechos subjetivos del particular. De hecho, la Caja Costarricense, para continuar con ese caso particular, tiene prevista la oportunidad de defensa del patrono de previo a expedir la certificación mediante un reglamento (de dudosa constitucionalidad y legalidad, en razón de su naturaleza autónoma pese a la materia que regula) denominado "Reglamento del Procedimiento Administrativo Para Atender la Impugnación Actuaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con los Patronos" , aprobado por la Junta Directiva de dicho ente en el acuerdo Segundo del artículo 6 de la sesión No 6042, celebrada el 7 de agosto de 1986. Ciertamente esa norma de alcance general adolece de gran cantidad de omisiones, confusión e imprecisiones (quizá por su vieja promulgación), pero lo importante de esto es que la propia entidad descentralizada reconoce con esto la necesidad de otorgar el debido proceso a los mismos patronos.

Pero al igual que la Caja, también encontramos que en los cobros de impuestos de la Tributación Directa también se da una previa audiencia y oportunidad de defensa al contribuyente, tal y como se disponen en los artículos 160,162 y concordantes del Código Tributario.

En fin, a nuestro modo de ver, queda clara la necesidad de

un debido proceso previo a la emisión de este tipo de certificaciones con carácter ejecutivo.

ix- Necesidad de las Intimaciones Previas.

En punto al procedimiento previo, existe un criterio jurisprudencial de nuestro Tribunal Superior con el que diferimos abiertamente. Y es en el sentido de que previo al cobro judicial con fundamento en la certificación dicha, y luego de cumplido el procedimiento administrativo, deben realizarse las dos intimaciones al administrado, conforme lo señala el artículo 150 de la misma Ley General. A dicho el órgano jurisdiccional mencionado:

> *"IV.- Que en el sub litem y a instancias de la Procuraduría General de la República, la que hizo ver al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la necesidad de cumplir con el debido proceso, que se procedió de esa manera obteniéndose del elenco de hechos probados, la realización de la comparecencia oral y privada, la recabación de la prueba y la citación en el término previsto y además, la resolución final emitida por el Organo Director del Procedimiento, lo que permite concluir que hasta ahí, se cumplió con lo establecido por la ley; empero, para l a emisión del documento base de la acción, lamentablemente dejó de lado lo establecido por el artículo 150 ibid (...) de lo expuesto en los acápites precedentes se determina que luego de la culminación del procedimiento ordinario, que es el*

que configura el acto constitutivo del crédito (sic) y, antes de la emisión del título ejecutivo es requisito indispensable hacer las intimaciones al obligado para la satisfacción de lo debido..." (TSCA. Sec. II. No 289- 92)

Consideramos que si bien es cierto, en algunas oportunidades las intimaciones del 150 podrían evitar el proceso judicial, no es posible exigirlas como requisito imprescindible y previo al establecimiento del proceso ejecutivo, pues a lo sumo son facultativas, pero nunca preceptivas, al grado de provocar la inejecutividad del título en caso de omisión. Los requerimientos de pago que exige la norma indicada, están dirigidos a aquellos supuestos en los que la propia Administración Pública vaya a efectuar el cobro en su misma sede, sin necesidad de acudir al Juez, y allí sí serían necesarios (sobre la posibilidad de ejecutar al administrado deudor en sede administrativa, puede verse el interesante dictamen de la Procuraduría General de la República número C- 196-85 del 26 de agosto de 1985). Pero en caso en que se acuda al Juez, debe tenerse presente que en primer término la obligación está preconstituida por ley o por resolución judicial, y por tanto, difícilmente desconocida para el deudor; luego se efectúa un procedimiento administrativo con todas las garantías de defensa, como es el caso de la audiencia, prueba, recursos, etc; y por último se acude al Juzgador, para que allí, en el proceso ejecutivo, el deudor pueda también defenderse oponiendo excepciones o recurriendo de lo resuelto.

De modo que, como puede verse, la oportunidad de defensa para el deudor está más que garantizada, y en consecuencia, las intimaciones parecen innecesarias, máxime si su incumplimiento produce la inejecutividad del título como lo ha dicho el Tribunal. Somos celosos defensores del principio fundamental del debido proceso, pero ha de recordarse que nuestra materia pretende lograr el equilibrio entre las prerrogativas de la Administración y las garantías de los administrados, y en este caso, resulta excesiva la exigencia de las intimaciones, por excesiva la inclinación hacia el deudor.

x- Funcionario Competente Para Certificar.

Otro aspecto de interés en esta materia, corresponde a la determinación del funcionario con facultades suficientes para expedir la certificación título ejecutivo. ¿ Puede extenderla el asesor legal; el auditor, o necesariamente debe ser el Ministro o Presidente Ejecutivo ? Salvo disposición legal especial que autorice a otro funcionario específico distinto del jerarca, es a éste a quien corresponde expedir la certificación del adeudo, y así lo ha indicado el Tribunal Superior Contencioso, entre otras, en las resoluciones número 4062 de las 9:30 horas del 18 de agosto de 1988; 279-89 de las 8:30 horas del 18 de julio de 1989 y la 561- 93 de las 11: 10 hrs. del 28 de setiembre de 1993 . Para ello, el Tribunal ha integrado el 149, que en ese aspecto es omiso, con lo dispuesto en los artículos 65 inciso 2) y 210 de la misma LGAP. El

primero en cuanto atribuye la potestad de certificación al órgano que tiene funciones decisorias en materia de lo certificado, o a su secretario para el caso de que fuera un órgano colegiado, y el segundo, en la medida en que otorga la competencia para expedir los títulos al jerarca del ente respectivo. A manera de ejemplo, el Tribunal Superior, Sección Segunda ha señalado en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados lo que sigue:

> *"A pesar de que la norma transcrita otorga el carácter de título ejecutivo a las certificaciones de adeudos, el Tribunal considera que contiene una laguna al no expresar a quién compete tal función y es en virtud de ello, que se debe acudir entonces, a la Ley General de la Administración Pública en especial, a los artículos 65.2 y 149.1 inciso a). En el primero de ellas se preceptúa, que la potestad para emitir certificaciones corresponde únicamente, al órgano que tenga poderes de decisión en cuanto a lo certificado y, el segundo, en cuanto establece la facultad de emitir títulos ejecutivos, al órgano competente para ordenar la ejecución. III.- Que conjugadas en su contexto las normas citadas, el Tribunal llega la convencimiento, de que el Auditor del ente demandante no cuenta, con los poderes de decisión necesarios que lo faculten para la emisión de instrumentos que revistan el carácter de título ejecutivo, potestad que sí tienen, sin lugar a dudas,*

el Presidente Ejecutivo del Instituto, por disposición expresa de la ley, y por ello se determina, que es a él a quien compete certificar tales adeudos"

xi-Certificaciones de la Administración por adeudos de sus propios funcionarios.

Señalamos líneas arriba que nuestra Ley General de la Administración Pública también permite la creación de títulos ejecutivos en sus artículos 204 y 210, cuando permite al jerarca certificar las sumas adeudadas por sus empleados. Con ello se pretende garantizar la recuperación o indemnización de aquellos daños y perjuicios ocasionados a la Administración por conducta (activa u omisiva) de sus servidores. Es decir, se trata de una acción de regreso o bien de una acción indemnizatoria. Para el caso del artículo 203 y siguientes, se trata de la recuperación que hace el Estado o el ente de aquellas sumas que ha tenido que pagar a terceros, por daños y perjuicios ocasionados por sus servidores; mientras que en el supuesto del artículo 210, se dirige al cobro contra el servidor por daños y perjuicios producidos directamente a la Administración.

En ambos casos, para poder dirigirse contra el patrimonio del funcionario, es preciso determinar de previo su actuación **dolosa** o al menos la producción del daño con **culpa grave**, y para ello, al igual que se indicó con el artículo 149, es necesario cumplir con el procedimiento ordinario del 308 de la

LGAP. Este es un aspecto que se ha convertido en criterio jurisprudencial del Tribunal, el que entre otras resoluciones, ha dicho:

"Redacta la Juez León Feoli y;

CONSIDERANDO:

III.- Reiteradamente la mayoría de este órgano, ha sostenido la tesis de que la facultad legal de la Administración para emitir títulos ejecutivos en contra de sus servidores, al incidir de modo directo sobre su patrimonio, debe estar necesariamente precedida de lo que en doctrina se conoce como el debido proceso, cuyo fin es sin duda, garantizar el derecho de defensa y lo que en nuestro derecho positivo recogen entre otros los numerales 203 a 210 y 308 y siguientes de la Ley General de l a Administración Pública. En el presente asunto (...) no s e dio participación alguna la servidor, por el contrario, todo e l iter procedimental se llevó a cabo por las gestiones del interesado y sin intervención alguna a quien hoy se l e cobra. No se nombró órgano director, no se le dio audiencia, no se convocó a la comparecencia oral y privada y por último no se estableció el grado de culpa - dolo o culpa grave- que se le imputa. Motivo que en criterio de la mayoría del Tribunal restan el carácter de ejecutivo al documento base de la demanda..." (Sentencia No 820-92 de las 10:30 hrs. del primero de

setiembre de 1992. En igual sentido puede verse l a sentencia No 70- 90 de las 15: 00 hrs. del 22 de marzo de 1990)

En este sentido debe quedar claro, que en la resolución final del procedimiento, debe indicarse en forma clara y precisa la existencia de dicho dolo o culpa grave, pues para efectos del cobro, esa es la finalidad esencial del procedimiento. De no indicarse así, el título carece de ejecutividad. Así lo ha establecido por ejemplo la Alcaldía Civil de Hacienda en diferentes pronunciamientos confirmados por los superiores, entre las que se puede citar la resolución de las 15:10 del 17 de marzo de 1993, confirmada por el Juzgado Primero de la materia (expediente número 5518-92), en la que se dijo:

"... procede el suscrito Alcalde a analizar el acto administrativo que da fundamento a este proceso y en el que se observa que es omiso en cuanto a que no se estableció si el faltante que resultó de la auditoría realizada, se debió a dolo o culpa grave del accionado (artículo 210 inciso 1o) de la Ley de Administración Pública) ... en ningún momento se motiva esa situación indicando si se debió a una conducta dolosa, negligente o por falta grave" .

Ahora bien, hemos mencionado el dolo o culpa grave, pero ¿ qué debemos entender con tales términos ?. Con el dolo no se han presentado grandes problemas, pues hemos partido de su concepto tradicional, que se traduce como el saber y querer el

resultado de la acción realizada, o para decirlo en los términos de **Lacruz Berdejo**, quien lo define como *"... la voluntad de realizar un acto antijurídico con conocimiento de su ilegalidad; sabiendo que puede ser dañoso a los demás ; pero sin necesidad de que el agente haya previsto o podido preveer todos y cada uno de los posibles efectos."*

En cuanto a la culpa grave sí ha existido mayor dificultad para su precisión conceptual, pues su definición, como es sabido, ha dado pie a grandes elucubraciones de carácter doctrinal, sin que muchas veces se haya logrado plena claridad. Puede decirse de ella, que se trata de una negligencia o imprudencia grave, de un "descuido grave, un olvido de las reglas elementales de prudencia en el desempeño de su cargo", de aquella actuación realizada aún consiente del riesgo implícito de su conducta. Es decir, aquello que no puede ser tolerado como una culpa leve, como error habitual o un descuido explicable dentro de su esfera ocupacional o profesional.

Don Eduardo Ortiz Ortiz nos aclara aún más ambos conceptos cuando señala en la Actas de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, correspondientes al Proyecto de la Ley General de la Administración Pública (acta No 104 del 3 de abril de 1970. Período Extraordinario, pag. 9), lo siguiente:

> *"El dolo o culpa grave que significativamente es una culpa que ya está muy definida por los Tribunales. Dependiendo de cada caso, es aquella en donde o intencionalmente o corriéndose un riesgo o con obvia*

conciencia de que se están violando reglas elementales se causa un daño."

Y es este precisamente el concepto que ha seguido el Tribunal para definir los presupuestos de comentario, al señalar en algún caso específico lo siguiente:

"Armonizando los institutos del dolo y culpa grave, obtenemos que ambos aunque ciertamente son diferentes, se refieren a que el servidor, en forma intencional o corriéndose el riesgo que a todas luces se ve venir, y sin importar el daño que puede producir pues se tiene conciencia de que se están violando reglas elementales, aún así, despliega la actividad querida y logra al fin su cometido que de antemano conocía y sabía que no era deseable." (Sentencia del TSCA. Sección II. Número 2640 de las 9: 00 hrs del 6 de noviembre de 1986. En igual sentido puede verse la sentencia número 2744 de las 10:50 hrs. del 3 de febrero de 1987)

El aspecto anterior da pie cabalmente a una discusión interesante y a la vez trascendental, pues se han dado serios cuestionamientos sobre la competencia del órgano jurisdiccional para examinar los presupuestos fácticos o jurídicos que dieron pie a la certificación. Y la interrogante puede verse desde una doble perspectiva, pues la situación varía si nos encontramos en la fase inicial del proceso ejecutivo, en donde

habrá o no de despacharse ejecución, o si por el contrario, estamos ya en la etapa de sentencia. Para el primer supuesto, en la fase inicial del proceso, el Tribunal ha insistido en la improcedente discusión de cualquier aspecto que tienda a cuestionar los supuestos fácticos o jurídicos que dieron origen al título, la discusión de "la causa" ha dicho la Sección Segunda. Cuando de esos aspectos
se trate, en criterio de dicho órgano jurisdiccional, debe reservarse el asunto para ser conocido con la sentencia de fondo y no en la fase inicial del proceso en la que únicamente deben revisarse los elementos formales del título y su existencia como tal. De esta forma lo ha indicado el Tribunal entre otras, en la resolución número 3512 de las 10:55 hrs. del 3 de noviembre de 1987, al manifestar lo siguiente:

> *"... el Tribunal concluye que no es este el momento procesal oportuno para que por falta de ejecutividad del título, negarle el curso a la demanda. Así dispuesto porque en primer término, viola abiertamente ese numeral así como el 437 del Código de Procedimientos Civiles, y en segundo, porque cuando del fondo se trata, ya se refiera a responsabilidad contractual o extracontractual, el único iter procedimental dable, es que sea examinado a la hora del dictado del fallo y no como en forma errada lo dispuso la juzgadora de instancia" (en igual sentido pueden verse las resoluciones del mismo Tribunal número 2313 de las 10:15 hrs. del 29 de*

abril de 1986 y la número 3515 de las 11:15 hrs. del 3 de noviembre de 1987).

Ahora bien, de lo dicho, ¿ podría afirmarse que en sentencia si se puede examinar cualquier aspecto de la relación subyacente del título? Si nos apegamos a lo que allí se indica podría afirmarse que así es, pero la lógica y los mismos pronunciamientos oscilantes del Tribunal, nos indican lo contrario. En efecto, debe recordarse que el proceso ejecutivo es un proceso sumario, y por ende de conocimiento limitado en el que no pueden analizarse aspectos excesivamente controversiales que requieren de la amplitud y prueba propios del proceso declarativo.

Con ello no estamos diciendo tampoco, que no deba analizarse ningún elemento de la "causa" del título, pues con ello caeríamos en el otro extremo de la discusión. Y es que los dos criterios se han puesto en evidencia en los diferentes fallos del Tribunal. Así en la resolución ya citada No 2640 de las 9:00 hrs. del 6 de noviembre de 1986 el Tribunal indica:

"Es claro que así debe ser toda vez que no basta tener como base únicamente "el título" pues en verdad hay que valorar las situaciones de hecho y de derecho que le dieron origen".

Sin embargo, por otra parte, ha sido reiterado el criterio de la licenciada Anchía Paniagua, al salvar su voto cuando afirma que:

"II.- Si la ley ha otorgado el carácter de título

ejecutivo a tal documento siempre que esté extendido por el jerarca de la institución, es esto cuanto tiene que examinar el Juez para determinar, formalmente, si ha sido extendido por autoridad legítima, y materialmente, si el título corresponde a una obligación definitivamente constituida, líquida, vencida y exigible. Si tales requisitos se cumplen la demanda es procedente. No es posible en un proceso sumario como el ejecutivo entrar a analizar aspectos sobre el nacimiento de la obligación, entre otros, si hubo dolo o culpa grave del funcionario que diera lugar para crear el documento. Esto se analiza en el proceso ordinario, no en esta vía.-" (en igual sentido pueden verse los votos salvados de las resoluciones 2744 de las 10: 50 hrs. del 3 de febrero de 1987 ; 70-90 de las 15:00 hrs. del 22 de marzo de 1990 y 820-92 de las 10:30 hrs. del primero de setiembre de 1992).

Nuestra posición al respecto es totalmente ecléctica, pues es nuestro criterio que por tratarse de proceso ejecutivo, no puede quedar indefinida la discusión de cualquier aspecto relacionado con los supuestos fácticos o jurídicos que dieron origen al título. Ello sería convertir el proceso ejecutivo en un pequeño ordinario, lo que violaría su naturaleza misma. De modo que aquellos aspectos que requieran de una amplia fase probatoria deberán discutirse en un proceso ordinario.

De hecho así lo ha indicado también el mismo Tribunal en algún

caso específico, cuando señaló:

"Redacta el Juez Chavarría Matamoros; y ,

CONSIDERANDO:

... es lo cierto que el daño sufrido y pagado por la administración en los casos que proceda el reclamo y que es a lo que se refieren los artículos 199 y siguientes de la citada Ley, tiene que ser fácilmente visible, medible y entendible, de suerte que no es necesario buscar al que cometió la falta grave- negligente, porque ya se tiene, entonces, lo que el ordenamiento administrativo prevé es que hay que darle al responsable la oportunidad de defensa que atinadamente la doctrina denomina el debido proceso, para posteriormente expedir la certificación que sirva de título. De lo visto se desprende que si no se sabe a ciencia cierta quien fue el culpable y si para dar cumplimiento con lo preceptuado en el libro segundo de la ley de comentario es necesario abrir un largo proceso que en nada aclara si en verdad el ahora demandado actuó en forma dolosa o culpa grave, se llega a la conclusión de que en estos casos tan controversiales en donde hasta las sociedades contratantes podrían tener cierto grado de responsabilidad, no puede decirse que por sólo haberse cumplido con un procedimiento que está señalado en la ley, aquel tenga que apechugar (sic) con la responsabilidad."

De modo que lo relativo a la existencia o no del dolo o culpa grave, luego de haberse establecido la presencia de alguno de ellos en la resolución administrativa final, rebasa la naturaleza del proceso ejecutivo, y en consecuencia, no será allí donde se determine la legalidad del acto que así lo indicó. Para ello se requiere acudir a la vía ordinaria. Con esto, no estamos negando tampoco, la necesaria existencia del elemento subjetivo (culpa grave o dolo) para que la certificación posea ejecutividad, pues si alguno de ellos dos no se ha dado, no puede hablarse de título ejecutivo, sino que nos limitamos a señalar que establecida la existencia clara de alguno de los dos en la resolución administrativa, debe entenderse cumplido el requisito establecido en la ley, de manera que en caso de inconformidad del servidor afectado, deberá acudir a la vía plenaria con el objeto de dejar sin efecto el acto ablativo cuestionado. Igual solución ha de adoptarse para el caso en que se de una controversia compleja sobre la existencia o no de una relación laboral preexistente entre las partes, en donde deberá acudirse a la vía ordinaria, pues debemos insistir que estos artículos permiten el cobro contra servidores de la propia Administración afectada, no para terceros o ex-servidores, para los que ha de acudirse al artículo 149 en caso de que la obligación estuviese preestablecida.

Pero la situación no parece ser la misma cuando se trata del cumplimiento de requisitos formales del procedimiento

administrativo previo, lo que normalmente no requiere de amplias fases de discusión y prueba, como es el caso del cumplimiento o no del debido proceso, tal y como lo ha hecho el Tribunal en reiteradas oportunidades, según lo señalamos líneas arriba, o si se trata de las intimaciones (con las que no estamos de acuerdo), o la declaración expresa en la resolución final acerca de la actuación dolosa o con culpa grave del funcionario, o la inexistencia fácilmente comprobable de la relación laboral previa entre actor y demandado (este último supuesto también ha entrado a considerarlo el Tribunal al momento de dictar sentencia, al respecto puede verse la resolución número 2541 de las 10:20 hrs. del 9 de setiembre de 1986). Estos y algunos otros aspectos, son de fácil comprobación, y no vemos por qué negarse a su revisión en el proceso ejecutivo, cuyo título, para ser tal, ha de haber cumplido con los requisitos básicos indicados, independientemente de que se consideren formales o materiales. Por ello discrepamos del voto salvado expuesto por la licenciada Miriam Anchía, pues no podemos limitar las facultades del Juez en este tipo de títulos a la revisión formal de su contenido necesario , bajo los principios de abstracción y literalidad, dejando de lado totalmente sus antecedentes. La cita doctrinal que efectúa la distinguida Jueza es valedera en la materia civil, mas en este campo debe tenerse presente que se trata de títulos ejecutivos y no de títulos valores, que se trata de documentos propios de la vía civil de hacienda no de la civil, y antes que eso que se trata

de títulos ejecutivos de los denominados administrativos, en los que por su particularidad (origen sui géneris) no pueden abstraerse totalmente de su causa.

xii- Facultad de las Empresas Públicas para expedir certificaciones con carácter ejecutivo a la luz de la L.G.A.P.

Por último, conviene aclarar alguna confusión que se provocado con la empresas públicas, nacionales o mixtas, en cuanto a la facultad de expedir certificaciones con carácter ejecutivo al amparo de la disposición de comentario. En ese sentido debe tenerse en cuenta que la empresa pública es una persona jurídica común, es decir, privada, cuyo régimen jurídico se desdobla en público y privado, respectivamente para su organización y su actividad (artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública). De tal forma que si su actividad se rige por el derecho común, no forma parte de la Administración Pública, ni está sometida en esa esfera al derecho público, y en consecuencia, no puede hacer uso de las prerrogativas de imperio reservadas a la Administración, pues ni siquiera emite actos administrativos. Así las cosas, ha de quedar claro que un ente económico de este tipo, no

puede expedir certificaciones con fundamento en el artículo 210 de la Ley General de la Administración Pública, pretendiendo por la vía ejecutiva el cobro de un adeudo de alguno de sus empleados, los que para estos efectos, tampoco se consideran servidores públicos (artículos 111. 3) y 112. 2) de la misma Ley General citada). En este mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Superior Contencioso, Sección Segunda, al momento en que señaló: ***"III.-*** *De lo expresado se concluye que la actora es una sociedad estructurada como anónima, que sus funcionarios no son públicos y consecuentemente no pueden expedir válidamente los documentos a que se refieren los numerales 204 y 210 de la Ley General de Administración Pública." (sentencia número 145-89 de las 14:00 horas del 4 de mayo de 1989)*

xiii- Títulos Administrativos con garantía real inmersa.

Por último, dentro de esta modalidad de títulos ejecutivos administrativos, cabe mencionar algunos que consideramos especiales.

Especiales no solo porque están dotados de ejecutividad, sino porque además otorgan garantía real automática al momento de que se concreta la obligación a cargo de un administrado específico. Este es el caso de las certificaciones expedidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en lo relativo a alcantarillado sanitario, para las que, aparte

de ejecutividad, se otorga **hipoteca legal** sobre el inmueble al que se prestó el servicio. Ello de conformidad con el artículo 4o) de la Ley número 5595 de 10 de octubre de 1974.

Por su parte, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece en su artículo 116 (en concordancia con la Sección 8: 00 de su respectivo Reglamento y con el art. 387 del Co. Co. que mencionamos al momento de tratar los títulos negociales de orden público) **prenda legal**, en grado directo y privilegiado en favor del Fisco, sobre aquellas mercancías en poder de la aduana o del consignatario, para el caso de que no se hayan cubierto totalmente los derechos aduaneros, multas y demás cargos que causen. En este sentido, nuestro Tribunales han señalado que si el bien salió de la esfera del consignatario, pasando a manos de un tercero de buena fe (sobre todo si se hizo bajo el amparo registral), no puede perseguirse ya el bien, pues el gravamen indicado no puede afectar a terceros. (véanse las Casaciones No 28 de las 16: 50 horas del 15 de junio de 1988 y la No 99 de las 14:25 horas del 28 de junio de 1991)

Para el caso de la Prenda Legal, la Dirección General de Aduanas tiene la potestad (y así acostumbra hacerlo) de sacar a remate en su propia sede administrativa; mientras que para el supuesto de la hipoteca legal, el Instituto debe acudir a la autoridad Civil de Hacienda, con la particularidad de que el proceso ejecutivo - según veremos - se tramita como un ejecutivo simple, con período para excepciones, sentencia y demás, y la variación se presenta en la fase de apremio, pues

no es necesario decretar ni practicar embargo, desde que ya la ley impone el gravamen automático sobre el inmueble, el que saldrá a remate con la base declarada en tributación directa o la establecida por un perito.

Para culminar, tenemos el caso de hipoteca legal que impera en materia municipal para el supuesto de las deudas por concepto de impuestos, contribuciones y tasas municipales que se hayan generado a consecuencia directa del inmueble gravado, no así para el supuesto de obligaciones con el Gobierno Municipal ajenas al inmueble mismo, como es el caso de una patente o el mantenimiento de parques y zonas verdes, según lo dispone el artículo 83 del Código citado. Hay que recordar lo dicho sobre la materia de "detalles" en caminos públicos, en donde también existe gravamen real nacido de la ley (art. 13 Ley General de Caminos Públicos) .

25-) Certificaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Dejando de lado las certificaciones emitidas con fundamento en el art.149 de la L.G.A.P., encontramos como otro ejemplo de los títulos ejecutivos "administrativos", aquellos que permite la ley No 4777 de 10 de junio de 1971, reformada por ley No 6321 de 27 de abril de 1979, cuando de manera expresa faculta al Instituto Tecnológico de costa Rica a emitir certificaciones con fuerza ejecutiva sobre cualquier saldo adeudado a ella. Manifiesta a la letra el artículo 13 lo siguiente:

> "Las certificaciones emitidas por la Rectoría de la institución, relativas a saldos adeudados a ella,

directamente o por intermedio de las sociedades que autoriza el artículo quinto de esta ley, constituirán título ejecutivo".

Por su parte, el artículo quinto al que remite la norma anteriormente transcrita, señala en forma literal lo siguiente: "Podrá ofrecer bienes y servicios dentro de los campos de actividad que sean objeto de sus carreras profesionales, directamente o mediante sociedades en las que ejerza el control mayoritario y que podrán formar con establecimientos u organismos públicos de desarrollo, tanto nacionales como extranjeros. A este efecto se faculta a las instituciones nacionales para que puedan participar en dichas sociedades con el Instituto."

Este artículo 13 está cuestionado ante la Sala Constitucional por contravenir los artículos 33, 39 y 41 de nuestra Constitución Política, según acción que se tramita bajo el expediente número 1950-92, publicada en el Boletín Judicial número 185 del 25 de setiembre de 1992, aún pendiente de resolución. Y es que con independencia de lo que pueda haberse alegado en dicha acción de inconstitucionalidad, lo cierto es que del artículo en cuestión destacan varios aspectos que conviene mencionar.

En primer término, llama la atención la forma abierta con que dicho precepto permite la certificación ejecutiva, pues, según el artículo el Rector puede certificar cualquier *"saldo adeudado a ella"*, el que no parece estar restringido a los

bienes y servicios de que habla (y a los que remite la propia norma) el artículo 5, que transcribiéramos también líneas arriba. Sin embargo, a tenor de lo indicado con respecto al artículo 149 de la L.G.A.P. anteriormente comentado, consideramos que tal disposición no permite al Instituto, como no puede hacerlo, la certificación irrestricta de cualquier adeudo que éste considere en su favor, pues serán únicamente aquellas rubros preestablecidos por ley o por sentencia judicial firme, los que sean susceptibles de ser incluidos en este tipo de certificaciones. Cualquier supuesto crédito diferente a ello, no puede ni debe dar pie a un título ejecutivo por las razones expuestas ya líneas arriba para el numeral 149 supracitado, a las que remitimos para no caer en redundancias.

En segundo lugar, pero con igual transcendencia, tenemos que el artículo 13 remite a los eventuales créditos que el Instituto pueda poseer en su favor a consecuencia de las actividades desplegadas por las sociedades en las que participa, y de las que habla, según vimos, el artículo 5 transcrito.

> *"... directamente o por intermedio de las sociedades que autoriza el artículo 5 de esta ley.."*, reza la norma.

Y eso sí que llama poderosamente la atención, pues si partimos (como creemos que debe ser), de que las sociedades en las que participa el Instituto, son personas jurídicas independientes de éste, con patrimonio y personalidad jurídica propia, no

alcanzamos a comprender cómo pueden imputarse los créditos de ésta, en favor del Instituto, que aunque accionista mayoritario, es un ente totalmente distinto de la sociedad a que dio origen. Pero aún cuando soslayásemos tal inconveniencia, encontramos otro obstáculo jurídico de igual repercusión, dado precisamente por el hecho de que estas sociedades dirigidas a *"ofrecer bienes y servicios"* dentro de la esfera de acción (o mas bien capacitación profesional) del Instituto, vienen a constituirse como centros de acción concurrentes y no monopolísticos, productores de bienes y servicios hacia el exterior, con un régimen de giro dual, en cuanto público en su organización, pero privado en su actividad. Es decir, vienen a caracterizar una de las conocidas empresas públicas- entes privados, que como se sabe y se ha dicho, no forman parte de la Administración Pública, al no estar su actividad bajo la esfera pública (art. 3. 2) de la L.G.A.P.), lo que le excluye cabalmente de este tipo de potestades o privilegios, pues ha de recordarse que ni siquiera emiten actos administrativos. De allí que no participemos de la juricidad plena del mencionado artículo, puesto que, amén de lo dicho, está permitiendo por un mecanismo indirecto el cobro unilateral por vía ejecutiva de sumas adeudadas a un particular (la sociedad creada en el seno del Instituto Tecnológico), para lo cual parte de la ficción de atribuirlas a dicho ente. En síntesis, consideramos que el cobro de los créditos favorables a las sociedades en las que participa el Instituto Tecnólogico no puede hacerse por la vía ejecutiva establecida en el

artículo 13 (certificación), no solo por la independencia de ambas personas (que lleva también a la separación de los adeudos en su favor y a la titularidad de los mismos), sino además por la naturaleza jurídica y la actividad misma de dichas sociedades, que se manejan, como se indicó, en el campo puramente privado. De allí que el Instituto Tecnológico, por impedimento constitucional, no puede asumir como suyas y en su favor, obligaciones contraídas por particulares, a efecto de cobrarlas luego mediante mecanismos compulsivos propios de la potestad pública. En este sentido, cabe recordar con Rivero (op. cit. , pag. 100) que en las relaciones entre particulares, por virtud del principio de la igualdad jurídica de las voluntades humanas, nadie puede ver modificada su situación sin su consentimiento, por la sola voluntad de otro, como parece autorizarlo la ley al Instituto Tecnológico, en este caso, de manera solapada.

Capítulo IV: Prerequisitos de la Demanda.

Como es sabido, nuestra jurisdicción se denomina : **"Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda"**, por lo que de previo a cualquier consideración es preciso recordar la diferencia ya hecha entre una y otra materia, es decir, entre lo contencioso administrativo propiamente dicho, y lo civil de hacienda. Es cierto que ambos espectros se distinguen de las demás (civil, laboral, agrario, etc.), al menos en principio, por el hecho de que en los conflictos que en ellas se ventilan (y que fijan el marco de competencia de la jurisdicción) siempre interviene un ente público, bien como actor, bien como

demandado, salvo que haya una acción delictiva de por medio, en cuyo caso, el asunto es del conocimiento exclusivo de la jurisdicción penal (de ahí la importancia de establecer las diferencias entre las sanciones penales administrativas y las administrativas penales, pues de ello dependerá a cual jurisdicción corresponde). De modo que esa es la característica general de nuestra jurisdicción (intervención de un ente público en el proceso o al menos, interés directo del Estado, como ocurre con las empresas públicas), pero ello no nos proporciona suficientes elementos para establecer la distinción entre lo civil de hacienda y lo contencioso administrativo. Y es que esta última, según hemos señalado ya en capítulos anteriores, está referida a aquellos conflictos en los que se discute la validez de un acto, o en general, conducta administrativa, mientras que lo civil de hacienda está dirigido a dilucidar aquellos conflictos o simples situaciones de hecho, referentes a la materia mobiliaria e inmobiliaria, abarcando el dominio pleno, y el campo patrimonial dinerario propiamente dicho, en donde podemos incluir la responsabilidad contractual y extracontractual de la Administración, ya sea como obligado o como víctima accionante. Esto nos lleva a la clasificación **clásica** del proceso ordinario, que se ha dispuesto como: proceso ordinario contencioso puro, proceso ordinario civil de hacienda, proceso ordinario de plena jurisdicción y proceso ordinario de lesividad. Lamentablemente, este es un tema que escapa a nuestro trabajo, y por lo pronto nos limitaremos a indicar la diferencia básica entre cada uno de ellos. Se dice

que el contencioso puro es aquel en el que tan solo se impugna un acto administrativo, como podría ser el caso de una suspensión de un profesional por parte de su colegio (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por ejemplo), o el acto administrativo que ordena el cierre de un establecimiento comercial. El proceso ordinario civil de hacienda (que sí se tramita de acuerdo con la Ley Reguladora), está dirigido como dijimos a la discusión de aspectos patrimoniales en general, como es precisamente el dominio (o alguno de sus componentes) de bienes muebles o inmuebles y toda la esfera contractual o extracontractual de la Administración, como ejemplo podríamos citar el caso de una demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social por daños y perjuicios a un paciente producidos en una operación quirúrgica ("mal praxis") o los daños y perjuicios reclamados por un incumplimiento de un contrato.

Por su parte, en el proceso de plena jurisdicción, se produce una combinación de los dos anteriores, pues se pretende la nulidad del acto y a su vez, la indemnización de los daños y perjuicios, como podría ser el caso en el que se pide la nulidad del acto administrativo que declaró caduca una concesión de servicio público, concretamente una línea de autobuses, y los daños y perjuicios ocasionados con la paralización de la empresa. Por último tenemos el proceso de lesividad que es aquel en el que la Administración Pública se dirige ante el Juez pretendiendo la anulación de un acto administrativo firme dictado por ella misma y en el que se han generado derechos subjetivos al administrado. En el proceso,

será precisamente este último quien figure como demandado.

Pero dentro de este ámbito civil de hacienda - fuera del proceso ordinario - también se ubican todas aquellas acciones que tienden de una u otra forma a proteger o recuperar la materia patrimonial, como es el caso de los interdictos, de los desahucios, de las ejecuciones de sentencia (en esencia de la materia penal y de la Sala Constitucional), de las medidas cautelares, de las informaciones "ad perpetuam", de las diligencias de avalúo por expropiación y sobre todo **de los procesos ejecutivos y de ejecución** (simples, hipotecarios o prendarios). En todos estos proceso, reiteramos, siempre que intervenga un ente público como actor o demandado, o que se presente un interés directo del Estado (con las excepciones que veremos en capítulos posteriores), el asunto es del conocimiento de la jurisdicción civil de hacienda; en donde impera, como puede verse, un criterio eminentemente subjetivista, en el que la naturaleza jurídica de las partes juega un papel preponderante.

1- El agotamiento de la vía administrativa como requisito de admisibilidad.

Ahora bien, volviendo a nuestro tema central, tenemos que en el evento de que el proceso ejecutivo se interponga contra una entidad pública o contra el Estado como persona mayor y originaria, independientemente de que el actor (acreedor) sea privado o también público, es necesario que de previo a la interposición del proceso se agote la vía administrativa ante

el órgano o ente deudor.

Aquí es preciso aclarar que el necesario agotamiento en esta materia, no deviene como exigencia de lo dispuesto por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dado que siendo éste un típico proceso civil de hacienda, distinto del ordinario, no está regido en materia procedimental por la mencionada ley, sino por el Código Procesal Civil que en este campo funge como norma especial.

Ha de recordarse que, de los procesos civiles de hacienda, solamente el ordinario que corresponda a esa materia, se rige en lo relativo a procedimiento por la mencionada Ley Reguladora, los demás por el Código Procesal Civil o por las leyes especiales correspondientes. Así lo dispone en forma expresa el inciso 1) del artículo 3 de la Ley Reguladora de comentario, el que a la letra dice:

> "Para los fines del inciso c) del artículo anterior, de los juicios atribuidos a la vía civil de hacienda, los ordinarios se tramitarán de conformidad con la presente ley, y los demás, de acuerdo con la tramitación señalada en el Código de Procedimientos Civiles o en leyes especiales".

Norma esta que viene a ser confirmada por lo dispuesto en el artículo 547 del Código Procesal Civil. De manera que el agotamiento como tal es reflejo de lo dispuesto en el Código en mención, el que dispone en su artículo 548 los siguiente:

> "El Juzgador no dará curso a demandas que se presenten contra el Estado o sus instituciones, sino

> cuando se haya agotado la vía administrativa, salvo los casos concretos en que la ley no obligue a realizar dicho agotamiento"

Debe anotarse sin embargo, que para estos supuestos civiles de hacienda, - y para nuestros efectos, el ejecutivo -, el agotamiento es tan solo **un requisito de admisibilidad de la acción, y no un presupuesto necesario para la estimación del derecho de fondo.** Dicho de otro modo, en estos procesos con el agotamiento de la vía administrativa, se logra abrir la vía jurisdiccional, es decir, queda libre el acceso al "tribunal" civil de hacienda, pero ello no puede verse como un requisito sine qua non para acoger o no las pretensiones esgrimidas por el actor. Siendo ello así, en aquellos casos en los que el accionante haya omitido ese paso previo, y tal circunstancia hubiese pasado desapercibida para el demandado y para órgano judicial desde el inicio mismo del proceso, no puede convertirse en causal de inadmisibilidad si ya es "juicio" está listo para el dictado de la sentencia, pues ha de tenerse como un requisito formal - tal y como se dijo-, que al no haber sido observado a tiempo, ha de entenderse subsanado, debiéndose efectuar el pronunciamiento que corresponda por el fondo. Así se ha resuelto en nuestros Tribunales, en donde se ha dicho:

> *"... la resolución apelada debe revocarse, toda vez que la no alegación sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa, por parte de la Municipalidad de Puntarenas, equivale a renuncia de su parte del*

privilegio que le concede la ley. Es cierto que si el Juzgado, antes de darle trámite al incidente, se hubiere percatado de tal hecho, tenía la obligación de prevenir el incumplimiento de tal requisito; empero, una vez llegado al estado procesal en que se encuentra, lo único posible es su continuación y fenecimiento. Doctrina de los artículos 33. 3, 41.4 y 96.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 970 del Código de Procedimientos Civiles" (Tribunal Superior Contencioso Administrativo. No 2186 de las 15:55 horas del 23 de marzo de 1977. Proceso Ejecutivo de la Sucesión de FAP c/ M d P)

Incluso, si el Estado o ente alegara con razón el defecto en el transcurso del proceso, habría de darse un plazo prudencial al actor acreedor para que subsane la deficiencia, aplicando si se quiere en forma supletoria o por analogía el 96.3) de la Ley Reguladora mencionada, vista la laguna que se da en la materia, a no ser que se considere más apto, el plazo y prevención bajo los cánones del artículo 291 del Código Procesal Civil, cuya aplicación parece limitada eso sí, para la fase inicial del proceso. No obstante consideramos que esta última posibilidad no es la más feliz, dada la remisión que en materia de agotamiento de la vía administrativa hace el Código Procesal Civil a la Ley Reguladora (art. 548 in fine) .

Las particularidades del agotamiento pueden ser muchas, pero por razón de espacio y la especificidad de nuestro tema,

será en otro momento en el que abordemos el tema.

CAPITULO V: La Demanda Ejecutiva. Requisitos.

El artículo 439 del Código Procesal Civil al referirse a la demanda, remite a las disposiciones generales de los procesos sumarios, en donde se indican con precisión los elementos que debe contemplar ésta. Así tenemos que la demanda ejecutiva simple debe contener los siguientes requisitos:

1-) Nombres y Calidades del Actor y Demandado

2-) Exposición sucinta de los hechos.

3-) Fundamentos de Derecho

4-) Pretensión

5-) Pruebas

6-) Cuantía del asunto.

Hay que agregar además, de acuerdo con el mismo Código:

7-) Lugar para oír notificaciones.

8-) Firma de la parte.

9-) Autenticación.

10-) Timbres.

11-) Copias.

1- Nombres y Calidades del Actor y Demandado.

En cuanto a los nombres y calidades del actor y demandado no hay por lo general ningún inconveniente, pues ya sea que actúen personalmente o por medio de apoderado, deben cumplir con el requisito dicho.

Sin embargo, es preciso dejar establecido que el nombre del sujeto pasivo que se consigne en el escrito de demanda (ya sea persona física o jurídica) debe de coincidir plenamente con el documento que sirve de base al proceso ejecutivo, pues ocurre frecuentemente (sobre todo cuando de certificaciones se trata) que hay diferencias en nombre o bien en algún apellido, así como en la denominación de la sociedad anónima o en su cédula jurídica. Esto último produce gran confusión al Juez, pues no se sabe si se trata de un simple error material o realmente de personas distintas, lo cual obliga a constantes aclaraciones, si es que se están en la etapa en que pueden hacerse.

Lo anterior no debe confundirse empero, con la conversión o sustitución del demandado obligado a la prestación exigida, la que opera cuando por inexistencia o extinción de ese obligado, la ley transfiere la deuda a una persona jurídica o física distinta de la originaria, tal y como ocurre por ejemplo en el caso de una sucesión, de una liquidación anticipada de la sociedad dispuesta por los socios, en donde jurisprudencialmente se ha tenido como demandados a los miembros accionistas de la misma en su carácter personal; o como sucede también con aquellas sociedades que luego de presentar la declaración de un impuesto nacional (renta vgr.) de manera inexacta, no aparecen inscritas formalmente en el Registro Nacional, ante lo cual se ha dispuesto que la persona que suscribió y presentó la declaración es responsable en su carácter personal, según se extrae de los artículos 17, 21 inciso b), 79, 80, 124 inciso b) y 125 del Código Tributario.

En este aspecto de la identificación de actor y demandados, sí llama poderosamente la atención que en muchas oportunidades, el acreedor menciona como un hecho, que determinadas personas se constituyeron codeudores o fiadores solidarios, pero no se indican expresamente como demandados. Una cosa es señalar que A y B se constituyeron como fiadores en el pagaré (por ejemplo), como un hecho mas, y otra muy distinta, incluirlos como demandados en el escrito mismo. Esta práctica viciada, lamentablemente obliga a los "de previos" en forma constante, con detrimento en la celeridad del proceso. No basta con que se indique a los sujetos pasivos de la obligación que se ejecuta, debe demandárseles formalmente en el mismo libelo.

Otra de las interrogantes que surge aquí, lo es en cuanto a la necesidad de aportar o indicar el número de cédula de identidad del demandado, pues el artículo no lo exige en forma expresa. Estamos claros en la conveniencia de que así se haga para efectos de evitar confusión y demandas mal dirigidas contra homólogos, diferenciables en el plano escrito, únicamente por su número de cédula. Y esto reviste aún mas importancia para efectos del correspondiente embargo, sobre todo si se trata de salarios, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, etc. , en donde se requiere una identificación precisa del embargado.

Pero el inconveniente se presenta al momento en que se examina el documento para efecto de despachar ejecución. ¿ Debemos considerar el número de cédula de identidad como requisito imprescindible para efectos de dar curso al proceso ? Y en

consecuencia, ¿ es necesario prevenirlo como acto previo a cualquier resolución ? En este, como en la mayoría de los casos, pueden darse dos criterios bastante firmes. Puede señalarse que sí es un requisito básico, pues si bien el artículo 433 no lo exige expresamente, el artículo 437 del mismo Código permite la aplicación de las normas del proceso ordinario a los procesos sumarios, en lo que se guarde silencio y sea compatible con estos últimos. Lo que permite la aplicación supletoria del artículo 290 inciso primero Ibidem, en el que sí se establece como requisito necesario de la demanda el número de cédula del accionante y accionado, que en ese sentido tampoco puede tomarse como parte de las calidades, tal y como se ha considerado en alguna oportunidad. Sin embargo, en la tesis opuesta, podría decirse que al no estar contemplado en el 433 no es requisito imprescindible, al menos para despachar ejecución, pues existe norma expresa y especial sobre los requisitos de la demanda, en donde no se incluye el número de cédula, por lo que no puede acudirse al 290 del proceso ordinario, ya que no hay omisión ni laguna en el sumario, sino tan solo modificación de los requisitos para estos. Este último aspecto es señalado incluso por uno de los redactores del Código, cuando señala lacónicamente:

> *"No sobre decir siguiendo el perfil de lo que es un proceso sumario, que la demanda tiene poco requisitos formales, como se deduce del párrafo 1o del artículo 433"* ***(Arguedas Salazar (Olman):*** *Proceso Abreviado y Sumario en el Código Procesal Civil, Revista*

Iustitia No 44, Año 4, San José, Costa Rica, Agosto, 1990, pag. 6)

Nos inclinamos claramente por la segunda posición, pues aparte de que el 433 no exige el requisito, de considerarlo así para la demanda, habríamos de prevenirlo conforme lo establece el Código (según lo veremos líneas adelante) con la posibilidad de declarar el proceso inadmisible para el caso de que se incumpla lo prevenido; circunstancia que en nuestro criterio sería excesivamente rigurosa, máxime que tratándose de sanciones (como lo es la inadmisibilidad) debe acudirse a un criterio restrictivo, y mal haríamos en aplicar una medida tan drástica por aplicación supletoria (o analógica de una norma). Amén de que poco efecto práctico se daría en la realidad, pues al menos en nuestra materia civil de hacienda, muy probablemente el ente público acreedor procederá a emitir otra copia certificada del título y a interponer otra demanda, con gasto de tiempo y esfuerzo para ambas instituciones. De tal forma que consideramos más conveniente que, pese a la omisión, se despache la ejecución respectiva y se prevenga el número de cédula para efectos de comunicar los embargos solicitados, con lo cual estaríamos respetando el principio "pro actione" y no, poniendo trabas a la resolución final debida.

a- PODERES.

Relacionado con el aspecto de los nombres y calidades de las partes, encontramos el tema de los poderes, con especial

relevancia cuando de personas jurídicas se trata, ya sean públicas o privadas. En realidad el tema del mandato y de la representación escapan a la finalidad misma del trabajo que nos ocupa, pues por sí mismo podría ser objeto de un estudio específico extraordinariamente amplio. No obstante, queremos destacar algunos aspectos de interés que con alguna frecuencia ocupan la atención en el proceso ejecutivo.

a-1: Mandato y Poder.

En primer término, es preciso distinguir la figura del mandato con la del instrumento escrito en el que normalmente se consigna éste, los que lamentablemente confunde nuestro Código Civil en su artículo 1251 cuando refiere que el poder es el instrumento en el que se hace constar el mandato, cuando en verdad la denominación correcta para ese documento es el de "procuración", dado que en él constan las atribuciones del mandatario (sobre este punto puede verse **Baudrit Carrillo** (Diego): Contenido del Poder Generalísimo, en Revista Iustititia No 71, de noviembre de 1992, San José Costa Rica, pag. 4). Asimismo, debe distinguirse la figura del poder con el mandato mismo, pues no obstante la idea generalizada (incluida en nuestra legislación), son figuras diferentes. Por poder ha de entenderse "el acto por el cual una persona inviste a otra de su representación" (**Sánchez Urite** (Ernesto A.): Mandato y Representación, Buenos Aires, Argentina, Abeledo Perrot, Segunda Edición, 1986, pags. 271.). O como "aquel elemento jurídico exterior que da efecto a la voluntad del

representante sobre el patrimonio del representado", según lo define el profesor **Baudrit** citando a Carbonier (op. cit., pag. 4). "El poder viene a constituir la fuente de las atribuciones del apoderado" señala el autor nacional. En cambio, por mandato debemos conceptuar "el contrato por medio del cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta de otra". Según se ve, son institutos jurídicos de fondo (sustanciales) diferentes, pues el poder es tan solo una especie del mandato que en ese sentido viene a ser el género, por lo que de asimilarse ambas figuras, se comete el error de asimilar el poder con tan solo una proyección parcial (o especie) del mandato, a saber: el mandato representativo.

Así encontramos diferencias en cuanto a la *naturaleza jurídica* , pues mientras que el mandato es un acto jurídico bilateral, el poder es un acto jurídico unilateral (no requiere de aceptación del apoderado al momento de expedirse). También hay diferencia en cuanto a la *capacidad* , pues para contratar en el mandato se requiere de capacidad plena, en tanto que para el poder basta tan solo una capacidad restringida o volitiva, o de querer y entender, es decir, capacidad para realizar actos lícitos. También hay diferencia en cuanto a la *forma* , ya que el mandato no es formal, mientras que el poder, requiere de un documento que pueda ser exhibido frente a terceros, con lo que se actuará a nombre y por cuenta del representado. Por último se diferencian en cuanto al *objeto* , dado que el mandato implica la realización de un acto jurídico o una serie de actos de esta naturaleza, mientras que en el poder se pueden realizar

todo tipo de actos lícitos, salvo las limitaciones impuestas por el poderdante o la naturaleza del poder, es decir, generalmente el objeto del poder es más amplio que el del mandato (sobre la diferencia entre ambas figuras puede verse **Sánchez Urite (Ernesto A.)**: op. cit., pags. 271.).

Basta ver el origen eventual del poder como acto jurídico, para tener clara su distinción con el mandato. Así tenemos que el poder puede ser producto de un contrato (como el de mandato por ejemplo); de una disposición legal (como es el caso del ejercicio de la patria potestad ejercida por las partes); de una decisión judicial (tal y como ocurre cuando se designa un curador procesal o un administrador de bienes ajenos); o del estatuto particular de una persona jurídica o moral (como ocurre con los representantes designados en el acta constitutiva de una sociedad mercantil).(**Baudrit Carrillo: (Diego)**: op. cit., pag. 4)

a-2 : Tipos de Poder.

a-2-1: El Poder Generalísimo.

Como se sabe, nuestra legislación regula en esencia cinco tipos de mandatos de representación, que a la postre confunde con el mandato oculto o no representantivo. Así tenemos el **poder generalísimo**, regulado en el artículo 1253 del Código Civil que da amplias facultades al apoderado para cualquier acto de disposición, en cuanto pueden comprometer definitivamente el patrimonio del poderdante. Por ello se

afirma que el poder generalísimo permite al apoderado realizar toda clase de contratos onerosos a nombre y por cuenta de su poderdante.

Dispone el artículo mencionado lo siguiente:

> *"En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de una persona, el mandatario puede vender, hipotecar y de cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes; aceptar o repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poderdante, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo"*

La ventaja que tiene este artículo en nuestro sistema, radica en el hecho de que al momento de constituir el poder no es necesario que se haga una enumeración pormenorizada de todas las atribuciones del apoderado, pues basta que se haga referencia a las facultades señaladas por el Código Civil en el artículo respectivo.

Nótese sin embargo, que en la enumeración que hace la norma no se incluye la posibilidad de donar, ni tampoco de sustituir su poder. Lo primero por cuanto la donación requiere poder especialísimo (art. 1408 del Código Civil), y lo segundo, porque para la sustitución del poder se necesita de

autorización expresa del poderdante (artículo 1264 del Código Civil). Sobre este último aspecto regresaremos más adelante.

a-2-2 : El Poder General.

También tenemos el **poder general** regulado en el artículo 1255 del Código Civil. Con éste se confiere al apoderado amplias facultades para la administración de los bienes de su poderdante. Aquí importa destacar la atribución que confiere el artículo en el inciso 5o) cuando señala:

> *"Exigir judicial o extrajudicialmente el pago de los créditos y dar los correspondientes recibos"* .

Con esta disposición se permite al apoderado general (de una persona física o jurídica, privada o pública) la interposición de las acciones de cobro judicial (mediante el proceso ejecutivo, si es necesario) en nombre de su representado. Es decir, este poder confiere atribuciones suficientes para accionar en proceso ejecutivo <u>como actor</u>. Sin embargo parece que el precepto sólo faculta al apoderado general para que accione como actor, no así como demandado, pues se refiere a la posibilidad de <u>exigir el pago de créditos</u>, no a defender el pago de los mismos, cuando su poderdante sea el deudor. Consideramos que ello debe ser así, pese a que pueda considerarse en algún momento que el gestionar en defensa de las obligaciones contraídas por su mandatario sea consustancial a la administración de sus bienes, derivado de la potestad que otorga a éste el inciso 6o) del mismo artículo. De hecho, la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso

Administrativo lo ha entendido en el mismo sentido que el nuestro cuando indicó:

> *"La conclusión entonces, es que por ser el presente un juicio ejecutivo simple donde se reclama una suma de dinero a la empresa PLF S.A., y como no se está en ninguno de los casos de excepción del artículo 1255 del Código Civil, el señor ... como su apoderado general que es, no está facultado para contestar la demanda ni actuar en su nombre dentro del proceso."* (Sentencia No 588-93 de las 10:40hrs. del 7 de octubre de 1993.)

Ahora bien, el poder general sólo permite al apoderado accionar para el cobro de los créditos de su poderdante, normalmente en el proceso ejecutivo, y en forma excepcional en el ordinario, pero ha de quedar claro que **el poder general no faculta al apoderado para accionar en la vía ordinaria**, salvo el caso mencionado arriba. Así lo ha definido la Sección Primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo en las resoluciones número 8010, 10110 y 10560, y la Sala Primera Civil en las resoluciones No 129 de las 8:15 hrs. del 16 de abril de 1963 y la No 74 de las 8:00 hrs. del 27 de marzo de 1979. Además sobre la imposibilidad de presentar demanda de desahucio, puede verse la sentencia del Tribunal Superior Primero Civil No 317-M de las 8:10 hrs. del 11 de marzo de 1987).

Tanto el poder general como el generalísimo deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Público, y

con ellos se establece una excepción a la regla o principio de presentación de documentos al Registro, pues en este caso para que afecten a terceros, la ley exige que se encuentren debidamente inscritos. (párrafo final del artículo 1251 del Código Civil).

i- Comprobación de Poderes en el Sistema Bancario Nacional.

Ahora bien, ya se trate de poder generalísimo o de poder general, en tratándose de proceso ejecutivos instaurados por cualquiera de los Bancos que integran el Sistema Bancario Nacional, no se requiere aportar en cada uno de los procesos el correspondiente poder del representante bancario, pues el artículo 70 párrafo final, permite que se presente por una única vez ante el Despacho Judicial respectivo, el que llevará un registro de los mismos, con su respectiva firma y duración del poder. Es importante insistir en este último aspecto, pues es frecuente que se presenten las certificaciones sin la indicación de cuanto dura el poder, lo cual obliga a constantes prevenciones. Además, importa aclarar también en este aspecto, que la facilidad concedida por la ley a los Bancos sólo se extiende a los procesos ejecutivos o de ejecución, no así a los ordinarios o de otra índole, en los cuales deberá aportarse certificación debidamente expedida acerca del representante bancario respectivo. De esta posibilidad, al igual que de las normas especiales para la realización del remate que establece la Ley del Sistema Bancario Nacional, pueden hacer uso todas aquellas instituciones autónomas o semiautónomas cuando se

acojan expresamente a las disposiciones de esta ley, ya sea en la demanda o en escrito posterior aparte, por así disponerlo el artículo 2 de la Ley No 4937 de 24 de diciembre de 1971 que reformó el artículo 70 mencionado. En este sentido el Tribunal Superior Contencioso ha sido estricto al señalar que el ente sólo puede hacer uso de este beneficio únicamente cuando se hubiere acogido a dicha ley **de manera expresa**. (entre otras puede verse la resolución número 254-89)

ii- Los Fiscales Específicos en la Tributación Directa.

Una situación similar, aunque no tan clara, se da con denominados Fiscales Específicos que utiliza la Dirección General de Hacienda con fundamento en los artículos 157 y 158 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el "Reglamento Regulador de la Gestión de Cobro Judicial de los Fiscales Específicos", emitido por Decreto Ejecutivo No 22988-H del 18 de enero de 1994 (publicado en el diario oficial La Gaceta No 53, del 16 de marzo de ese mismo año), de donde se obtiene que éstos gozan de las facultades de apoderados judiciales, pese a que en ninguna norma se establece de esta manera (al menos en forma expresa) por lo que se ha extraído del artículo 162 del mismo Código. No obstante, la disposición reglamentaria citada les faculta a interponer la demanda, gestionar el proceso, publicar el edicto, participar en el remate, suspender el "juicio" y hasta darlo por terminado, todo lo cual es propio de un apoderado judicial, es este caso de la Dirección General de Hacienda. Siendo esto así, parece

imprescindible que tales fiscales (que no parecieran funcionarios públicos de planta, según la concepción del 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública), aporten en cada uno de los procesos su respectivo poder o designación, o al menos, una certificación clara y completa de su nombramiento y período de vigencia, a efecto de que el Despacho Judicial tenga un registro actualizado de ellos.

a-2-3: El Poder Especial.

También tenemos el **poder especial**, regulado en el artículo 1256 del mismo Código Civil. Se entiende por éste, el que se otorga para un determinado negocio, judicial o extrajudicial. Luego de que se haya cumplido con el cometido, cesa el poder, sin que pueda extenderse a ningún otro asunto, aunque fuese derivación o consecuencia del primero. Tal sería el caso por ejemplo de un poder dado para arrendar un inmueble, que no facultaría al apoderado especial para percibir los alquileres (**Gerardo Trejos y Marina Ramirez**: Tratado de los Contratos, en la que se modifica la obra de don Alberto Brenes Córdoba del mismo título, San José, Costa Rica, Primera Edición, Editorial Juricentro, 1985, 210). También se ha exigido un poder especial (judicial) exclusivo para el acto concreto de la conciliación en materia de familia.

a-2-4 : El Poder Especialísimo.

De igual forma encontramos el **poder especialísimo**, el que también se da para un caso específico, determinado, pero que a diferencia del anterior, dada su importancia o condición

jurídica, se convierte en un acto de representación de características muy especiales, dirigido tan sólo a ese acto específico, tal y como ocurre por ejemplo con el matrimonio o la donación.

a-2-5: Poder o Mandato Representantivo Judicial.

Conjuntamente con los anteriores, nuestro ordenamiento también prevee un quinto grupo de poderes, bajo el denominado **mandato judicial**. Tiene por objeto éste, facultar al mandatario para que intervenga en uno o varios asuntos judiciales en los que el mandante intervenga como sujeto procesal. El poder judicial en consecuencia, puede ser general o especial, lo primero (poder general judicial) cuando se trata para todos los asuntos que interesen al mandante; lo segundo (poder especial judicial) cuando se trate de un poder judicial para un asunto específico. Quizá el más frecuente en nuestro medio, sea el poder especial judicial, el que según hemos dicho, no requiere de inscripción en el Registro Público, ni aceptación del apoderado. Dicho poder puede constituirse de dos formas: ante abogado o apud acta. Siguiendo la ritualidad dispuesta por el artículo 1251 del Código Civil, tenemos que con anterioridad al nuevo Código Procesal Civil se exigía razón notarial al pie del poder, lo que produjo no pocos problemas, pues en algunas resoluciones los Tribunales exigieron en forma estricta que se consignara una razón extendida por notario, en tanto que otros dieron por bueno el poder con tan solo la firma y sello consignada por un abogado y notario (sobre este último punto

pueden verse a manera de ejemplo las resoluciones del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, números 405-89 y 615-89, y de la Sección Segunda las número 5-90 y 4210). Hoy, la nueva legislación se hace eco de este criterio menos rígido y tan sólo requiere para la expedición de aquél de la simple autenticación de abogado, la que deberá ser puesta por un profesional distinto de aquel en cuyo favor se otorgó el poder, según lo dispuesto por el artículo 118 del Código Procesal Civil. Aquí cabe acotar también que cuando el poderdante es abogado, no se requiere que su firma sea autenticada por otro profesional en derecho, pues la suya (única necesaria) se entiende auténtica, así lo dispuso la Corte Plena mediante circular adoptada en la sesión celebrada el 31 de mayo de 1993 y publicada en el Boletín Judicial del 26 de julio de 1993.

Sobre este aspecto del poder especial judicial y su respectiva autenticación, es bueno aclarar que en cuanto a la representación del Estado (entendido el término en sentido estricto como sinónimo de "Estado Persona") depositada por ley en la Procuraduría General de la República, no se requiere de mayor formalidad, puesto que el señor Procurador General o incluso el General Adjunto, tan solo transfieren o delegan su representación en alguno de los señores Procuradores específicos, sin mayores requisitos ni formalidades, pues basta para ello, un simple escrito o nota, o incluso puede hacerse por vía telegráfica o radiográfica, según lo señala el artículo 13 de su Ley Orgánica. En este supuesto particular de poder

especial judicial (conviene aclararlo de una vez), no se requiere del pago de timbre del Colegio de Abogados, ya que no se está ante el ejercicio privado de la profesión, tal y como lo dispuesto el **Tribunal Superior Contencioso, Sección Primera** en la resolución número **10.567.**

Por su parte, el poder **apud acta**, es el que se confecciona en el propio despacho judicial, en el mismo expediente del juicio, que deberá- firmar el poderdante y el funcionario judicial correspondiente (Alcalde, Actuario, Juez, Secretario del Tribunal), dando fe de que efectivamente fue otorgado en su Despacho y de la autenticidad de la firma. A continuación nos permitimos transcribir una de las tantas fórmulas ("machotes") que para el mismo existen:

> "Ante mí, XXXX, Juez (Actuario o Alcalde), compareció el señor ZZZZ, quien es (calidades y número de cédula), y manifiesta: Que en su carácter personal (o en su condición de apoderado generalísimo de la empresa SSSS), otorga poder especial judicial para que lo represente en este proceso que se tramita bajo el expediente número ... que es ordinario (o ejecutivo o desahucio, etc.) promovido por ... contra... , al licenciado TTTT (calidades y número de cédula), a quien le confiere todas las facultades enumeradas en el artículo 1289 del Código Civil, así como las de sustituir este poder en todo o en parte, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo en caso necesario. Leída que fue esta acta al otorgante, la

ratifica y todos firmamos en la ciudad de ..., a las ... horas... del día.... del mes de ... de mil novecientos noventa y ... . Se agregan y cancelan los timbres de ley.

a - 3: Timbres del Poder.

En cuanto a los timbres que debe cancelar el poder, se han generado una gran cantidad de dudas, sobre todo en períodos de reforma legal, pero dichosamente en la mayoría de los casos se ha tomado de alguna forma instintiva la solución correcta. En efecto, de conformidad con el inciso 14 del artículo 273 del Código Fiscal, vigente de acuerdo con la reforma dada por ley número 6450 de 15 de julio de 1980, todo poder debe pagar un timbre de 100.oo, que se vio aumentado en un 25% de acuerdo con el artículo 7 de la ley de "Reajuste Tributario" (aprobado por ley No 7088 de 30 de noviembre de 1987, publicado en el Alcance No 34 - A a la Gaceta No 229 del lunes 30 de noviembre de 1987). **De modo que en la actualidad, el poder debe cancelar 125.oo en timbre fiscal**, ya sea apud acta o ante abogado. Y para el caso de que se hubiese hecho ante abogado, deberá pagar además el timbre correspondiente establecido en la tabla del Decreto vigente, cancelando siempre como mínimo la suma de **¢ 50.oo en timbre del Colegio**. Aquí sin embargo puede presentarse otro problema común, ¿ qué sucede si una persona, como actor o demandado otorga poder a varios abogados para que lo representen indistintamente de manera individualizada; o por el contrario, que varias personas (litis consortes) como

demandados o actores, otorguen en un solo acto y documento poder a un solo abogado ? ¿ Deben pagar el timbre fiscal por cada uno de los abogados a los que se da poder, o en el segundo caso por cada una de las personas que otorgó poder, o por el contrario, debemos entenderlo como un solo acto para efectos fiscales ? Consideramos que ya sea que se trate de pluridad de abogados o pluralidad de sujetos procesales, existen una multiplicidad de poderes, que deben entenderse cada uno como un negocio o acto jurídico independiente, que deberá en consecuencia cancelar (cada uno) el timbre correspondiente a su poder. En realidad la confusión se presenta por el hecho de que se efectúan los poderes en un solo documento y acto, pero, ¿ acaso no está comprendido allí mas de un poder?. Es claro que sí. De hecho, qué sucedería si se constituyeran por separado, allí nadie negaría el pago de las especies fiscales, entonces, por qué hacerlo aquí. Creemos que debe pagarse tantos timbres fiscales (125 colones) como poderes se otorguen. De esta manera lo dispone claramente en Código Fiscal cuando en el inciso segundo del artículo 273 manifiesta:

> *"Si en un mismo documento se consignan varios contratos o se contraen obligaciones distintas, se pagará el impuesto que corresponda a cada uno de ellos".*

Asimismo precisa recordar que de conformidad con el inciso 27 del artículo 273 recién citado, la revocación de poderes está exenta del pago del timbre fiscal, así como las garantías o cauciones otorgadas en el mismo documento en el que consta la

obligación que se garantiza, y en esto último hay que enfatizar, pues si por ejemplo en un proceso se otorga una garantía o caución ordenada por el Tribunal, obviamente sí tendrá que pagar el correspondiente timbre fiscal, pues es un acto independiente de la constitución de la obligación inicial ya declarada.

Estas cauciones dadas por ejemplo como garantía en costas, deberán pagar el 5 colones por cada mil, de acuerdo con la regla general establecida en el párrafo final del artículo 272 del Código Fiscal mencionado, incrementado en un 25 por ciento mediante la Ley de Reajuste Tributario, según se dijo líneas arriba, por virtud de la inclusión expresa que de ellas se hace en el inciso tercero del mismo artículo 272.

Consideramos que tanto el pago de timbres como la autenticación, son requisitos que de haberse omitido, pueden ser subsanados con posterioridad, sin que ello ocasione la invalidez o ineficacia del documento expedido, como en algún momento lo dispuso la **Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo** (véanse las resoluciones número **3054 y 3910**). Los timbres pueden ser cancelados con la multa correspondiente en el plazo prevenido por la autoridad judicial, y la autenticación puede darse en presencia del Secretario también dentro de la fecha señalada por el Juzgador, que bien puede ser la usual de tres días. Sólo en el evento de que no se cumpla con lo prevenido, puede hablarse de ineficacia del poder conferido, lo cual acarrearía la invalidez de las actuaciones y resoluciones dadas con fundamento en las

articulaciones de quien no era apoderado y por ende, carecía de legitimación ad procesum.

En esta materia de los timbres se ha dado sin embargo una mala práctica de los litigantes, pues en aquellos casos en los que han incumplido con la cancelación correspondiente, una vez que son prevenidos del pago y la multa respectiva, presentan un nuevo poder, esta vez con los timbres debidamente cancelados. Ello, como se observa, implica una clara burla a la obligación impuesta por ley, sobre todo en lo referente al pago de la multa. Sin embargo, ¿ cómo negar validez a ese nuevo poder y a las gestiones que se realicen con fundamento en él ? Parece difícil y antijurídico hacerlo, pero consideramos que al menos debe sancionarse al quien incumple, restando validez (allí sí) a las gestiones que haya realizado con el documento originario que produjo la prevención y la multa. Así lo ha entendido la **Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo**, en su resolución número 2649 de las 17:20 hrs. del 11 de noviembre de 1986, que en lo pertinente dijo:

"Redacta el Juez Chavarría Matamoros y,

CONSIDERANDO

... Sí ha de aclararse que el Juzgado estaba en lo cierto al prevenir el pago de la multa, empero como de poderes se trata, si la suma echada de menos no fue cancelada, bien podía el Banco actor conferir un nuevo poder, ahora con las especies de ley correspondientes de suerte que, se repite, si la multa no fue pagada, lo único que no cobró valor fue

la excitativa hecha por el mal llamado "mandatario".- "

a - 4: Limitaciones al Poder.

Todos estos poderes (generalísimo, general, especial judicial, etc.) pueden otorgarse con determinadas limitaciones, como ocurre cuando se confieren tan solo para determinado tipo de actos o para actuar en una zona territorial específica. Sin embargo, las limitaciones más usuales en nuestro medio se dan en cuanto a una suma determinada de dinero y en cuanto a la actuación conjunta de dos o más personeros para el ejercicio válido del poder. En el primer caso, el poderdante limita al apoderado para que actúe por su nombre y cuenta hasta un máximo determinado de dinero (un millón, dos millones, o más de colones), por encima de ella, el acto del apoderado no le compromete y se reputará como responsabilidad exclusiva de aquel.

a- 4 -1: Poderes Conjuntos.

Otro caso de limitación se da en el supuesto de representantes conjuntos, en donde se exige de cláusula expresa que así lo disponga, pues de lo contrario, ha de entenderse que pueden actuar por separado, arts. 1259 y 1286 C.C. Ocurre aquí que el poderdante otorga el poder a dos o más personas para que estos le representen, siempre y cuando actúen en forma conjunta. Sobre esta figura se han presentado algunos cuestionamientos de interés, como ha ocurrido por ejemplo con el tipo de actividades o negocios para los cuales se requiere

la actuación conjunta, ¿ son todos o solamente algunos ? ¿ opera solo para efectos negociales o también para la representación jurisdiccional?. Y de cubrir también esta última opción, ¿ deben actuar los personeros en forma conjunta tanto si figuran como actores o como si lo hacen en el carácter de demandados ?. Ante todo, los cuestionamientos han surgido en lo que se refiere a la notificación válida de la persona física o jurídica representada, pues se discute si debe notificarse a ambos representantes o si basta con que se haga a uno solo de ellos, pero sobre esto regresaremos luego al momento de abordar el tema de la notificación.

a- 4 - 2: Sustitución del Poder y Poderes Sucesivos.

La figura de los representantes conjuntos no debe confundirse con el otorgamiento de poderes sucesivos ni mucho menos con la sustitución del poder. Esta última figura está regulada en nuestro Código Civil en los artículos 1264, 1265 y 1266. Nos atrevemos con nueva osadía a definir la sustitución del poder, como **aquella transferencia que efectúa el mandatario, en forma total o parcial, de las facultades que originariamente le fueron asignadas por el mandante, de modo tal, que el sustituto asume su posición como centro de representación último, generalmente definitivo en relación con el anterior representante (pues en cuanto al poderdante, continúa sujeto a las mismas causas de extinción que regían para el anterior, generales a todo poder), y excluyente de su antecesor, lo que le faculta para actuar en forma directa a**

nombre y por cuenta del poderdante, en los mismos términos que se dispusieron para su transmitente. Como puede verse, se trata de un desplazamiento total o parcial del apoderado originario, que queda relegado del todo en cuanto a la materia en la que dispuso la sustitución, es decir, desaparece de la vida jurídica. Por ello. podría hablarse de una especie de subrogación, o bien de cesión, por cambio, pleno o parcial, en la figura del apoderado. De allí que don **Alberto Brenes Córdoba** con su característica claridad señale al respecto:

> "Una vez hecha la sustitución total del mandato, el sustituyente queda por completo separado del manejo de los negocios para que fue otorgado aquél, ..." (Cfr. la producción de **Gerardo Trejos y Marina Ramirez:** op.cit., p.p. 216-217)
>
> Es por esto que el autor argentino **Ernesto A. Sánchez Urite** describe con gran acierto esta figura de la siguiente manera : "... en la sustitución propiamente dicha hay un traspaso y un nuevo representante, nombrado por el anterior, que recibe las facultades que éste tenía, de manera que el representante inicialmente nombrado por el principal desaparece de la escena jurídica y su lugar lo ocupa el sustituto." (op. cit., pag. 153).

Nótese que normalmente se trata de una transferencia definitiva a manos del sustituto - según hemos dicho-, pues según letra del artículo 1265 del Código de comentario, el anterior apoderado (que ve eliminada su investidura como sujeto

de **aquel acto jurídico unilateral** primigenio) no puede revocar la sustitución, salvo que estuviere autorizado para ello o que se hubiere reservado tal facultad.

Esta posibilidad de sustituir el apoderado, no se entiende incluida en forma implícita en el contrato de representación, requiere de cláusula expresa que autorice al mandatario para ello. Con ello, nuestro régimen jurídico se aparta de algún modo de la doctrina tradicional que estima improcedente en forma absoluta la sustitución del poder, pues autoriza y tutela esa modificación cuando así lo establezca la voluntad del propio poderdante, salvo casos extraordinarios en donde se ha permitido aún sin la anuencia previa del poderdante en el contrato, cuando las circunstancias particulares no solo lo permitan sino lo exijan. Este tema específico ha provocado no pocas dudas que van más allá- del poder generalísimo para extenderse a todos los tipos contemplados en el Código. Así tenemos que en varias oportunidades los Tribunales Superiores Civiles han limitado la restricción de sustituir el poder a los que denominan de "disposición" pero no a los judiciales propiamente dichos, que aunque no autorizados expresamente deben entenderse permitidos (al respecto pueden verse entre otras la resolución del **Tribunal Superior Segundo Civil** de las 9:45 hrs. del 23 de marzo de 1992 y del **Tribunal Superior Primero Civil** las número **163** de las 9:05 hrs. del 25 de enero de 1989 y la número **647-M** de las 7:45 horas del 15 de junio de 1993). Sin embargo la tesis mayoritaria a nivel jurisprudencial es la de impedir la sustitución del poder para todos aquellos

casos en los que no se haya autorizado de manera expresa por el poderdante, tal y como lo señala con claridad el artículo 1264 del Código Civil. En este último y mayoritario sentido tenemos por ejemplo la sentencia del **Tribunal Superior Contencioso Administrativo**, **Sección Primera**, **No 8003** de las 15:00 hrs. del 29 de agosto de 1985, y más recientemente la sentencia de la **Sala Primera de la Corte suprema de Justicia No 69** de las 15 horas del 3 de noviembre de 1993, en donde reiteró el principio de la prohibición legal del apoderado para sustituir su poder, salvo que el poderdante lo autorice expresamente. (sobre el tema específico y en coincidencia con el criterio mayoritario puede verse el artículo del doctor **Gutiérrez Cerdas (Alfonso)**: Sustitución de Poderes. Observaciones en torno a una reciente sentencia judicial, en la Revista Ivstitia, No 87, de marzo de 1994.).

Para este tipo de sustitución existen dos posibilidades: en una primera, el poderdante señala con antelación la persona que en su caso deberá sustituir al apoderado, y una segunda, en donde se deja al arbitrio del apoderado la designación de su sustituto. Como es lógico, ambos sistemas gozan de un régimen diverso de responsabilidad para el apoderado, pues mientras en el primero, el apoderado sustituido será responsable por los actos del sustituto, cuando éste fuere notoriamente incapaz o insolvente. En la segunda hipótesis en cambio, no habrá responsabilidad del apoderado antecesor (véase al respecto el numeral 351 de la obra citada de **Gerardo Trejos y Marina Ramirez**, pag.215).

En el caso se los **poderes sucesivos o subpoderes** ocurre en cambio cosa distinta, pues se presentan éstos, cuando opera un acto por medio del cual el representante (apoderado) otorga la facultad de representación en una tercera persona, para que en forma definitiva, pero de manera concurrente o paralela con él, realice en nombre y por cuenta del representado, el negocio o negocios "representativos" de que se trate, según le fueran asignados en un principio a él. Es decir, se trata de la figura en que un apoderado otorga un poder a otro, no en su carácter personal sino como representante de un tercero, a quien se reputarán también todos los efectos de aquellos actos ejecutados por nuevo mandatario.

De lo dicho, se extrae en forma inmediata que la diferencia esencial de esta figura con la sustitución radica en el hecho de que allá se da una supresión - total o parcial- del primitivo poder, pues según se dijo, se elimina de la relación jurídica al apoderado sustituido; en tanto que aquí, ese apoderado originario mantiene vigente su status, y en consecuencia, su relación jurídica con el poderdante. De hecho, aquel primitivo representante otorga un nuevo poder al tercero, en ejercicio y ejecución de su cargo, sin que por ello se extinga su mandato representativo. Podríamos decir con **Sánchez Urite**, siguiendo una terminología conceptual distinta a la suya, que el subpoder es un apoderamiento que el representante otorga en nombre del representado y para él, por lo que debe diferenciarse de la sustitución del poder, denominada también como transferencia de poder, ya que en este

último caso, el representante originario desaparece de la relación (op. cit. p.p. 164-165).

Pero de esa diferencia básica señalada anteriormente, se desprenden otras subsecuentes que permiten una mayor claridad y diferenciación de ambas figuras. En efecto, aquí no puede decirse que opere una cesión, o más exactamente un subrogación, pues con el nuevo poder no se extingue el original. Y es esto lo que realmente opera, **un nuevo poder que una persona como apoderado otorga a otra**. Siguiendo a Sánchez Urite, podríamos decir que el representante principal efectúa el apoderamiento de un subdelegado, a nombre de su mandante y con efectos para éste; lo que a nuestro modo de ver no es ni mas ni menos que un nuevo acto jurídico de representación, distinto, aunque dependiente del primero. Es distinto en cuanto puede tener un objeto igual o más reducido que el primero, en cuanto intervienen sujetos diferentes (ya no A y B, sino B y C), y en razón de que operan en una situación temporal diversa. Pero a su vez, se encuentran entrelazados, pues este último nace a consecuencia del primero. Como lo señala el autor argentino de cita:

> "El poder jurídico del subdelegado en orden a concluir negocios jurídicos para el representado se funda en dos apoderamientos conectados entre sí: el del apoderado principal efectuado por el representado, y el del subdelegado efectuado por el apoderado principal o primitivo u originario" (op. cit., pag. 151).

A esta figura del subpoder, no alude, al menos en forma expresa nuestro ordenamiento jurídico.

a - 5: La Extinción del Poder.

Por último. sobre este tema del poder. conviene referirse de manera muy breve a sus causas de extinción, señaladas en forma general para el mandato en el artículo 1278 del Código Civil. Sería inoportuno aludir aquí a cada una de ellas, además de reiterativo e innecesario, pues de éstas se ocupa con amplitud la doctrina, la que probablemente sólo citaríamos con inadecuada alteración. En todo caso, valga la oportunidad para puntualizar algún detalle en cuatro de las que allí se mencionan.

a-5-1: La extinción del plazo.

En primer término señala el inciso 2) del numeral supracitado, que termina el mandato (en este caso, representantivo):

> *"Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato"*

Ese término por el cual se ha conferido el poder, se contabiliza como es obvio, desde el momento mismo en que se otorga el mandato representativo y no desde la inscripción, pues esta opera tan solo como un requisito de publicidad y afectación a terceros, que extiende sus efectos de manera retroactiva al momento en que se emitió el acto, si es que no hay obstáculo registral o jurídico alguno.

a-5-2: La renuncia del apoderado.

Se establece también como causal de terminación del mandato en el inciso cuarto del mismo artículo, **la renuncia del mandatario**. No obstante, es preciso recordar que la renuncia simple, como acto exclusivo y aislado del representante, no basta para tener por extinguida la relación, puesto que a tenor del artículo 1285, ese mandatario tiene la obligación de continuar en aquellos negocios cuya paralización pueda perjudicar al mandante, hasta que avisado éste de la renuncia, haya tenido tiempo bastante para proveer al cuidado de sus intereses. Mas simple, no se tiene por efectiva la renuncia al poder, sino hasta que se haya comunicado con la suficiente antelación al poderdante. Aceptar lo contrario, podría implicar serios perjuicios para este especial mandante al verse sorprendido con el abandono que de su cargo hizo su apoderado en perjuicio de sus bienes, obligaciones o cargas.

a-5-3: La extinción del plazo y la renuncia en materia mercantil.

Esta disposiciones sin embargo, deben concordarse en materia mercantil, con los artículos 19, 22 , 186 y 235 incisos c) y d) del Código de Comercio, por cuanto en los primeros se señala el transcendental principio de la **inscripción del acto** en materia comercial como requisito sine qua non para la afectación de terceros, contrario a lo que ocurre como regla en el derecho civil, en donde basta la presentación al Registro

para la protección o perjuicio de aquellos terceros (artículo 455 C.C.) (al respecto puede verse la resolución del TSCA. Secc. II.
No 4234 de las 10: 00 hrs. del 6 de diciembre de 1988). Así tenemos que como ejemplo básico, que si al momento en que se contrajo la obligación, la sociedad no se había inscrito aún en el Registro Público, lo que ocurrió hasta mucho tiempo después, no puede demandársele en proceso ejecutivo, pues no existía a la vida jurídica. En ese caso, los responsables directos serán los socios que adquirieron el crédito (art.22 del Código de Comercio.). E igual ocurre en el evento de que se inscriba la liquidación anticipada de una sociedad anónima, pues habiendo dejado de existir no puede demandársele, por lo que se transfiere su responsabilidad a los socios que la componían (al respecto puede verse entre otras, la Resolución del **TSCA. Secc. II. No 2834** de las 8:00 hrs. del 2 de abril de 1987 y del **Tribunal Primero Civil**, la No **314** de las 7:40 hrs. del 14 de abril de 1981).

Pero aún más relevante que lo anterior - aunque vinculado a ello-, resulta lo dispuesto por el artículo 186 mencionado, según el cual:

> "Concluido el plazo para el que fueran sido designados, los consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones hasta el momento en que sus sucesores puedan ejercer legalmente sus cargos".

Al amparo de esta norma se ha tenido como válida la notificación efectuada a aquel representante de una sociedad

cuyo período de nombramiento le venció con anterioridad a la actuación judicial de referencia. Sin embargo, es preciso dejar claro que para este supuesto se ha exigido como requisito de manera unánime la designación (aún no inscrita) del nuevo representante. Es decir, para todos los efectos legales, se mantiene en vigencia la representación del consejero al que se le extinguió por razón del tiempo su mal denominado "mandato" , siempre y cuando se hubiere designado el nuevo representante, pues éste no entrará legalmente a ejercer su nueva función sino hasta que el acto se inscriba, según quedó visto. Como puede verse, se trata de una situación transitoria, en donde el legislador ha querido proteger a los terceros y a la misma sociedad sin dejarla acéfala, lo que no puede extenderse, claro está, a una situación indefinida, como ocurriría en el supuesto de que no hubiere sustituto. Al respecto y a manera de ejemplo, puede citarse entre muchas la resolución de la **Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo**, No 302-92, de las 11:30 hrs. del 31 de marzo de 1992, en la que se dijo:

"Redacta la Juez León Feoli y ;

CONSIDERANDO:

III.- El punto central sobre el que versa el recurso, estriba en determinar si la empresa accionada fue bien notificada en la persona del señor Q.V. , cuyo nombramiento como representante se encuentra con el plazo vencido. El Juzgado con base en el artículo 186 del Código de Comercio, llegó a la conclusión de que la diligencia se encuentra bien realizada, por

> estimar que debe mantener esa condición hasta tanto su sucesor no pueda legalmente ejercer el cargo y consecuente-mente denegó la nulidad planteada. La autorización de continuidad de los representantes de una sociedad, una vez concluido el plazo para el que fueron nombrados, tiene como requisitos, la existencia de sucesores nombrados, que legalmente puedan ejercer el cargo, situaciones que en la especie se echan de menos, pues la certificación registral apuntada a los autos por el propio autor, nada refiere sobre el particular, lo que es de trascendental importancia dado que de la relación de los artículos 455 y 1251 del Código Civil el ejercicio de estas funciones está sujeto al amparo registral" (en igual sentido pueden verse las resoluciones del mismo Tribunal No 4956 de las 9:30 hrs. del 9 de agosto de 1981; 4401 de las 10: 15 hrs. del 16 de diciembre de 1980 y entre muchas del Tribunal Superior Civil, la No 618 de las 8:30 hrs. del 28 de julio de 1976).

En relación con este punto, han surgido cuestionamientos sobre la aplicabilidad del artículo 186 a la hipótesis en que, el representante **renuncia** a su cargo antes de la extinción de su período. Nótese que el artículo se refiere sólo al evento en que le hubiere concluido el plazo, sin embargo, la tesis mayoritaria jurisprudencial, ha sido la de extender dicha prórroga del nombramiento también a este supuesto., tesis que

compartimos en todo por razones de orden práctico de y la justicia misma. En ese sentido ha indicado el Tribunal:

"Redacta la Juez Ferrero Aymerich; y,

CONSIDERANDO:

II.- Que como acertadamente se indica por parte de la autoridad de primera instancia, la renuncia que a su cargo de Presidenta de la sociedad demandada hizo la señora R. C. U. no puede perjudicar al ente acreedor, ya que efectivamente, los ordinales 19 y 22 del Código de comercio preceptúan, que la constitución de sociedades, sus modificaciones, disoluciones, fusión y cualquier otro acto que modifiquen su estructura deben ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil y que tal omisión, no produce efecto legal alguno en perjuicio de terceros. Se auna a lo anterior, el criterio que se ha sostenido por parte de este Tribunal y en estricta aplicación del artículo 186 del mismo cuerpo normativo en el sentido de que, hasta tanto los sucesores no puedan ejercer legalmente sus cargos, los anteriores deberán continuar en el desempeño de sus funciones; situación que es la del sublitem, en razón de que hasta tanto no se inscriba como corresponde la renuncia a su cargo, y el nombramiento del sustituto, la señora C. debe continuar ejerciendo las funciones que le fueron encomendadas."

Con esta resolución debe entenderse modificado el criterio

del Tribunal sobre este mismo aspecto, vertido en el voto No **386-89** de las 9:45 hrs. del 5 de setiembre de 1989.

La expuesta fue incluso la tesis originaria y prevaleciente del Tribunal, que ya desde 1982 había señalado con precisión los requisitos propios de la renuncia del consejero para poderse tomar como válida, además de aceptar la prórroga en el ejercicio de aquel representante que renuncia hasta tanto no se inscriba la sustitución. Se indicó en esa oportunidad lo siguiente:

"Redacta el Juez Vindas Baldares; y

CONSIDERANDO:

III. ... El Presidente de una sociedad anónima es mandatario, como consejero, que tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma de acuerdo con las facultades que se le otorguen. Su renuncia, y subsiguiente nombramiento del sustituto, que deben darse como actos concomitantes puesto que implican una modificación a la estructura social, no es válida por sí misma, y en consecuencia no surte efecto alguno legal en perjuicio de terceros ni extingue su responsabilidad ante la sociedad, si no se cumplen los siguientes requisitos: a) Que para su conocimiento y aceptación, sea planteada ante la asamblea general y esta haga el nombramiento de nuevo Presidente; b) Que ambos acuerdos sean protocolizados; c) Que se publique un extracto de la Escritura de Protocolización de dichos acuerdos, en

> la Gaceta; d) Que esa escritura se inscriba en el Registro Público, Sección Mercantil. Mientras no se logre la inscripción de la sustitución de personas, el Presidente que renunció continúa ejerciendo la representación judicial y extrajudicial de la sociedad de acuerdo con el mandato que se le confirió. Esa es la doctrina que surge de los artículos 19, 22, 182, 191 inciso c) y 235 del Código de Comercio, 1251, 1278 inciso 4o , 1285 y 1287 párrafo final del Código Civil." (Resolución del TSCA. Secc. II. No 359 de las 13:45 hrs. del 7 de julio de 1982).

Esta prórroga temporal de la representación que dispone el 186 del Co.Co., de cuyos requisitos venimos hablando, no se aplica sin embargo a las **sociedades de responsabilidad limitada**, en las que de no haberse designado nuevo representante legal (para lo cual se requiere publicación del acuerdo respectivo y registro formal de la escritura de protocolización), debe entenderse **reelegido automática e indefinidamente el personero al que le venció el plazo de nombramiento**, puesto que por otra parte, no se requiere la publicación y registro de esa reelección, según se extrae del artículo 89 del Código de Comercio y de lo resuelto por el **T.S.C.A. Secc. II**. No 1354 de las 10:50 hrs. del 5 de abril de 1984.

a-5-4 : La revocación

Pero el artículo central de comentario (1278 del Código Civil), también dispone como una causal más de terminación del

mandato, la **revocación**. En este aspecto nos limitaremos a mencionar la necesaria concordancia que de este inciso tercero debe hacerse con el artículo 1280, que regula la figura de la revocación tácita ocurrida cuando el poderdante confiere un nuevo poder a un tercero para que realice el mismo negocio o acto otorgado en un principio al anterior representante. Como lo indica don **Diego Baudrit**, se trata *"... del otorgamiento de poderes sucesivos, con idéntico contenido" en donde "... el poder previo queda revocado de pleno derecho con el otorgamiento del sucesivo, si no se ha indicado circunstancia en contrario" (op. cit., pag 5).*

a-5-5: La extinción del poder sustituido y del subpoder.

Por último, no podemos concluir el tema sin referirnos a la hipótesis diversa de la extinción del poder sustituido y del subpoder, a los que aludimos páginas arriba. En ambas figuras, es el apoderado (debidamente autorizado para ello), el que transfiere el mandato representantivo a una tercera persona, lo que da pie a cuestionarse: ¿ Qué sucede, si durante la intervención de este tercero como apoderado sobreviniente, el representado revoca el mandato base que había conferido con la posibilidad de sustitución o de subapoderamientos ?. Al respecto, y de acuerdo con todo lo dicho, es lógico y obvio pensar, que si en la sustitución del poder hay desplazamiento (total o parcial) del apoderado originario, en una especie de cesión o subrogación, que no implica un nuevo acto de apoderamiento, sino la transmisión del ya existente, extinguido

en cuanto al apoderado "principal" y antecesor, extinto también en relación al sustituto, pues a lo que pone fin el representado, no es a otra cosa que a su mandato representativo, sin importar la persona que desempeñe como apoderado sustituto, gracias a su misma autorización previa. Lo contrario, implicaría obligar a este representado a soportar al sustituto de manera indefinida, o a revocar su mandato en forma doble, tanto al originario como al nuevo representante. Es a esto a lo que se refiere cabalmente el artículo 1278 en su inciso octavo cuando señala:

> "El mandato termina:
>
> 8o -- Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio y por razón de ellas."

Dicho de otro modo, la cesación del poder primitivo acarrea también la extinción de las facultades del sustituto. Pero cosa distinta sucede si se trata de subapoderamientos, en los que se extingue el poder principal y originario. Estimamos que aquí no caen los poderes sucesivos otorgados, pues son éstos, nuevos actos, vinculados al poder principal (en cuanto se derivaron de él), pero no dependientes del mismo. Si el representado desea poner fin a los diferentes poderes y subpoderes vigentes, deberá revocarlos uno a uno, de manera independiente, ya sea en forma separada o conjunta, sobre todo si se trata de personas jurídicas, en donde la extinción de los actos posteriores no tendría ninguna razón de ser.

Reconocemos que este inciso octavo no hace distinción

alguna entre ambas figuras (sustitución y subapoderamiento), pues alude tan solo a la *"cesación de funciones del mandante"* ; sin embargo, consideramos pertinente la diferenciación, incluso por aspectos de seguridad y dinamismo jurídico, máxime, si como se ha dicho, de personas morales se trata, pues en éstas ante que un mandato de representación, opera la **teoría del órgano**, en donde se ve al apoderado no como representante, ni mucho menos como mandatario, sino como un órgano por el que actúa directamente la persona jurídica, y no éste para la persona jurídica En todo caso, por si alguna duda quedase, es bueno informar que nuestra jurisprudencia se ha encargado de perfilar en forma nítida este aspecto específico del tema abordado, cuando señala que **entratándose de personas jurídicas (**privadas o públicas, agregamos nosotros**), en las que se hayan dado poderes sucesivos, la extinción del primero, no extingue la de los posteriores, pues a ellas no se aplica el inciso 8o del artículo 1278.** Señaló al respecto la antigua **Sala de Casación**, en la resolución número 69 de las 16:30 hrs. del 23 de agosto de 1978 lo siguiente:

> "Que el artículo 1278 inciso 8o del Código Civil , al disponer que el mandato termina" por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio y por razón de ellas", se está refiriendo a los casos en que el mandante inviste a otro de calidad de apoderado suyo, para que lo represente en el carácter especial que se deriva de sus funciones, como ocurre tratándose del albacea que

> confiere poder a un abogado, a fin de que actúe en su representación dentro del juicio sucesorio. El profesor Brenes Córdoba pone ese ejemplo del albacea y de su apoderado, y así aclara los alcances de la citada regla del artículo 1278 (ver "Las Obligaciones", párrafo 875, página 509, segunda edición).-Ahora bien, no hay duda de que la situación es distinta cuando la persona física que otorga el mandato en ejercicio de sus funciones lo hace en nombre de una persona moral. para que el mandatario represente a esa persona, pues en tal supuesto no tiene ninguna importancia que cesen aquellas funciones, desde luego que el mandante no es la persona física sino la persona moral en cuyo nombre se constituyó el mandato." (En igual sentido puede verse la sentencia del **TSCA.Secc.I.** No 9969 de las 16:40 hrs. del 27 de diciembre de 1987).

En todo caso, cabe señalar a modo de recordatorio final , que el acto que efectúe el apoderado, ignorando la cesación de su mandato, se reputa para todos los efectos, válido, y no solo para su poderdante sino para los terceros, quienes también serán protegidos, aún en el evento de que el apoderado ya tuviere noticia de su cesación cuando realizó el negocio jurídico, siempre y cuando aquellos hubieren actuado de buena fe (art. 1282 del C.C.). Con esto, no se hace mas que tutelar el principio de la protección a terceros de buena fe, y en última instancia, la seguridad del tráfico jurídico.

12- Exposición sucinta de los hechos.

En cuanto a los hechos no se requiere aquí una precisión especial (como sucede por ejemplo en el ordinario), pues no es necesaria una individualización de cada uno de ellos, ni remontarse al origen y aspectos previos del crédito. Bastará indicar la existencia del crédito, título que lo respalda, indicación del incumplimiento y su causa, fecha del mismo, etc.

3- Fundamentos de Derecho

En relación a los fundamentos de derecho, no hay mayor comentario que hacer, pues la parte debe indicar en su demanda ejecutiva las disposiciones legales que fundamentan su pretensión y le dan acceso al ejecutivo. Aquí sin embargo, se ha dado una práctica viciada y además reprochable de litigante, pues en múltiples ocasiones fundamentan la demanda haciendo citas de derecho muy generales e imprecisas, como por ejemplo: "*Fundo mi acción en el artículo 1 del Código de Comercio; ,1, 2, siguientes y concordantes del Código de Comercio y en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional*". Citas como esas violentan el espíritu mismo de la disposición y resultan a todas luces inconvenientes. No obstante, de algún modo se está- realizando una cita de derecho, por lo que no parece posible hacerle la prevención en ese sentido, máxime si se

parte del principio de que el Juez conoce el Derecho *("iura non vit curia").*

4- Pretensión

La pretensión es un aspecto que en la demanda ejecutiva simple ha generado algunos problemas, puesto que en muchos casos el actor se limita a pedir en ella que se despache ejecución y se embarguen tales o cuales bienes, sin mencionar nada acerca de la condenatoria en capital, intereses y costas en la fase de sentencia. De allí que en los procesos en los que se detecta inicialmente la omisión, debe prevenirse el cumplimiento de la misma, pues, si pasa desapercibido también para el Despacho, en sentencia no habrá mas salida que declarar inadmisible o sin lugar la demanda, toda vez que el Juez en este caso, está limitado por la pretensión de la parte, y siendo así, no puede otorgar lo que ella no ha pedido (principio de congruencia). Ahora bien, dijimos que en la fase inicial del proceso puede corregirse el defecto, pero hasta cuando podemos considerar que estamos en la fase inicial ?. Al respecto el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda ha señalado que :

> ***"Redacta la Juez Ferrero Aymerich, y; ... III.***- *Que de acuerdo con lo expuesto se obtiene, que en nuestro medio también es de aplicación el principio de la litis contestatio, por medio del cual, la accionada puede proceder al cierre del ciclo inicial de la*

litis, con la contestación de la demanda, momento en el que se traba la relación procesal y después de precluida esa etapa por ejemplo, no es posible legalmente, llamar o traer a juicio a terceras personas y el proceso en este estadio, solo puede terminar normalmente por sentencia de cognición, esto es, cuando decida definitivamente las cuestiones debatidas o por sentencia que resuelva sobre excepciones perentorias o bien, anormalmente, por sentencia recaida en incidente que ponga término al principal objeto de la acción por hacer imposible su continuación o reiteración (...) Que partiendo de todo lo expuesto, el Tribunal concluye, que por el estadio en que se encuentra el proceso de que se conoce, en el que la relación procesal ya quedó fijada para ambas partes y dada la imposibilidad e ilicitud de proceder a anular todo lo actuado según lo hizo la autoridad de instancia, no queda más a este órgano colegiado, que proceder a revocar la resolución venida en alzada para que se continúe la tramitación de los procedimientos y sea en sentencia, que se emita el criterio del caso" (Resolución No 426- 93 de las 10:15 hrs. del 19 de agosto de 1993)

En términos simples, luego de trabada la litis (contestación de la demanda indica el Tribunal) no puede corregirse la omisión de la pretensión.

a- Innecesaria solicitud expresa para el decreto de embargo

También ha sido objeto de algún cuestionamiento la pretensión inicial del proceso ejecutivo, es decir, la solicitud para despachar ejecución y decretar embargo en otras palabras, ¿ es necesario que en la demanda se soliciten dichas actuaciones en forma expresa ? ¿ Si no se hicieran no podría entonces despacharse ejecución ? Y la duda toma mayor seriedad si se observa la redacción del artículo 439 del Código de comentario, que luego de remitir al artículo 433 para efectos de los requisitos de demanda, señala: *"En el escrito se solicitará el despacho de ejecución y el decreto de embargo"* .
Al respecto consideramos que la respuesta es negativa, pues es necesaria la pretensión para la condenatoria del demandado en sentencia, pero no para despachar ejecución, diligencia que parece consecuencia automática de una demanda completa y presentada en forma, pues en contraposición a lo dispuesto en el numeral 439 recién transcrito, tenemos lo preceptuado en el artículo siguiente (art. 440), en donde se dispone:

> *"Si el actor acreditare su personalidad, y si el título presentado fuere ejecutivo, el juez despachará la ejecución y ordenará el embargo de bienes..." (la letra en negro no es del original)*

De modo que el juez para efectos de despachar ejecución deber revisar la "personalidad" (sic) del actor, o mas bien su personería, y que el título presentado sea realmente ejecutivo, sin necesidad de que el acreedor-demandante solicite expresamente que se despache ejecución y se decrete embargo. En ese caso, deberá procederse de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 440 mencionado, con la salvedad de que el decreto de embargo debe ordenarse en forma general, sin indicación de ningún bien particular, los que deberá- señalar el acreedor posteriormente para expedir la orden correspondiente sobre un bien concreto.

b- Costas No Pedidas.

Aunque no hayamos abordado aún el tema de la sentencia o de las costas, sí es preciso dejar sentado desde ya, que no se requiere en sentido estricto formal y expresa pretensión sobre costas, pues aunque no se soliciten, el Juez está obligado a efectuar pronunciamiento expreso al respecto. Así lo indicó en forma reiterada la jurisprudencia de nuestros Tribunales con anterioridad al Código Procesal Civil vigente, el que ahora de modo expreso recoge el principio en el artículo 221.

5- Pruebas.

En cuanto a la prueba del proceso ejecutivo, esencialmente está- referida al título mismo, el que en materia civil común por lo general debe presentarse en original, no así en la jurisdicción civil de hacienda en donde la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional permite a los Bancos en su artículo 70 párrafo 5o , que presenten una fotocopia debidamente certificada por la Gerencia del documento original en el que conste la obligación. Ya indicamos páginas atrás que esta competencia que otorga la ley al Gerente para certificar las fotocopias, puede y ha sido delegada a otros funcionarios del mismo Banco, luego de publicado el aviso correspondiente en el

Diario Oficial "La Gaceta". Las fotocopias deben ser nítidas, es decir, fácilmente legibles, pues de contrario, deberá prevenirse una en buenas condiciones, además, deben cancelar los timbres de ley.

De este beneficio también pueden gozar las demás instituciones autónomas y semiautónomas, cuando se acojan en general y en forma **expresa** a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional citada, según lo permite el artículo 2 de la Ley No 4937 de 24 de diciembre de 1971, según se indicó páginas arriba. Cabe agregar que la adopción de dicha ley lo es para todos los efectos de ejecución y no solo de para efectos del título según veremos adelante. Por lo pronto basta señalar que el acogimiento a dicha ley debe ser claro y expreso, de lo contrario se le da el mismo tratamiento de un particular común.

Ante esta posibilidad de certificar las fotocopias de títulos como regla general, se dan algunas excepciones creadas esencialmente por vía jurisprudencial para el caso de las cédulas hipotecarias y para los cheques. Esto porque se estima que son títulos dirigidos a una fácil circulación, de modo tal que el Despacho Judicial debe garantizarse que el Banco los posee, máxime en el caso de las cédulas hipotecarias, las que para su cancelación requieren de ser incineradas, aún cuando la extinción provenga de una resolución u orden judicial, de acuerdo con el mandato del artículo 439 del Código Civil, el que en su párrafo final señala:

"En el primero y último casos junto con el documento

inscribible de cancelación deberá presentarse la cédula correspondiente para que el Registrador al firmar la cancelación, la incinere" .

Este artículo debe concordarse con el inciso **d)** del numeral **24** y el artículo **86**, ambos del **Reglamento del Registro Público**. Es por esto que sobre la necesaria presentación de los títulos originales, la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, señaló en la resolución número 1414 de las 7:30 hrs. del 29 de mayo de 1984 lo siguiente:

"Que, siendo la CEDULA HIPOTECARIA un título de crédito por el que sólo responde la finca gravada sin comprometer personalmente a nadie el pago de la deuda, teniendo (sic) fuerza ejecutiva y reputándosele dueño al portador si contiene endoso nominal o en blanco, la presentación de la cédula es indispensable en el juicio correspondiente para sustentar la acción ejecutiva hipotecaria... Aún cuando, conforme a la Ley Orgánica del Sistema del Bancario Nacional, se hubieran presentado en este juicio fotocopias de cada una de las tres Cédulas Hipotecarias, debidamente certificadas por la Gerencia del Banco, tampoco pudo haberse cursado la demanda como ejecutiva hipotecaria por haber sido presentadas las originales en otro juicio, ya que en esa hipótesis se trataría de un mismo título en cada caso."

6- La cuantía.

La cuantía de la demanda ejecutiva, no por ser de fácil fijación, ha dejado de generar sus inconveniencias, pues en la mayoría de los casos se realiza una estimación excesiva, con el criterio de algunos litigantes de que la estimación en el ejecutivo corresponde, al igual que para el embargo, a capital, intereses y cincuenta por ciento. Y el aspecto reviste especial importancia, pues en materia civil de hacienda la estimación no sólo fija la competencia del órgano jurisdiccional de alzada, sino que además, limita de antemano el máximo de las pretensiones pecuniarias de las partes, como regla general en todo proceso (artículo 18 del CPC) En realidad las reglas sobre este aspecto están claramente determinadas en los incisos 2, 3, 5 y 8 del artículo 17 del Código Procesal Civil. En ese sentido se dispone que en las obligaciones pagaderas a plazos se calculará el valor por el de toda la obligación, como sucedería por ejemplo con una deuda de ochocientos mil colones pagadera mensualmente por el plazo cinco años, pues al momento en que se haga exigible por el incumplimiento de una mensualidad (si así está pactado) se estimará el proceso por la totalidad de la obligación, es decir, ochocientos mil colones, o en su caso, el saldo adeudado en ese momento. Pero además, en esa estimación deberán incluirse a título de perjuicios, lo intereses que hasta la presentación de la demanda hayan transcurrido, de conformidad con el inciso 3) del artículo mencionado. Aquí, en consecuencia, no se computan como parte de la estimación los

intereses que operen con posterioridad a la demanda, tal y como lo señala el inciso de comentario en concordancia con el artículo 18 Ibidem, de manera que en cuanto a estos no rige el límite máximo de la pretensión.

Cabe agregar que en aquellas demandas que cubran varios créditos contra un mismo deudor (como podría ser el caso de un hipotecario con créditos de diverso grado), la cuantía se calculará por el valor de todos los créditos reunidos (inciso 5 art. 17). Asímismo, en los procesos en los que se reclama el pago de cédulas hipotecarias, la cuantía se determina por el monto total de la obligación por el que fueron emitidas (inciso 8 art. 17).

7- Lugar para oír notificaciones.

Respetando la regla establecida en los artículos 175 y 185 del Código Procesal Civil, la demanda ejecutiva deberá señalar lugar para oír notificaciones, no solo para el auto inicial al demandado, sino para las suyas que con posterioridad se emitan, pues en caso contrario (caso de que lo omitan), se le aplicará al demandante la notificación automática, quedando notificado de las resoluciones posteriores con el sólo transcurso de 24 horas después de dictadas.

8- Firma de la parte o partes.

La demanda obviamente debe estar firmada por el o los correspondientes acreedores demandantes, o en su caso, por su representante o representantes, como ocurre siempre en el caso de personas jurídicas. Aquí debemos ser enfáticos en el sentido de que, si la demanda o un escrito común no está debidamente firmado por la parte o de quien interviene como gestor judicial (de acuerdo con el artículo 286 ibidem), no es estrictamente una gestión judicial, y en el caso de la demanda, no podemos tenerla como tal, por lo que no queda otra salida que rechazarla de oficio por inadmisible. Para el caso de que se trate de firmas ilegibles, al pie de la misma deberá indicarse con claridad el nombre de la persona que rubrica, sobre todo para el caso de representantes de entes públicos, como son los bancos, en donde muchas veces el mismo representante es abogado, de manera que firma y autentica por sí, no obstante, el Despacho desconoce su nombre, o al menos no tiene certeza de que efectivamente sea ese funcionario. En esos casos, de no indicarse el nombre, deber prevenirse. También consideramos válida la huella digital que se consigna ya sea en el título (en este caso del deudor), o en su caso, de la demanda (del acreedor claro está), cuando se justifique tal circunstancia, siempre y cuando por supuesto, vaya acompañada de la respectiva autenticación, que de seguido mencionamos.

9- La Autenticación

La necesaria firma de la parte, no debe confundirse con la autenticación del abogado, que también constituye un requisito de la demanda. En efecto, el artículo 114 del Código Procesal Civil exige como requisito para todo escrito (dentro del cual se incluye la demanda) la firma de un abogado que autentique la del petente, salvo que el propio gestionante sea abogado como ya se dijo. Si la demanda o cualquier otro escrito no viene autenticado, la ley confiere un plazo de tres días para que el abogado cumpla con lo omitido. Se había interpretado que dicho plazo debía contarse a partir del día siguiente de presentado el escrito, y que no se concedía mediante resolución judicial, sino que tan solo se dejaba pendiente el documento en la oficina judicial, en espera que el abogado, por su propia cuenta, se presentara al Despacho. De ser así, procedía a autenticar el escrito ante el secretario del "tribunal", quien dejaba constancia de la hora y la fecha en que se llevaba a cabo. Si en ese plazo no se presentaba el abogado, se denegaba la gestión, que para nuestros efectos, era la demanda ejecutiva. Dicha interpretación y práctica fue declarada inconstitucional recientemente, cuando la Sala encargada de la materia puntualizó en la necesidad de emitir una resolución formal sobre la materia, empezando a correr el plazo de los tres días según la regla general establecida en el mismo Código, es decir, al día siguiente hábil de la notificación efectuada. De esta manera se declaró inconstitucional la frase

del artículo 114 que señalaba: *"contados a partir del día siguiente a su presentación"* (Voto número 3495-94 de las 14:57 hrs. del 12 de julio de 1994, publicado en el Boletín Judicial número 143 del 28 de julio de ese mismo año. Expediente No 467-94).

Sobre la posible subsanación del defecto apuntado y la sanción por no hacerlo, se ha presentado alguna confusión que no debería ser, pues el artículo está dado para la autenticación (patrocinio letrado) del escrito, no para la firma del a parte gestionante, como se ha interpretado en alguna oportunidad. Es decir, si un escrito no viene firmado por la parte que gestiona, no debe aplicarse esta disposición del 114, la cual está dada, como hemos dicho, para la autenticación.

En esta materia de autenticaciones, sí existe disposición normativa escrita que señala expresamente el deber del abogado de poner su nombre al pie de la firma al momento en que autentica un escrito. Al respecto dispone el artículo 20 del Reglamento Interior del Colegio de Abogados lo siguiente:

> *"Los abogados al suscribir los pedimentos o escritos dirigidos a las autoridades judiciales o administrativas, deberán escribir en forma legible el nombre y apellidos debajo de la firma. Los infractores serán corregidos disciplinariamente por la Junta de Gobierno, a solicitud del interesado o por queja de la respectiva autoridad"* .

Ahora bien, para el caso en que el propio representante o

accionante, sea abogado y no firme el escrito en ninguna de sus condiciones, consideramos que al carecer de firma el documento (dado que el autenticante es la propia parte), no debe darse el plazo de tres días que estamos comentando, pues. según dijimos líneas arriba, un memorial sin ninguna firma no puede considerarse como gestión judicial, es decir, es inexistente para todo efecto. Por ello no compartimos el criterio externado por la Sección del Tribunal Superior Contencioso que en un caso particular rechazó una gestión que carecía de toda firma, pues apoderado general judicial del ente acreedor (a su vez abogado que autenticaba por sí) no rubricó el escrito, **pero luego de conferidos los tres días** que estipulada el 114 del Código de Rito. Señaló el Tribunal sobre ese aspecto:

> *"De la filosofía que informan los numerales 114 y 561 del Código Procesal Civil, el escrito en que se formule una apelación, debe venir firmado por la parte con derecho a apelar y debidamente autenticado, cuando sea pertinente o en su defecto y bajo ciertas circuns-tancias, por el abogado que sin tener poder, hubiere autenticado algún escrito en el proceso. En el memo-rial en que se formuló la que ahora se conoce, se omitió la rúbrica del apoderado general judicial de la entidad actora y al no haber sido subsanada la omisión en el plazo de tres días, no debió admitirse la ges-tión. "(el subrayado y la negrita no son del original. Resolución No 28-93 de las 11:15 hrs. del 16 de febrero de 1993. Expediente*

del Juzgado Primero Con-tencioso Administrativo y Civil de Hacienda No 4758- 91)

10-Timbres de la Demanda.

La demanda deberá presentar los timbres correspondientes debidamente cancelados según lo dispone la ley. Aquí es preciso señalar que pese a lo dispuesto por el artículo 6 del Código Procesal Civil, en cuanto estipula la tramitación de los procesos en papel de oficio con reintegro de timbre fiscal, lo hace con sometimiento a lo que disponga la ley en ese sentido, sin tomar en cuenta que las disposiciones del Código Fiscal (artículos 249, 250 y 253) que regulaban las sumas correspondientes a timbres fiscales, fueron derogadas con anticipación, mediante ley No 6292 de 26 de julio de 1984, publicada en el Alcance No 13 de la Gaceta No 149 de miércoles del 8 de agosto de 1984. De modo que hoy por hoy, los asuntos en materia civil, comercial y contencioso administrativo se tramitan en papel común, sin necesidad de reintegro, puesto que no existe.

a- Timbres del documento base.

Sin embargo, lo dicho sólo rige para el papel con el que se tramita el proceso, no así para los otros documentos que deban presentarse junto con la demanda, como es el caso del mismo título ejecutivo, o de la copia certificada de ese documento que deberá cancelar las especies correspondientes, o de los

poderes que se adjunten, salvo que por ley expresa se encuentren exentos de dicho pago, tal y como ocurre en varios casos, según veremos. Aquí sí vuelve a tomar importancia el aspecto de los timbres, sobre el cual trataremos de hacer algunas precisiones.

Antes de cualquier otra observación es necesario insistir que en materia de timbres fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el denominado "Reajuste Tributario" (aprobado por ley No 7088 de 30 de noviembre de 1987, publicado en el Alcance No 34 - A a la Gaceta No 229 del lunes 30 de noviembre de 1987) en su artículo 7, se aumentó el impuesto por timbre fiscal en cualquier documento, en un veinticinco por ciento del monto ya establecido. Señala la indicada norma:

> *"Se incrementan en un veinticinco por ciento (25%) los montos de las tarifas y tributos incluidos en el Código Fiscal".*

Asimismo, debe tenerse clara la diferencia entre lo que corresponde a reintegro por concepto de papel, conforme lo establece el Código Fiscal, para aquellos casos en los que el documento se confeccione en papel común aún cuando requiera de un valor específico, lo que se subsana mediante el reintegro en timbre fiscal por el valor correspondiente. Este timbre por concepto de papel, que también se paga en fiscal, es distinto al pago del impuesto simple y llano por timbre fiscal. Los primeros se encuentran regulados en los artículos 238 y siguientes del Código mencionado, en tanto que los segundos

están contemplados en los artículos 271 y siguientes del mismo cuerpo normativo.

En cuanto a las copias certificadas del título que presentan generalmente los bancos, tenemos que deben cancelar los siguientes timbres: por concepto de reintegro de papel en timbre fiscal, paga doce colones con cincuenta céntimos (¢12.50) de conformidad con el inciso 9) del artículo 247 del mismo Código Fiscal. Por concepto de timbre fiscal paga seis colones con veinticinco céntimos (¢6.25) por la primera hoja o fracción, y dos colones con cincuenta céntimos (¢2.50) por cada hoja adicional o fracción, ello de acuerdo con el inciso 21) del artículo 273 del Código de referencia. Aquí sin embargo, se presenta un problema serio, pues si bien es cierto la norma dispone ese monto, y así lo han aplicado reiteradamente la mayoría de los Despachos Judiciales, tenemos que el inciso de comentario se refiere tan sólo a las certificaciones o copias de expedientes, o de actas o asientos de libros, apud acta o extendida por separado, lo que no incluye al menos en forma expresa, las copias certificadas de los documentos de crédito suscritos en un Banco, a no ser que se considere que la copia del título es parte de un expediente de crédito que tramitó la entidad bancaria y así colocarlo en esa norma especial del artículo 273.

Además debe cancelar un timbre forense y uno de rehabilitación, cada uno por el monto de un colón (¢1.oo). El primero conforme lo señala el artículo 7 de la Ley No 176 de 17 de agosto de 1944 y sus reformas, el cual dispone:

"Toda certificación expedida por las dependencias de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Instituciones Autónomas y los notarios, pagará Timbre Forense por valor de un colón, salvo los casos contemplados en leyes especiales".

243 El segundo a tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley No 3890 de 19 de junio de 1967, reformado por ley No 5027 de 24 de julio de 1972, que a la letra dice:

"Las fotocopias certificadas que se hicieran en máquinas no instaladas por el Patronato Nacional de Rehabilitación, llevarán además un timbre de un colón (¢1.00), que se denominará "Timbre Patronato de Rehabilitación". Este timbre deberá agregarse también a toda certificación expedida por las oficinas de la administración pública, tanto de las dependencias de los tres Poderes del Estado, como de las de la administración descentralizada."

Asimismo deberá cancelarse un timbre de cinco colones (¢5.oo) de Archivos Nacionales, según lo dispuesto por la Ley de Archivos Nacionales (No 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en la Gaceta No 225 de 27 de noviembre de 1990), que también dispone en el párrafo final del artículo 6 lo siguiente:

"Por todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas del Poder central, las instituciones descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre de archivos de ¢5,00."

En cuanto al timbre forense y de rehabilitación se ha presentado alguna duda, por cuanto las leyes que los estipulan obligan a su pago en toda certificación extendida por un ente de la Administración Pública (ya aquí no nos limitamos a las fotocopias de los títulos en poder de un banco, sino hablamos de certificación en general), mientras que en multiplicidad de leyes especiales de los diferentes entes menores, se exime a éstos del pago de cualquier timbre (según veremos adelante). Ha surgido entonces la interrogante: ¿ debe cancelar un ente exento del pago de timbres en general, los correspondientes a forense y rehabilitación, al momento en que extiende una certificación con carácter ejecutivo ?. En el caso del forense, la respuesta es clara, pues la propia ley obliga al pago del mismo, **salvo lo dispuesto en leyes especiales**, de manera que en cuanto a él impera la norma que exime al ente del pago de "especies fiscales" (en general timbres). Igual solución debe darse en cuanto al de rehabilitación, pues debe imperar la ley especial sobre la general. Así lo ha entendido la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso que en un caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal revocó la prevención del Juzgado para el pago de timbres (fiscales, forense y de rehabilitación en ese momento) ordenando el curso de la demanda ejecutiva, en virtud de que aquella entidad está exenta del pago de dichos extremos (Resolución No **827-90** de las 10:00 hrs. del 23 de noviembre de 1990). En síntesis, podemos resumir diciendo que la certificación (incluyendo la fotocopia de un

título del Banco) que presente un ente público como título ejecutivo (**así como toda aquella que no corresponda a un asiento registral**) debe pagar los siguientes timbres, salvo que por ley esté exento de los mismos:

Reintegro	¢12.50
Fiscal	¢ 6.50 para la primera hoja
	¢ 2.50 para las restantes.
Forense	¢ 1.00
Rehabilitación	¢ 1.00
Archivos Nacionales	¢ 5.00

En el caso de certificaciones provenientes de los Registros Públicos, las certificaciones expedidas deberán agregar los siguientes timbres:

Reintegro	¢12.50
Fiscal	¢12.50 por cada asiento o que no hay inscripción.
Forense	¢ 1.00
Rehabilitación	¢ 1.00
Archivos Nacionales	¢ 5.00

Aquí debe tenerse presente que **las letras de cambio originales** (no hablamos ya de la copia certificada del documento base) **están exentas del pago de timbres fiscales**, conforme a la reforma efectuada al inciso 13) del artículo 273 del Código Fiscal, mediante Ley No 6292 de 26 de julio de 1984, publicada en el Alcance No 13 de la Gaceta No 149 de miércoles 8 de

agosto de 1984, la cual dejó sin efecto el contenido de ese inciso dispuesto por ley 6955 de 1984.

b- Entidades exentas de pagar timbres

Ahora bien, hemos señalado que todo ente público tiene que cancelar los timbres indicados a efecto de expedir una certificación, a no ser que se encuentre exento del pago de aquellos. Pero cúales entes pagan timbres y cúales no por exención de alguna norma especial ?. En este sentido debe recordarse también, lo dispuesto por la Ley No 7293 de 31 de marzo de 1992 (Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, Su Derogatoria y sus Excepciones), publicada en la Gaceta del viernes 3 de abril de 1992, en la que se mantienen todas las exenciones tributarias que se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones descentralizadas, a las municipalidades, a las empresas públicas estatales y municipales y a las universidades estatales (inciso L) del artículo 2). En consecuencia, estando plenamente vigentes, brindamos a continuación una lista no exhaustiva de aquellos entes públicos exentos y de los no exentos de acuerdo con la ley. Aquellos que no lo estén, deberán cancelar los fiscales, forense y rehabilitación correspondientes.

Entes exentos del pago de timbres.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Ley 6868 de 6 de mayo de 1983. Art. 20.

Municipalidades. Código Municipal

Ministerios Ppio de Inmunidad Fiscal

Consejo Nacional de Producción (CNP) Ley Orgánica No 2035 de 17 de julio de 1956, artículo 12 y Ley No 6050 de 14 de marzo de 1977.

Instituto Tecnológico de Costa Rica Ley No 6321 del 27 de abril de 1979 (art. 10)

Instituto Costarricense de Electricidad Ley No 6264 (caso de contrato, están exentas ambas partes)

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) Ley Orgánica No 1788 de 24 de agosto de 1954, art. 38. (ambas partes en caso de contrato)

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	Ley Constitutiva (ambas partes en caso de contrato)
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)	(en caso de contrato, ambas partes)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (ICAA)	Ley No 2726, art. 17 y Transitorio II de la Ley No 5915 de 12 de julio de 1976.
Empresa de Servicios Públicos de Heredia	Ley No 5889, art. 4.
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)	Ley Orgánica. art. 44
Asociaciones de Desarrollo Comunal	Ley No 3859, art. 37 (incluye Asociaciones de Desarrollo Integral) **No derogada** por Ley Reguladora de todas las Exoneraciones (art. 2 inc. p)
Instituto Mixto de Ayuda Social.	Ley de Creación. art. 31

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) Ley Orgánica. art. 25

Fundaciones Ley No 5338 de 28 de agosto de 1973. Art. 10. En cuanto contempladas en incisos d) y e) del art. 2 de la Ley Reguladora de Todas las Exonera...

Servicio Nal. de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) Ley No 6877 de 29 de julio de 1983, art. 21.

Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) Ley No 6756 de 5 de mayo de 1982, art. 158.

Servicio Nacional de Electricidad (SNEE) Ley Orgánica. Art. 71

Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL)

Junta Administrativa del Servicio de Eléctrico de Cartago. (JASEC) Ley No 3300 de 16 julio de 1964. Art.

inciso j)	
Consejo Nacional Cooperativo (CONACOOP).	Ley No 6756 de 5 de mayo de 1982, art. 136.
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	
Editorial Costa Rica	Ley No 2366 de 10 de junio de 1959, art. 8 inciso a).
Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)	Ley No 3091, art. 22 inciso b) y Ley No 5337, artículo 42.
Universidad Estatal a Distancia (UNED)	Ley No 6044, art. 19.
Archivo Nacional.	Ppio de Inmunidad Fiscal cuando actúa a través Ministerio Gobernación.
Registro Nacional	Ppio de Inmunidad Fiscal cuando actúa a través

	Ministerio de Justicia.
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)	Ley No 3286, art. 35.
Banco Central de Costa Rica.	
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.	Ley No 5347, art. 10.
Patronato Nacional de Rehabilitación	Ley No 3695 de 22 de junio de 1966, art. 5.
	Unicamente cuando se otorguen en su favor escrituras públicas.
Corte Suprema de Justicia	Principio de Inmunidad Fiscal
Asamblea Legislativa	Principio de Inmunidad Fiscal
Universidad de Costa Rica (UCR)	
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	Ley No 7031, art. 41.

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)	Ley 5251 de 11 de julio de 1973, art. 27.
Escuela Centroamericana de Ganadería	Ley No 4401 de 1 de setiembre de 1969.
Imprenta Nacional	Ley No 174 de 21 de setiembre de 1948 y Ley No 4961 de 11 de marzo de 1972.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. (CONICIT)	Ley No 5048 de 9 de agosto de 1972, art. 22
Consejo Nacional de Rectores (CONARE)	Ley No 7015. art. 49.
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)	Principio de Inmunidad Fiscal

c- Entes <u>NO</u> exentos del pago de timbres.

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)	
Instituto Nacional de Seguros (INS)	Art. 12 de la Ley No 12 de 30 de octubre de

1924.

Bancos Comerciales del Estado Excepto Banco Central (que no es banco comercial en todo caso)

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Consejo Técnico de Aviación Civil

Cooperativas. Ver alcances del art. 6 inciso d) de la ley 6756.

Centro Nacional de Mujer y Familia

Consejo Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)

Centro Para Promoción de las Exportaciones e Inversiones (CEMPRO).

Consejo de Seguridad Vial (CSV). Ver ley No 6324 de 24 de mayo de 1979 y oficio de la Contraloría General de la República

No 4680 de 13 de mayo de 1987.

Colegios Universitarios

Centros Agrícolas Cantonales

Instituto de Alcoholismo y Farmaco-dependencia (IAFA).	Ver oficios de la Contraloría Gral.Rep.Ns. 13366-87 y 1005-88.

Junta de Defensa del Tabaco

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.	Ley No 6158 de 25 de noviembre de 1977.

Junta Administrativa del Registro Nal. Decreto DE 17653- J de 29 de julio de 1989.

Junta Administrativa de la Dirección Nacional de Comunicaciones

Junta Administrativa del Archivo Nacional

Junta de Protección Social de San José

Movimiento Nacional de Juventudes

Oficina del Arroz Ley No 7014

Dirección General de Educación Física y Deportes

Patronato Nacional de Ciegos

Museo de Arte Costarricense

Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas.

Todos estos entes **no** exentos deberán pagar en consecuencia los timbres de ley, de acuerdo con las disposiciones mencionadas líneas arriba.

d- La necesaria y debida cancelación de los timbres

Es preciso recordar que para que los timbres adheridos a un documento o certificación surtan todos los efectos legales, deben ser debidamente cancelados, es decir, una vez adheridos al documento, deben ser firmados por el funcionario o persona que lo expide, o en su caso, con el sello propio, el de la oficina, o el del establecimiento. En el caso de los vales o el pagaré deberán ser firmados por el deudor o el fiador, mientras que en los documentos o instrumentos públicos no registrables, deben ser cancelados por el funcionario que los autoriza.

(sobre este aspecto pueden verse los artículos 285 del Código Fiscal y 13 de la Ley de Timbre Forense).

En cuanto a la cancelación de los timbres también ha surgido duda en cuanto a al obligado a cancelarlos para el caso de las certificaciones expedidas por contador público, luego del cierre de una cuenta corriente (art. 611 del Código de Comercio), pues unos señalan al Contador Público como el encargado de hacerlo, mientras que otros afirman que la cancelación corresponde al abogado que hará uso de la certificación en el proceso ejecutivo. Consideramos la segunda posición como errada, pues lo hemos señalado, de conformidad con el inciso 4o del artículo 285 del Código Fiscal, en estos casos, la cancelación debe hacerla el funcionario o profesional que expide el documento, que para el caso específico es el Contador Público, y no el otro profesional que hará uso de ella, puesto que para ello (para usarla), deberá ser perfecta, válida y eficaz, lo que no se cumple sino hasta que el Contador adhiera y cancele los timbres de ley.

Ahora bien, qué sucede si el personero encargado no cancela los timbres correspondientes ?. Es decir, cómo debe actuar la autoridad pública o el Juez (en sentido lato) si se presenta a su Despacho un documento sin los timbres correspondientes o sólo con parte de ellos ?.

La pregunta puede desdoblarse en dos sentidos. ¿ Qué debe hacerse procedimentalmente ?, y ¿ qué sanción (si es que cabe) debe aplicarse a quien incumplió con tal obligación ? Sobre el primer aspecto el Código Procesal Civil se limita a señalar en

el párrafo final del artículo 291 (referido a la demanda defectuosa), que el Juez ordenará el pago de especies fiscales faltantes en los documentos, con lo cual no brinda mayor luz, pues, ¿ cómo, cuando y con qué efectos debe dictarse esta orden? Al respecto debe concordarse este artículo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 286 del Código Fiscal, reformado por la Ley Para el Equilibrio Financiero del Sector Público, No 6955 de 24 de febrero de 1984, que en principio nos da una clara respuesta y que literalmente manifiesta:

> "No se admitirá ni se recibirá en las oficinas públicas ningún documento que, debiendo haber pagado timbre, sea presentado sin él en todo o en parte. El documento en que no se haya satisfecho ese impuesto del todo, o que no esté completo, o no haya sido cancelado conforme a las reglas del artículo 285, <u>será inútil e ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno</u>, mientras no se pague la multa que se dirá, y los tribunales y funcionario de la Administración Pública lo declararán así de oficio." (el subrayado no es del original)

Como puede verse, el Código niega toda validez y eficacia al documento que no haya cubierto los timbres fiscales, por lo que en principio podría pensarse que no puede atenderse la gestión realizada con él, sino hasta que pague el timbre y su multa. Para nuestros efectos, habríamos de decir entonces que

una certificación expedida como título ejecutivo o un poder en su caso, no podría atenderse sino hasta que cubra los timbres fiscales.

No obstante lo anterior, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, al referirse a una copia certificada de un documento ejecutivo presentado por un Banco Estatal en el que no se cancelaron los timbres de ley, señaló:

> *"Si bien es cierto se echan de menos las especies fiscales correspondientes de la certificación emitida, ello en modo alguno le resta fuerza ejecutiva al documento, debiendo en casos como éste, optar el Juzgador por requerirlos de manera previa o simultánea al dar curso a la acción" (Resolución No* ***361- 89*** *de las 9: 55 hrs. del 24 de agosto de 1989)*

Estamos plenamente de acuerdo en que no es necesario prevenir los timbres como acto previo a despachar ejecución, para no negar del todo el curso a la demanda ejecutiva. Pero, ¿ no contraría lo dispuesto por el Tribunal la letra del artículo 286 recién transcrito, toda vez que permite -como una opción más-, la prevención de los timbres para su cancelación posterior, dando así validez a la gestión y documento presentado sin ellos?. Consideramos que no es así, puesto que comprendemos el sentido y finalidad práctica de la resolución, y la compartimos en un todo, pues no tiene razón de ser el que se paralice el proceso por aspectos fiscales y se obligue al Juzgador a emitir varias resoluciones, primero previniendo,

luego resolviendo la gestión, cuando bien pudo hacerlo en un solo auto. Y estas razones de orden práctico, que no podrían ser solo eso, tampoco chocan con la normativa legal, pues no obstante lo dispuesto por el Código Fiscal en el numeral transcrito, debe traerse a colación lo preceptuado por la Ley No 3889 de 2 de junio de 1967, que constituye una ley especial, aplicable en esta materia por encima del Código mencionado. Disponen los artículos primero y segundo de la ley de referencia lo siguiente:

> *"1o.- Cuando por disposición de la ley hubiera de pagarse en la tramitación de expedientes judiciales o administrativos, timbre de cualquier clase que sea y cualquiera que sea la causa que motiva su pago y se omitiere el cumplimiento de esa obligación, en todo o en parte, el funcionario o tribunal respectivo prevendrá la presentación del timbre en el término de tres días a la parte omisa, y mientras no se cumpla la prevención, no se dará curso a las gestiones de esa parte. Las gestiones hechas antes de la prevención, o en el curso de ésta, surtirán los efectos legales consiguientes, pero a las posteriores, no se les dará curso sino en el momento en que se pague el timbre, sin retroacción de términos. La parte que no hubiere pagado el timbre, no será oída en las diligencias o actuaciones que deban llevarse a cabo en el expediente, tales como inspecciones oculares (sic) , pruebas de testigos o*

cualesquiera otras similares, mientras no se haya hecho el referido pago.

Artículo 2o : Si la omisión a que alude el artículo anterior ocurriere en documentos presentados en el expediente, el incumplimiento de la prevención de pago del timbre, privar de valor probatorio al documento mientras no se efectúe el pago y en su caso, de la multa, cuando ésta proceda. este no podrá realizarse si el juicio se hallare ante la Sala de Casación." (el subrayado no es del original)

En otros términos, compartimos en todo lo resuelto por el Tribunal en la resolución transcrita arriba, pues en aquellos casos en los que se omita el pago de timbres fiscales, forense o de cualquier otra índole, con la salvedad del correspondiente al Colegio de Abogados, deber atenderse la gestión formulada, previniendo el pago de los mismos, o de su correspondiente multa (como ocurre con el forense y el fiscal) dentro del plazo de tres días. Así lo reiteró también en forma implícita el Tribunal Superior Contencioso, Sección Segunda, mediante resolución número 3651 de las 10:30 hrs. del 8 de enero de 1988.

En cuanto a las sanciones que establece la ley por el no pago de timbres, no ya procesales, sino a nivel patrimonial sobre la negociación de fondo, tenemos lo dispuesto en el

párrafo segundo del mencionado artículo 286 del Código Fiscal, el que a la letra dice:

> *"Sin embargo, tales documentos surtirán efecto legal, si el interesado agrega los timbres en cantidad de diez veces la que correspondía, cuando nada se hubiere pagado o estuvieren los timbres sin cancelar o mal cancelados; y diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse si el timbre estuviere incompleto"*

Es decir, por el no pago de timbres fiscales, el interesado deber cancelar diez veces lo dejado de pagar. Esta disposición **no se aplica sin embargo al timbre de rehabilitación, que sólo deber prevenirse en la suma no pagada, pero sí se aplica al timbre forense** por disposición expresa del artículo 13 de la ley respectiva que señala: *"... y si se defraudare ese impuesto, incurrirá en una multa a favor del Estado, equivalente a diez veces el impuesto defraudado"* .

e- Timbres de la Autenticación.

Dijimos también que la demanda ejecutiva necesita de autenticación, y al requerirla, también exige el correspondiente timbre del Colegio de Abogados, a cancelar de acuerdo con los montos establecidos en el artículo 103 del nuevo Arancel de Profesionales en Derecho (Decreto Ejecutivo No 20307-J del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno), lo que deberá hacerse en el primer escrito con el que se apersone la parte, ya sea actor o demandado. Uno de los problemas que se

han presentado recientemente con el mismo, radica en el hecho de que el artículo 109 inciso b) del mencionado decreto, establece que en caso de que se omita, los Tribunales y oficinas administrativas, prevendrán al interesado su pago o reintegro bajo la advertencia de no tramitar la gestión, lo que ha llevado a pensar a muchos funcionarios que mientras no se cubra el mismo, no debe darse el trámite correspondiente a la gestión. Esto implicaría que en la demanda ejecutiva cuando no se cubra el timbre del Colegio de Abogados, no despacharían ejecución sino que procederían a prevenir el timbre de rigor. No obstante, dicha interpretación, aunque parece ajustada a lo dispuesto por el mencionado inciso b) del artículo 109 del decreto, violenta abiertamente la Ley de Creación del Timbre del Colegio, obviamente de grado superior, circunstancia que convierte en ilegal lo que en ese sentido establece la nueva disposición reglamentaria. En efecto, el timbre fue creado por Ley No 3245 de 3 de diciembre de 1963 en su artículo 3, y en el artículo 4 de esa misma ley se dispuso clara y tajantemente que ante el no pago del timbre, no debían recibirse los escritos y documentos en oficinas públicas y tribunales, y que en el caso de que se hubieren recibido, se debía hacer la prevención pertinente sin dar curso a la gestión. Bajo esta normativa, la interpretación que se ha dado al artículo 109 de la Tarifa, resultaría plenamente válida. Sin embargo, el mencionado artículo 4 de la ley, fue reformado por ley No 3596 de nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, disponiendo en su lugar que:

"Cuando las oficinas administrativas o los Tribunales de Justicia, de cualquier instancia o grado, notaren que el timbre no ha sido agregado en todo o en parte, sin perjuicio de dar trámite a la gestión, o del curso dado a las anteriores, prevendrán el pago o reintegro correspondiente, dentro del plazo de diez días, bajo el apercibimiento de no oír al omiso mientras no se cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos.

El Registro de Prendas no inscribirá el certificado hasta tanto no se agregue el timbre y tendrá el documento como defectuoso." (el subrayado es nuestro).

Como puede verse entonces, debe prevenirse el timbre hacia el futuro, sancionando al remiso con la no atención de sus posteriores escritos, lo que implica dar curso a su primera gestión en la que incumplió el requisito mencionado. Lo contrario sería incluso una transgresión del principio de celeridad, economía procesal y antiformalismo, puesto que implicaría para el Despacho la emisión de un auto exclusivo para ese efecto, para luego, una vez cumplido el requisito, dar curso al proceso, dos resoluciones, dos notificaciones, dos revisiones del funcionario judicial que firma, en fin, dos movimientos completos del expediente para cumplir con el requisito de un simple timbre, eso sin tomar en cuenta el retraso que implica para el actor acreedor, que eventualmente puede estar urgido de los decretos de embargo.

El problema que aquí se presenta es que tradicionalmente se

ha conferido un plazo de diez días para el pago del mencionado timbre (sin multa claro está), de acuerdo con el artículo transcrito de la ley correspondiente a ese timbre. Sin embargo, tenemos que por otro lado, está la ley 3889 de 1967 cuyo artículo primero ya transcribimos que habla de **cualquier timbre**, **sea cual sea la causa de su pago**, y establece un plazo de tres días para la prevención. Realmente no podemos afirmar que la ley del timbre del Colegio de Abogados, sea especial sobre esta última, pues ya dijimos que ésta cubre cualquier timbre, y se refiere en especial a aquellos que deben cancelarse en una gestión judicial. Y tampoco podría aplicarse el criterio temporal para superponer la del timbre del colegio, pues esta última (3889) también es posterior. Así las cosas, parece que el plazo de diez días que hemos venido otorgando para cumplir con el pago del timbre del Colegio de Abogados no es la correcta, pues debe aplicarse la establecida en la ley tantas veces citada 3889, que hable del plazo de tres días en forma general.

11- Copias.

Dejando ya de lado el tema de los timbres, encontramos que como parte de las cosas que deben adjuntarse a la demanda ejecutiva, están las copias del escrito de demanda y los documentos presentados, tal y como lo requiere el artículo 136 del Código Procesal Civil. Deben presentarse tantas copias como litigantes haya y para tal efecto se considerará como una

sola persona litigante los apersonados conjuntamente y bajo una misma representación. Para el caso de los documentos, deberá presentarse una copia más, a efecto de agregarla al expediente y puedan ser consultados por las partes. En este aspecto en muchos Despachos impera una costumbre antijurídica y peligrosa en cuanto se agregan al expediente los documentos originales con el grave riesgo de que puedan ser sustraídos. Debe repetirse entonces que de aquellos documentos que se aporten, esencialmente como prueba (puesto que no deben incluirse en ellos las certificaciones de piezas fácilmente reponibles) debe adjuntarse al expediente copia, no el original que deberá ser custodiado en el archivo del Despacho, sin perjuicio de que la parte pueda revisarlo, tal y como lo señala el artículo 140 párrafo 3o del mismo cuerpo normativo.

Para esta regla establece el Código dos excepciones, por un lado, que no es preciso presentar copias de libros o folletos, los que deben estar a disposición de la parte; y por otro, la contenida en el artículo 326 del mismo Código, en cuanto autoriza la presentación de escritos sin copias para hacer constar los pasos dados por la parte, a fin de que no se demore la recepción de sus pruebas.

El artículo 136 dispone que las copias deben ser suscritas por la parte o por su abogado director, sin hacer distinción de ellas, pero creemos que debe distinguirse entre copias literales al carbón y copias fotostáticas del escrito ya rubricado por la parte y por su abogado. Las primeras sí deben ser firmadas en la forma que indica el artículo, pero parece

innecesario el requisito para las segundas, desde que ya vienen incluidas en la fotocopia. Obviamente si la copia fotostática tampoco presenta las firmas correspondientes, deberá ser rubricada en los términos señalados por la disposición de comentario.

Cabe mencionar además, que el nuevo Código Procesal Civil acertadamente elimina la obligación que el anterior imponía al Secretario del Despacho Judicial en el sentido de que no debía recibir ningún escrito ni documento al que no se acompañaran las copias respectivas o el valor de las mismas (artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles). Con ello se partía de la presunción equivocada de que ese funcionario revisaba todo escrito y documento al momento de su ingreso, lo cual no es solo absurdo sino humanamente imposible, al menos en estos tiempos. Por ello, el nuevo Código (que ya no lo es tanto) parte del supuesto razonable de que tal requisito difícilmente puede ser corroborado por el empleado "manifestador" al momento de recibir el escrito, pues no es sino hasta el momento del proveído en donde el funcionario encargado se percata de ello, y algunas veces ni allí, por lo que toca al notificador hacer la observación. Por ello, se prevé de una sola vez la hipótesis de no presentación de copias, disponiéndose al efecto que el Juez <u>dictará la resolución que para el escrito cabe</u> y con ella ordenará la presentación de las copias omitidas o presentadas en forma incompleta dentro de tercero día, bajo apercibimiento de que en caso de omisión no se le escucharán sus posteriores gestiones (mismo artículo 136 del C.P.C.). Es por esto que

sobre ese aspecto, discrepamos con lo resuelto por el Tribunal Superior Contencioso, Sección Segunda, el que para un caso particular dispuso que los más conveniente era prevenir los documentos (las copias) antes de dictar la resolución correspondiente (para el caso una audiencia) (al respecto véase la resolución No **340-90** de las 8: 40 hrs. del 8 de junio de 1990).

Por último sobre este aspecto de las copias, debe tenerse presente para el caso de documentos microfilmados, o sus copias, lo dispuesto por la **Ley No 4278 de 11 de diciembre de 1978**, en donde se confiere el mismo valor del original a las copias certificadas de aquellos en microfilm.

Capítulo VI: Defectos de la Demanda.

Ya hemos comentando algunos aspectos sobre la forma de subsanar los defectos y acerca de las sanciones por el incumplimiento u omisión en cuanto a timbres, autenticación y copias, que gozan de disposiciones especiales. Pero, ¿ qué sucede ante el incumplimiento de los demás requisitos, como es el caso de la pretensión, calidades, estimación, etc. ? Al respecto el Código Procesal Civil contiene la norma del 291 referida a la demanda defectuosa y la manera de subsanarla. Dispone el numeral citado en lo que interesa lo siguiente:

> *"Si la demanda no llenare los requisitos legales, el juez ordenará al actor que la corrija y, para ello, le puntualizar los requisitos omitidos o no llenados como es debido. Igual orden dará en el caso de que la parte demandada, dentro de los diez primeros días del emplazamiento, señalar algún defecto legal que el Juez hallare procedente. Dicha resolución, en ambos casos, carecerá de recurso.*
>
> *En la resolución se prevendrá la corrección dentro del plazo de cinco días, y si no se hiciere, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su archivo.*
>
> *La resolución en la que se ordene la corrección de la demanda no tendrá recurso de apelación; sí lo tendrá en ambos efectos aquella en la que se declare la inadmisibilidad"*

El artículo incluye en su párrafo final en forma expresa los timbres como parte de los requisitos de la demanda, según lo señalamos páginas arriba, al comentar el tema. El 114 del mismo Código se refiere a la autenticación, y el 136 Ibidem alude a las copias.

Ahora bien, para empezar, se ha cuestionado seriamente la aplicabilidad de dicha norma al proceso ejecutivo. En efecto, antes que nada es preciso despejar esta interrogante, o al menos dejar establecida nuestra posición. Son numerosos los votos salvados de la Licda. Sonia Ferrero Aymerich en cuanto a la inaplicabilidad del precepto aludido al proceso sumario, mientras que por mayoría el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, ha aplicado lo ha aplicado a sin número de situaciones presentadas en la acción ejecutiva. La Jueza Ferrero estima esencialmente que los requisitos de la demanda ejecutiva están claramente delimitados en el artículo 433 del C.P.C., mientras que en el 440 se dispone lo necesario para dar curso a la acción ejecutiva. De allí que en su criterio, la normativa del proceso ejecutivo no es omisa en cuanto los requisitos de demanda ni la forma de subsanarlos, razón por la cual no puede aplicarse el artículo 291 del mismo Código (dirigida al proceso ordinario) como norma integrativa valiéndose para ello de lo dispuesto en el numeral 437 del mismo cuerpo normativo, según el cual son aplicables a los procesos sumarios lo dispuesto para los ordinarios, en lo que se guarde silencio, sea compatible y no se oponga a las reglas

particulares de aquellos. Por ello, también estima que muchos de los requisitos que se previenen bajo la regla del 291, no pueden dar lugar a la inadmisibilidad de la acción, pues no son requisitos de la demanda ejecutiva en sentido estricto, puesto que además el artículo 440 solo exige para despachar ejecución la "personalidad" del actor y el título ejecutivo . Al respecto puede verse el voto salvado de la resolución No **445-90** de las 9:10 hrs. del 8 de agosto de 1990, que sirve de fundamento para las posteriores.

En este aspecto compartimos el criterio de la mayoría del Tribunal en cuanto permite la aplicación de la norma al proceso ejecutivo. Es cierto que el 440 mencionado solo se refiere a la personería y al título, pero no puede verse en forma aislada sino en concordancia con el 433 que establece los demás requisitos para la demanda. Afirmar que basta con la comprobación de lo indicado en el 440 para despachar ejecución, equivaldría admitir que cualquiera presente un título demostrando su legitimación para cobrarlo, sin ningún otro requisito ni formalidad. Por otra parte, para el proceso ejecutivo no existe ninguna norma específica que regule la forma y medios para subsanar los defectos de la demanda, por lo que bien se hace al acudir al 437 para tomar con fundamento en él lo dispuesto por el 291.

Ahora bien, ¿ cúales son los requisitos de la demanda que pueden y deben prevenirse bajo esta norma del 291 ?. El aspecto aunque parece simple ha provocado diversos criterios, pues por mayoría el Tribunal lo ha venido aplicando por ejemplo para el

caso en que se incumplan las personerías del actor o demandado, mientras que la licenciada Ferrero Aymerich salva su voto por considerar que las mismas no son requisito de la demanda, a tenor de lo que disponen los mencionados 433 y 440 del C.P.C. Aquí también compartimos el criterio de la mayoría, pues consideramos que los requisitos de la demanda ejecutiva no pueden verse en forma restrictiva, ya que si se presenta el cobro contra una persona jurídica es imprescindible determinar si la misma existe y quien es su representante, como requisito básico de la demanda , de manera que en caso de incumplimiento habremos de aplicar la prevención que establece el artículo de comentario. Si bien es cierto el artículo 433 no las menciona expresamente como parte de la demanda, debemos entender que están contempladas como parte del nombre y calidades del actor y demandados, pues no se concibe - insistimos- una persona jurídica como demandante o accionada sin la adecuada comprobación de su existencia y de su representante (sobre este aspecto pueden verse los criterios de Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, No 445-90 de las 9:10 hrs. del 8 de agosto de 1990 y la No 566-92 de las 11:20 hrs. del 4 de junio de 1992). De modo que en nuestro criterio, todo elemento o documento esencial para una demanda adecuada y completa, puede ser prevenido por vía del 291 en mención. El problema se torna aún más complejo cuando se trata del demandas hipotecarias o prendarias con renuncia de trámite, pues en esos casos se afirma que no se trata de un proceso ejecutivo y por ello se rechaza la aplicación del art. 437 que permite acudir a

la norma del 291. En efecto, resulta cierta la afirmación de que ni el 663 (del proceso hipotecario sin renuncia) ni el 682 (del proceso prendario) permiten la remisión a las normas del proceso ejecutivo común, pero en nuestro criterio tal remisión expresa no es necesaria, pues por principio debemos acudir a la norma general en caso de silencio tal y como ocurre en estos casos de procesos con renuncia. De allí que, si el actor no aporta la relación de gravámenes general del Registro (como lo exige por ejemplo el 674 in fine del C.P.C. para los procesos prendarios) o el documento de hipoteca base del proceso deba prevenírsele para que lo aporte dentro del plazo de cinco días bajo apercibimiento de declarar inadmisible la demanda (al respecto pueden verse las resoluciones del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Nos 742-90 de las 10:00 hrs. del 25 de octubre de 1990 y la 732-91 11:40 hrs. del 3 de diciembre de 1991)

Como puede verse nuestra interpretación del artículo es ampliativa, pues los redactores del Código siempre tuvieron presente la celeridad del proceso, que se manifiesta no solo en las actuaciones del Despacho, sino en la seriedad y acuciosidad con la que las partes gestionen sus pedimentos. De modo que no resulta correcto que el litigante presente en forma reiterada demandas incompletas -muchas veces dirigidas a generar tan solo honorarios-, y que posteriormente pendan en forma indefinida ante la autoridad judicial, la que de no ser por ese artículo no podría hacer nada con el proceso, mas que prevenir lo omitido.

ANEXOS

CLASIFICACION DE LOS TITULOS EJECUTIVOS

```
                                        +---- JUDICIALES EN
                                        |     SENTIDO ESTRICTO
                                        |
                                        |
                                        |
                             TITULOS  -----+
                  +----------- JUDICIALES    |
                  |                          |
                  |                          |
                  |                          +---- JUDICIALES
                  |                                MIXTOS
                  |
                  |
                  |
                  |
                  |
                  |
                  |
                  |
TITULOS ---------+
EJECUTIVOS        |                                          DE ORDEN
                  |                                     +--- PUBLICO
                  |                                     |
                  |                                     |
                  |                                     |    DE ORDEN
```

```
                  |                                     |    PUBLICO
                  |                  +-- NEGOCIALES ----+--- CON
PARTICI-                              |                  |
     |    PACION DE
                                           |                  |
```

```
          |    PRIVADOS                              |
|                  |
                  |                  |                  |
                  |                  |                  |
                  |                  |                  +--- PRIVADOS
                  |                  |
                  +--TITULOS   ------+
                     EXTRAJUDICIALES |
                                     |
                                     |
                                     |
                                     +-- ADMINISTRATIVOS
```

EJECUTIVO SIMPLE.

(Ente o sujeto acreedor y demandante) contra (Deudores o Demandados) .

Señor Alcalde Civil de Hacienda:

Quien suscribe.....,en mi condición de apoderado de ....., con facultades suficientes para este acto, según consta en la certificación de personería archivada en ese Despacho, ante Usted respetuosamente manifiesto:

HECHOS:

Según consta en el título ejecutivo adjunto (*o en la copia certificada adjunta*), el señor (*nombre, calidades y número de cédula, o en su caso, nombre de la persona moral con su cédula jurídica y certificación de personería*), es en deberle a mi representada a esta fecha de plazo vencido, la suma de ..... que corresponden a capital por la suma de..... y a los intereses que ascienden a la suma de ....., según el siguiente desglose (*período*, *tipo de interés y monto*).

Dicha obligación se encuentra garantizada con fianzas de los señores (*nombres, calidades y números de cédula*).

PRETENSION:

Por lo expuesto y en vista de que la obligación es líquida y exigible desde el ....., demando en esta vía ejecutiva al deudor y los fiadores dichos, por lo que solicito que se despache ejecución, se decrete embargo y en sentencia se condene a los demandados al pago del principal, los intereses indicados y futuros (*o las multas o recargos*), y las costas personales y procesales de esta demanda.

Solicito además que el embargo se decrete sobre lo siguiente: (*bienes embargables del deudor y fiadores, aportando las respectivas*

certificaciones de propiedad del Registro Público si se trata de bienes inscribibles). Para lo anterior, solicito se expidan los oficios y mandamientos de anotación correspondientes, los que diligenciaré personalmente, a cuyo efecto autorizo para su retiro a .....

DERECHO:

Fundo mi pretensión en los artículos 1- 221- 433 - 438 y siguientes del Código Procesal Civil, así como en el artículo 70 y concordantes de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (*o en su caso la Ley Específica que da ejecutividad a sus títulos*) y los artículos ..... del Código de Comercio (*cuando sea aplicable claro está*)

ESTIMACION:

Estimo esta demanda en la suma de (capital, intereses o multas al momento de la presentación de la demanda).

NOTIFICACIONES.

Señalo para oír notificaciones dentro del perímetro judicial en (lugar preciso). Al demandado puede notificársele en ..... y a los fiadores en .....

San José, (*fecha*)

Firma autenticada del representante del ente (*salvo si es abogado en cuyo caso autentica por sí*), con indicación del nombre del personero.

EJECUCION HIPOTECARIA.

(Ente o sujeto acreedor y demandante) **contra** (Deudores o Demandados) .

Señor Alcalde Civil de Hacienda:

Quien suscribe....., en mi condición de apoderado de ....., con facultades suficientes para este acto, según consta en la certificación de personería archivada en ese Despacho, ante Usted respetuosamente manifiesto:

HECHOS:

Según consta en la certificación del Registro Público que acompaño, el señor (*nombre, calidades y número de cédula*) o en su defecto, la sociedad....., representada por el señor (nombre, calidades y número de cédula), en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de dicha empresa (*este ocurre en la gran mayoría de los casos, de no ser así indicar la limitación, poderes conjuntos o cualquier otro elemento*), con cédula jurídica número....., personería que se demuestra con la certificación adjunta, es en deberle a mi representada a esta fecha de plazo vencido, la suma de ....., correspondiente a capital y sus respectivos intereses, los que ascienden a la suma de ....., conforme al siguiente desglose..... (*períodos, tipo de interés y monto*).

Dicha obligación se encuentra garantizada con hipoteca de primer grado (*o indicar el grado correspondiente*) sobre la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, al Folio Real Matrícula número....., propiedad de ..... (*nombre, calidades y número de cédula de la persona física y citas de inscripción y personería completa si se trata de persona jurídica*), así como la fianza solidaria de ..... (*nombre, calidades y número de cédula*).

De igual forma consta en la certificación adjunta que sobre el inmueble en referencia pesa además ..... (*hipotecas de grado inferior, embargos practicados, anotaciones de decreto de embargo vigentes, terceros poseedores, caución real en proceso penal, civil o contencioso administrativo, patrimonio familiar, arriendo de predio rústico inscrito, anotación de demanda ordinaria, etc*) en favor de .....

PRETENSION

Por lo expuesto, constituyendo el documento presentado título ejecutivo con renuncia de trámites (*si no hubiere renuncia deber tramitarse como ejecutivo simple, sin necesidad de posterior embargo y valoración del bien que ya está dado con el documento*), y encontrándose vencida y exigible la deuda desde el ....., demando en esta vía de ejecución hipotecaria al señor deudor y fiadores indicados, en sus calidades dichas, por lo que solicito:

1.- Se anote la presente demanda al margen de la finca anteriormente descrita, para lo cual pido que se expida el mandamiento correspondiente, el cual se diligenciará personalmente, a cuyo efecto autorizo para su retiro a .....

2.- Se confiera audiencia a las partes demandadas sobre la liquidación de intereses que presento.

3.- Se proceda a señalar día y hora para la celebración del remate del bien hipotecado, sirviendo como base la suma de capital por el que responde (*o en su caso "el crédito por el que responde"*), autorizando para participar en cualquiera de los remates que se realicen a ..... Solicito además se confeccione el edicto respectivo, para cuyo retiro autorizo a ..... (*puede solicitarse también que se adjunte a la cédula de notificación del auto inicial, como ha venido siendo costumbre en la materia civil de hacienda, para comodidad de las partes y celeridad del proceso*)

DERECHO

Fundamento la presente demanda en los artículos 660 y siguientes del Código Procesal Civil; 70 y siguientes de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (*si se trata de un Banco o bien de un ente menor que se ampara a los beneficios de la misma*), y 409, 415, 417, 419, 422 y concordantes del Código Civil.

ESTIMACION

Estimo la presente demanda en la suma de (*capital mas intereses a la fecha de presentación*).

NOTIFICACIONES.

Señalo para oír notificaciones ....(*indicar lugar preciso, no es conveniente la expresión "con el abogado autenticante"*). los obligados podrán ser notificados en: **A**: la empresa o persona física o deudora en .....; **B**: los señores fiadores en.....; **C**: los acreeedores de grado en .....; **D**: al anotante de una demanda ordinaria, al cónyuge con derechos de patrimonio familiar; al Patronato Nacional de la Infancia si hay menores; al arrendatario de predio con contrato inscrito en el Registro Nacional; a quien anotó decreto de embargo aún vigente, etc, etc, en ..... (*no se notifica al Estado en caso de ejecución del bien dado luego de la hipoteca como caución real en un proceso judicial específico, allí sólo se comunica por oficio al Despacho encargado*)

San José (Fecha.)

Firma y nombre autenticada del representante del ente.

Nota: en caso de cédulas hipotecarias la demanda tendría algunas

variantes..

EJECUCION PRENDARIA.

(Ente o sujeto acreedor y demandante) **contra** (Deudores o Demandados) .

Señor Alcalde Civil de Hacienda:

Quien suscribe....., en mi condición de apoderado de ....., con facultades suficientes para este acto, según consta en la certificación de personería archivada en ese Despacho, ante Usted respetuosamente manifiesto:

HECHOS:

Según consta en la certificación del Registro Público de Prendas que acompaño, el señor (*nombre, calidades y número de cédula*) o en su defecto, la sociedad....., representada por el señor (*nombre, calidades y número de cédula*), en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de dicha empresa (*este ocurre en la gran mayoría de los casos, de no ser así indicar la limitación, poderes conjuntos o cualquier otro elemento*), con cédula jurídica número....., personería que se demuestra con la certificación adjunta, es en deberle a mi representada a esta fecha de plazo vencido, la suma de ....., correspondiente a capital y sus respectivos intereses, los que ascienden a la suma de ....., conforme al siguiente desglose.....(*períodos, tipo de interés y monto*).

Dicha obligación se encuentra garantizada con prenda de primer grado (*o indicar el grado correspondiente*) sobre los bienes descritos en el certificado de Prenda No ....., el cual adjunto debidamente certificado, así como la fianza solidaria de ..... (*nombre, calidades y número de cédula*).

De igual forma consta en la certificación adjunta que sobre los bienes de referencia pesa además ..... (*embargos practicados, anotaciones de decreto de embargo vigentes, caución real en proceso penal, etc*) en favor de .....

PRETENSION

Por lo expuesto, constituyendo el documento presentado título ejecutivo con renuncia de trámites (*si no hubiere renuncia deber tramitarse como ejecutivo simple, sin necesidad de posterior embargo y valoración del bien que ya está dado con el documento*), y encontrándose vencida y exigible la deuda desde el ....., demando en esta vía de ejecución prendaria al señor deudor y fiadores indicados, en sus calidades dichas, por lo que solicito:

1.- Se anote la presente demanda en el Registro de Prendas y en el Registro de Público de la Propiedad de Vehículos (*si es que procede en este último caso*), para lo cual pido que se expida el mandamiento correspondiente, el cual se diligenciará personalmente, a cuyo efecto autorizo para su retiro a .....

2.- Se nombre ejecutor para que proceda al embargo del bien

pignorado, nombrando como depositario al señor..... (*y para el caso de que el deudor no ponga el vehículo emprendado - si es esto con lo que se garantiza - a disposición del Despacho*) y se expida orden de captura sobre el vehículo marca ....., placas ....., para que el ejecutor pueda practicar el embargo (*aportar certificación del vehículo*).

3.- Se confiera audiencia a las partes demandadas sobre la liquidación de intereses que presento.

4.- Se proceda a señalar día y hora para la celebración del remate del bien pignorado, sirviendo como base la suma de capital por el que responde (*o en su caso "el crédito por el que responde"*), autorizando para participar en cualquiera de los remates que se realicen a .....

5.- Solicito además se confeccione el edicto respectivo, para cuyo retiro autorizo a ..... (*puede solicitarse también que se adjunte a la cédula de notificación del auto inicial, como ha venido siendo costumbre en la materia civil de hacienda, para comodidad de las partes y celeridad del proceso*)

PRUEBA

1. Aporto certificado de prendas del Registro Nacional.
2. Certificación de Propiedad del Registro Público del Vehículo.....
3. Certificación sobre la existencia, vigencia y personería de la sociedad mencionada.

DERECHO.

Fundamento la presente demanda en los artículos 530 y siguientes del Código de Comercio; 432, 433, 438 y siguientes del Código Procesal Civil, así como en el artículo 70 y concordantes de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (*cuando se trate de un Banco o de un ente menor amparado a las disposiciones de dicha ley*)

ESTIMACION

Estimo la presente demanda en la suma de ..... (*capital mas intereses al momento de la presentación de la demanda*)

NOTIFICACIONES

Señalo para oír notificaciones en ..... (*indicar lugar preciso*). Al demandado en ....., para lo cual pido que se confeccione y retenga la comisión correspondiente para ser retirada en forma personal por..... para su diligenciamiento oportuno y conjunto con la autoridad comisionada (*si es que está fuera del perímetro judicial*). A los fiadores, acreedores, anotantes, etc., en.....

San José, (fecha)

Firma y Nombre del Representante del Ente.
Autenticación